

《【문제1.1】 민사소송법의 법적 성격에 대해 논하시오. (25점)》

<문제1.1> 민사소송법의 법적 성격

I. 서론

- 법은 그 규율 대상과 목적에 따라 사법(私法)과 공법(公法)으로 구분된다. 사법은 사인 간의 평등한 관계를 규율하며 사적 자치의 원칙이 지배하는 영역인 반면, 공법은 국가와 개인 간의 수직적 관계나 공공의 이익을 규율하는 영역이다. 민사소송법은 사적인 권리관계를 확정하고 실현하는 절차를 다루지만, 그 절차를 주재하는 주체는 국가기관인 법원이다. 이하에서는 민사소송법이 사법과 공법 중 어느 영역에 속하는지, 그리고 그 근거가 무엇인지에 대하여 구체적으로 검토한다.

II. 민사소송법의 공법적 성격

1. 공법과 사법의 구별 기준

- 법의 분류에서 공법은 국가 조직, 공공단체와의 관계, 국가 권력의 행사를 규율하는 법을 의미한다. 사법은 개인의 경제적 활동이나 가족 관계 등 사적 영역을 규율한다. 민사소송법이 규율하는 민사소송절차는 사법상의 권리를 실현하기 위한 것이지만, 그 과정에서 국가의 사법권(司法權)이 개입한다는 점에서 독특한 위치를 점한다.

2. 국가기관인 법원의 개입

- 민사소송은 국가의 사법권(司法權) 행사 과정이다. 사인이 스스로의 힘으로 권리를 쟁취하는 자력구제는 원칙적으로 금지되며, 오직 국가가 설치한 법원을 통해서만 법적 분쟁을 해결할 수 있다. 법원은 국가의 통치권 중 하나인 사법권(司法權)을 행사하는 공공기관이며, 민사소송법은 이러한 공공기관의 직무 수행 절차를 규정하므로 공법에 해당한다.

3. 강행법규적 성격

- 사법(私法)인 민법이나 상법은 사적 자치의 원칙에 따라 당사자의 합의가 법규보다 우선 적용되는 임의법규적 요소가 많다. 그러나, 민사소송법은 국가가 공정한 재판을 보장하기 위해 설정한 절차법이므로, 당사자의 합의로 절차를 마음대로 변경할 수 없는 강행법규적 성격이 강하다. 이러한 강행성은 공법의 일반적인 특징이다.

III. 민사소송법의 절차법적 성격

1. 실체법과 절차법의 구분

- 법은 그 내용에 따라 실체법과 절차법으로 나뉜다. 민법, 형법 등은 권리와 의무의 발생, 소멸을 다루는 실체법이며, 민사소송법, 형사소송법 등은 그러한 실체적 권리를 실현하는 순서와 방법을 규정하는 절차법이다. 민사소송법은 전형적인 절차법으로서 공정한 재판 절차를 유지하는 데 그 본질이 있다.

2. 소송계속과 판결의 효력

- 민사소송법은 소를 제기하고, 변론을 진행하며, 판결을 내리고, 그 판결이 확정되는 일련의 역동적인 과정을 규율한다. 판결의 효력 중 하나인 기판력은 국가가 내린 최종적인 판단에 대하여 다시 다투지 못하게 하는 강력한 법적 힘을 부여하는데, 이는 사법(私法)상의 합의와는 차원이 다른 국가 공권력의 산물이다.

IV. 민법과의 관계 및 차이점

1. 사법(私法)의 실현을 위한 수단

- 민사소송법은 실체법인 민법의 권리를 확정하고 강제적으로 실현하기 위한 도구적 역할을 수행한다. 민법이 어떤 권리가 있는가를 다룬다면, 민사소송법은 그 권리를 어떻게 증명하고 실현하는가를 다룬다. 이러한 관계 때문에 과거에는 민법의 부속물처럼 취급되기도 했으나, 현대 법학에서는 소송절차 고유의 논리와 목적을 인정하여 독립된 법 영역으로 간주한다.

2. 소송법적 효과와 실체법적 효과의 분리

- 민사소송법상 행해지는 소송행위는 민법상의 의사표시와 구별된다. 예를 들어, 소송상 화해는 소송을 종결시키는 공법적 효과를 가짐과 동시에 당사자 간의 사법상 계약이라는 측면도 지닌다. 하지만, 절차의 안정성을 위해 소송행위에는 민법상의 착오나 사기·강박, 비진의 등의 의사표시 규정을 그대로 적용하지 않는 것이 원칙이다. 이는 민사소송법이 민법과는 다른 독자적인 공법 체계를 구축하고 있음을 보여준다.

V. 결론

- 민사소송법은 사법(私法)상의 권리관계를 다루는 소송을 규율하지만, 그 법적 성격은 명백히 공법에 해당한다. 사법권(司法權)이라는 국가 통치권의 행사 절차를 규정하고 있으며, 법원이라는 국가기관과 소송 당사자 간의 관계를 규율하기 때문이다. 따라서 민사소송법은 국가 법 질서 내에서 공법 중에서도 절차법의 영역을 담당하며, 실체법인 민법을 실현하는 필수적인 보완 장치로서 기능한다. 결론적으로 민사소송법은 사법의 실현을 목적으로 하는 공법이라고 정의할 수 있다.

《【문제1.3-1】 소송법상 실효의 원칙에 대해 설명하시오. (25점)》

<문제1.3의 물음1> **소송법상 실효의 원칙의 의의, 신의칙과의 관계, 성립 요건, 적용 범위 및 소송법상 효과**

I. 소송법상 실효의 원칙의 의의 및 신의칙과의 관계

1. 소송법상 실효의 원칙의 의의

- 소송법상 실효의 원칙이란 권리자가 소송법상 권능을 행사할 수 있음에도 장기간 이를 행사하지 아니하여, 상대방에게 더 이상 그 권능을 행사하지 않을 것이라는 정당한 신뢰를 준 경우 그 후의 권리 행사를 허용하지 않는 원칙을 말한다. 이는 장기간 방치된 권리 행사를 차단함으로써 소송절차의 안정과 신속을 도모하는 데 취지가 있다.

2. 신의칙과의 관계

- 민사소송법 제1조 제2항은 당사자와 소송관계인이 신의에 따라 성실하게 소송을 수행하여야 한다는 신의성실의 원칙(이하 '신의칙')을 규정하고 있다. 소송법상 실효의 원칙은 이 신의칙의 파생 원칙인 모순행위금지의 원칙과 밀접한 관련이 있다. 과거의 불행사 상태와 모순되는 후행 소송행위를 제한함으로써 당사자 간의 신뢰를 보호하는 역할을 하기 때문이다.

II. 실효의 원칙의 성립 요건

1. 소송법상 권능의 장기간 불행사

(1) 소송상 권리·권능의 존재

- 실효의 대상이 되는 소송법상의 권능이 객관적으로 존재하고 있어야 하며, 권리자가 이를 행사할 수 있는 상태여야 한다.

(2) 상당한 기간의 경과

- 권리자가 소송상 권능을 행사할 수 있었음에도 불구하고 객관적으로 매우 장기간 동안 이를 행사하지 않고 방치하였어야 한다.

2. 상대방의 정당한 신뢰 형성

(1) 소송 상대방의 신뢰

- 권리자의 장기간에 걸친 권리 불행사로 인하여 소송 상대방에게 더 이상 해당 권능을 행사하지 않을 것이라는 신뢰가 형성되어 있어야 한다.

(2) 정당한 사유 및 객관적 사정

- 상대방이 그러한 신뢰를 가짐에 있어 정당한 사유가 있어야 하며, 객관적으로 신뢰를 가질 만한 사정 등이 배후에 뒷받침되어야 한다.

III. 적용 범위 및 소송법상 효과 (소송권능의 배척 또는 소각하)

1. 소송법상 실효의 원칙의 적용 범위

(1) 소송행위 및 소송법상의 권능

- 소송법상 이익권, 상소권, 소송 취소권 등 개별 소송행위에 원칙적으로 적용된다. 다만, 강행법규적 성격을 지닌 소송 요건이나 공익적 절차에는 신중하게 적용된다.

(2) 소제기 자체(소권)에의 적용

- 실체법상 권리에 기한 소제기 자체에도 실효의 원칙이 적용될 수 있다. 대법원은 근로자가 해고 후 아무런 이의 없이 퇴직금을 수령하고 수년이 지난 뒤에 제기한 해고무효확인 소 등에서 실효의 원칙을 적용하여 소를 부정한다.

2. 실효의 소송법상 효과

(1) 소송권능의 배척(실효)

- 요건이 충족되면 해당 소송행위의 권능은 실효되며, 그 후에 행해진 소송행위는 신의칙에 반하는 위법한 행위로서 법적 효력이 배척된다.

(2) 부적법 각하(소각하)

- 소제기 자체(소권)가 실효된 경우, 그 소송은 소송 요건을 흠결한 부적법한 소에 해당하므로 법원은 본안 심리를 하지 않고 판결로 소를 각하하여야 한다.

IV. 결론

- 소송법상 실효의 원칙은 소송 절차의 법적 안정성과 당사자의 신뢰 보호를 위해 필수적인 신의칙의 파생 원칙이다. 다만, 남용될 경우 헌법상 보장된 당사자의 재판청구권을 침해할 우려가 있으므로, 법원은 상당한 기간의 경과와 상대방의 정당한 신뢰 여부를 엄격하게 판정하여 예외적으로만 적용하여야 한다.

《【문제3.2】

<사례>

甲은 乙을 상대로 대여금 청구소송을 제기하였다. 이 사건의 제1심 판결은 판사 A가 담당하여 甲의 승소로 판결하였다. 이에 乙이 불복하여 항소하였고, 항소심 사건은 판사 A, B, C로 구성된 합의부에 배당되었다. 그런데 판사 A는 제1심 판결을 선고한 후 정기 인사발령에 의해 해당 항소심 재판부로 자리를 옮긴 상태였다.

한편, 항소심 진행 중 판사 B는 해당 사건의 원고인 甲과 고등학교 동창 사이이며, 최근 甲의 자녀 결혼식에 참석하여 축의금을 전달한 사실이 밝혀졌다. 이를 알게 된 乙은 판사 B가 재판의 공정성을 해칠 우려가 있다고 판단하여 기피신청을 하고자 한다.

또한, 판사 C는 이 사건의 목적물과 관련된 별개의 민사소송에서 과거에 甲의 대리인으로 활동하였던 경력이 있음이 확인되었다.

(물음1) 판사 A가 항소심 재판부의 구성원으로 참여하는 것이 민사소송법상 제척사유인 법관이 사건에 관하여 직무상 관여한 전심재판에 해당하는지 여부를 근거와 함께 논하시오.》

<문제3.2의 물음1> 법관이 제1심 판결 후 항소심 재판부 구성원으로 참여하는 것이 전심관여 제척사유에 해당하는지 여부

I. 문제의 제기

- 사안에서 제1심에서 원고 승소판결을 선고한 판사 A가 인사이동으로 동일 사건의 항소심 재판부 구성원이 되어 심리에 관여하게 된 상황이다. 쟁점으로 <제1심 판결을 담당한 법관이 항소심 재판부에 참여하는 것이 민사소송법상 전심재판에 직무상 관여한 경우에 해당하여 제척사유가 되는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 판사 A의 항소심 관여가 전심재판 관여를 이유로 한 제척사유에 해당하는지 논한다.

II. 법관의 제척사유와 전심관여

1. 제척제도의 의의 및 취지

- 제척은 법관이 구체적인 사건과 특수한 관계에 있어 재판의 공정성을 기대하기 어렵다고 판단되는 경우, 법률이 정한 객관적 사유에 기해 당연히 직무집행을 배제하는 제도다. 이는 재판의 공정성에 대한 외관상의 신뢰를 확보하고 불공정한 재판을 사전에 방지하는 데 목적이 있다.

2. 전심관여의 요건

- 민사소송법 제41조 제5호에 따른 제척이 성립하기 위해서는 다음의 요건을 충족해야 한다.

(1) 전심재판의 존재

- 전심재판이란 상급심의 심판 대상이 된 하급심의 재판을 의미한다. 즉, 항소심의 입장에서 제1심 재판은 전심재판이 된다.

(2) 직무상 관여

- 법관이 전심재판의 최종 판단인 판결의 성립이나, 그 기초가 되는 사실인정 및 법률판단에 실질적으로 관여했어야 한다.

(3) 사건의 동일성

- 당해 사건과 전심 사건이 동일한 사건이어야 한다. 사건번호가 다르더라도 실질적으로 동일한 분쟁을 다루는 경우라면 이에 해당한다.

III. 전심관여의 구체적 판단 기준

1. 판례의 태도

- 대법원은 제척사유인 전심관여를 엄격하게 해석한다. 판례는 최종변론과 판결의 합의에 관여하거나 종국 판결과 더불어 상급심의 판단을 받는 중간적인 재판에 관여함을 말하는 것이고, 최종변론 전의 변론, 증거조가, 기일지정과 같은 소송 지휘상의 재판 등에 관여한 경우는 포함되지 않는다고 판시한다.

2. 심급의 이익 보호

- 전심재판에 관여한 법관이 상급심 재판에 다시 참여하게 되면, 자신이 내린 선행 재판을 스스로 번복하기 어려울 것이라는 심리적 편견이 작용할 수 있다. 이는 당사자가 가지는 심급의 이익을 침해할 우려가 크므로, 헌법상 보장된 공정한 재판을 받을 권리를 보호하기 위해 이를 금지하는 것이다.

IV. 사안의 적용

1. 판사 A의 지위와 전심재판

- 사안에서 판사 A는 당해 사건의 제1심 판결을 담당하여 甲의 승소 판결을 직접 선고하였다. 이는 항소심의 심판 대상이 되는 전심재판에 해당하며, 판사 A는 판결의 핵심인 합의와 선고에 모두 참여한 자로서 실질적인 직무상 관여가 인정된다.

2. 제척사유의 성립 여부

- 항소심은 제1심의 당부를 판단하는 절차다. 판사 A가 항소심 재판부의 일원으로 참여하게 된다면, 乙이 제기한 항소 이유를 객관적으로 검토하기보다는 자신이 내린 제1심 판결의 정당성을 유지하려는 경향을 보일 가능성이 매우 높다. 이는 민사소송법 제41조 제5호가 금지하는 전형적인 전심관여의 사례다. 비록 정기 인사발령이라는 적법한 행정적 절차에 의해 항소심 재판부로 배속되었다 하더라도, 법관 개인의 신상 변화가 법률상 규정된 제척사유의 발생을 막지는 못한다.

V. 결론

- 판사 A는 제1심 판결이라는 전심재판에 실질적으로 관여한 법관이므로, 동일 사건의 항소심 재판부 구성원으로 참여하는 것은 민사소송법 제41조 제5호의 제척사유에 해당한다. 따라서 판사 A는 해당 항소심 사건의 직무집행에서 당연히 배제되어야 하며, 만약 판사 A가 참여한 상태에서 항소심 판결이 내려진다면 이는 절대적 상고이유인 판결 관여 불능 판사의 관여에 해당하여 파기 사유가 된다.

《【문제3.2】

<사례>

甲은 乙을 상대로 대여금 청구소송을 제기하였다. 이 사건의 제1심 판결은 판사 A가 담당하여 甲의 승소로 판결하였다. 이에 乙이 불복하여 항소하였고, 항소심 사건은 판사 A, B, C로 구성된 합의부에 배당되었다. 그런데 판사 A는 제1심 판결을 선고한 후 정기 인사발령에 의해 해당 항소심 재판부로 자리를 옮긴 상태였다.

한편, 항소심 진행 중 판사 B는 해당 사건의 원고인 甲과 고등학교 동창 사이이며, 최근 甲의 자녀 결혼식에 참석하여 축의금을 전달한 사실이 밝혀졌다. 이를 알게 된 乙은 판사 B가 재판의 공정성을 해칠 우려가 있다고 판단하여 기피신청을 하고자 한다.

또한, 판사 C는 이 사건의 목적물과 관련된 별개의 민사소송에서 과거에 甲의 대리인으로 활동하였던 경력이 있음이 확인되었다.

(물음2) 乙이 판사 B에 대하여 제기하려는 기피신청의 원인인 재판의 공정성을 기대하기 어려운 사정의 객관적 기준과 기피신청 시 소송절차의 정지 여부에 대하여 설명하시오.》

<문제3.2의 물음2> 기피원인인 재판의 공정성을 기대하기 어려운 사정의 객관적 기준과 기피신청 시 소송절차의 정지 여부

I. 문제의 제기

- 사안에서 항소심 재판부의 판사 B가 원고 甲과 고등학교 동창이고 최근 甲의 자녀 결혼식에 참석하여 축의금을 전달한 사실이 밝혀져 乙이 재판의 공정성을 이유로 기피신청을 하려는 상황이다. 쟁점으로 <민사소송법상 재판의 공정성을 기대하기 어려운 사정의 객관적 판단기준과 기피신청이 제기된 경우 소송절차의 정지 여부>를 검토할 필요가 있다. 이하에서는 판사 B에 대한 기피사유의 인정 여부와 기피신청에 따른 소송절차의 효력에 대해 설명한다.

II. 기피원인 : 재판의 공정성을 기대하기 어려운 사정

1. 의의 및 판례의 객관적 기준

(1) 의의

- 민사소송법 제43조 제1항은 법관에게 공정한 재판을 기대하기 어려운 사정이 있는 때에는 기피신청을 할 수 있다고 규정한다.

(2) 객관적 기준에 관한 판례의 태도★

- 판례는 재판의 공정성을 기대하기 어려운 사정이란 당사자가 주관적으로 불신감을 갖는 것만으로는 부족하고, 통상인의 판단에 의하더라도 법관이 편파적인 재판을 할 것이라는 의심을 가질 만한 객관적인 사정이 있는 경우를 의미한다고 본다. 즉, 법관과 당사자의 친분 관계, 원한 관계, 법관이 해당 사건의 승패에 직접적인 이해관계를 가졌다고 보일 만한 외관이 존재해야 한다.

2. 사안의 경우

- 판사 B가 원고 甲과 고교 동창이라는 사실이나 경조사에 참여하여 축의금을 전달한 사실은 한국 사회의 통상적인 사교례에 해당할 수 있다. 그러나 그 친분의 정도가 단순한 지인을 넘어 각별하여 재판 결과에 영향을 미칠 정도라면 객관적 기피사유가 될 수 있다. 다만, 실무상 단순한 동창 관계만으로는 기피신청이 인용되기 어려우며, 구체적으로 불공정한 재판 진행이 동반되어야 기피의 객관적 타당성이 인정될 것이다.

III. 기피신청과 소송절차의 정지

1. 원칙 : 소송절차의 정지

- 민사소송법 제48조 본문에 의하면 법원은 기피신청이 있는 경우 기피신청에 대한 재판이 확정될 때까지 소송절차를 정지하여야 한다. 이는 불공정한 재판을 받을 위험이 있는 상태에서 소송이 강행되는 것을 방지하기 위함이다. 정지되는 절차는 해당 기피 법관이 관여하는 모든 소송행위를 포함한다.

2. 예외 : 소송절차를 정지하지 않는 경우

- 소송의 지연을 목적으로 하는 무분별한 기피신청으로부터 재판의 효율성을 보호하기 위해 다음과 같은 예외를 둔다.

(1) 기피신청의 각하[민소법 제45조 제1항]

- 기피신청이 신청권을 남용하는 것이 명백하거나, 기합의된 기피신청 방식에 어긋나는 경우 등 요건을 갖추지 못한 때에는 원심법원이 결정으로 이를 각하할 수 있으며, 이 경우에는 절차를 정지하지 않는다.

(2) 종국판결의 선고

- 판례와 통설에 의하면, 변론이 종결된 후 판결만을 선고하는 단계에서는 기피신청이 있더라도 소송절차를 정지하지 않고 판결을 선고할 수 있다.

(3) 긴급을 요하는 행위

- 증거인멸의 우려가 있거나 기일을 늦출 경우 당사자에게 회복하기 어려운 손해가 발생할 우려가 있는 긴급한 행위는 절차 정지 중에도 예외적으로 허용된다.

IV. 절차 정지 위반의 효력

1. 절차 위반의 원칙적 효력

- 소송절차 정지 규정을 위반하여 진행된 소송행위는 원칙적으로 무효다. 따라서 기피신청 중 정지하지 않고 진행한 변론이나 증거조사 등은 효력이 없다.

2. 하자의 치유

- 기피신청이 최종적으로 기각 확정된 경우에는 절차 정지 규정을 위반하여 행한 소송행위라도 그 하자가 치유되어 유효한 것으로 간주된다. 이는 기결정된 기각 재판을 존중하여 소송 경제를 도모하기 위함이다.

V. 결론

- 乙이 판사 B에 대하여 제기하려는 기피신청은 통상인의 관점에서 공정성을 의심할 만한 객관적 사정이 입증되어야 한다. 기피신청이 접수되면 법원은 원칙적으로 소송절차를 정지해야 하며, 예외적으로 신청이 명백히 부적법하여 각하되는 경우나 긴급한 행위 등이 아닌 한 재판을 계속해서 안 된

다. 만약, 법원이 절차를 정지하지 않고 재판을 강행하였으나 이후 기피신청이 기각된다면 그 소송행위의 하자는 치유되나, 기피신청이 인용된다면 해당 소송행위는 무효가 된다.

《【문제3.2】

<사례>

甲은 乙을 상대로 대여금 청구소송을 제기하였다. 이 사건의 제1심 판결은 판사 A가 담당하여 甲의 승소로 판결하였다. 이에 乙이 불복하여 항소하였고, 항소심 사건은 판사 A, B, C로 구성된 합의부에 배당되었다. 그런데 판사 A는 제1심 판결을 선고한 후 정기 인사발령에 의해 해당 항소심 재판부로 자리를 옮긴 상태였다.

한편, 항소심 진행 중 판사 B는 해당 사건의 원고인 甲과 고등학교 동창 사이이며, 최근 甲의 자녀 결혼식에 참석하여 축의금을 전달한 사실이 밝혀졌다. 이를 알게 된 乙은 판사 B가 재판의 공정성을 해칠 우려가 있다고 판단하여 기피신청을 하고자 한다.

또한, 판사 C는 이 사건의 목적물과 관련된 별개의 민사소송에서 과거에 甲의 대리인으로 활동하였던 경력이 있음이 확인되었다.

(물음3) 판사 C의 경우와 같이 제척사유가 있음에도 불구하고 법관이 스스로 직무집행을 피하는 제도인 회피의 절차와 효과에 대하여 기술하시오.》

<문제3.2의 물음3> 제척사유가 있는 법관이 스스로 직무집행을 피하는 회피의 절차와 효과

I. 문제의 제기

- 사안에서 판사 C는 이 사건의 목적물과 관련된 별개의 민사소송에서 과거 甲의 대리인으로 활동한 경력이 있어 제척사유의 존재를 전제로 스스로 직무집행을 피하는 회피가 문제되는 상황이다. 쟁점으로 <민사소송법상 법관의 회피가 인정되는 절차와 회피가 허가된 경우 발생하는 절차적 효력>을 검토할 필요가 있다. 이하에서는 판사 C의 회피 절차와 그에 따른 효과에 대하여 기술한다.

II. 회피의 의의 및 요건

1. 회피의 의의

- 회피는 법관이 자기에게 제척 또는 기피의 사유가 있다고 인정하는 때에 스스로 당해 사건의 직무집행을 피하는 것을 말한다. 이는 법관의 양심과 명예를 존중하고, 불필요한 기피신청 절차를 생략하여 소송의 경제와 재판의 신뢰를 도모하는 데 목적이 있다.

2. 회피의 요건

- 법관은 자신에게 민사소송법 제41조(제척의 이유) 또는 제43조(당사자의 기피권)에 해당하는 사유가 있다고 판단될 때 회피할 수 있다. 사안의 판사 C와 같이 과거에 당사자의 대리인이었거나 사건에 실질적으로 관여한 바가 있다면, 이는 객관적으로 재판의 공정성을 의심받을 수 있는 상황이므로 회피의 요건을 충족한다.

III. 회피의 절차

1. 회피의 신청

- 법관은 회피하고자 하는 경우 소속 법원에 회피의 뜻을 표시하여야 한다. 이때 회피의 사유를 서면으로 소명하는 것이 원칙이다. 기피신청과 달리 당사자의 청구에 의하는 것이 아니라 법관의 자발적 의사에 의해 개시된다는 점에 특징이 있다.

2. 감독법원의 허가

- 회피는 법관이 임의로 결정하는 것이 아니라, 법원(감독법원)의 허가를 받아야 한다. 민사소송법 제49조는 감독권이 있는 법원의 허가를 받아 회피할 수 있다고 규정하고 있다. 이는 법관이 자의적으로 재판을 기피하는 것을 방지하고 재판부 구성의 안정성을 유지하기 위함이다.

IV. 회피의 효과

1. 직무집행의 배제

- 회피 신청에 대하여 법원의 허가 결정이 내려지면, 해당 법관은 당해 사건에 관한 모든 직무집행에서 배제된다. 이후 해당 사건은 법원의 사무분담에 따라 다른 법관이나 재판부로 재배당된다.

2. 소송행위의 효력

(1) 허가 결정 전의 행위

- 회피 사유가 있음에도 허가 결정이 내려지기 전에 해당 법관이 행한 소송행위는 당연히 무효가 되는 것은 아니다. 다만, 제척사유가 있는 법관이 관여한 경우라면 이후 상소나 재심의 사유가 될 수 있다.

(2) 허가 결정 후의 행위

- 회피 허가 결정이 내려진 후에 해당 법관이 행한 소송행위는 직무권한 없는 자의 행위로서 무효가 된다.

3. 소송절차의 정지 여부

- 기피신청의 경우에는 법률상 절차 정지 규정이 명시되어 있으나, 회피는 법관의 자발적 신청과 법원의 내부적 허가 절차로 진행되므로 기피와 같은 엄격한 절차 정지 규정은 없다. 그러나 실무적으로는 회피 신청이 접수되면 허가 여부가 결정될 때까지 해당 사건의 심리를 중단하는 것이 통례다.

V. 결론

- 사안의 판사 C는 과거 甲의 대리인으로 활동한 경력이 있어 제척사유에 해당하므로, 스스로 회피 신청을 하는 것이 타당하다. 판사 C가 소속 법원에 회피 신청을 하여 허가 결정을 받으면 해당 사건의 재판부에서 적법하게 제외된다. 이러한 회피 제도는 당사자의 기피신청에 따른 불필요한 감정 대립이나 소송 지연을 막고, 법관 스스로 재판의 공정성을 확보하게 함으로써 사법 제도에 대한 국민의 신뢰를 높이는 중요한 기능을 수행한다.

《【문제3.2-4】 법관의 기피제도에 대해 설명하시오. (25점)》

<문제3.2의 물음4> 법관의 기피제도의 의의 및 제척제도와와의 구별, 기피사유, 절차 및 원칙, 남용과 간이각하결정

I. 법관 기피제도의 의의 및 제척제도와와의 구별

1. 법관 기피제도의 의의

- 법관 기피제도란 법관에게 법률이 정한 제척사유가 없음에도 불구하고 재판의 공정성을 기대하기 어려운 객관적인 사정이 있는 경우, 당사자의 신청에 의하여 그 법관을 해당 사건의 직무집행에서 배제하는 소송법상 제도를 의미한다.

2. 제척제도와와의 구별

(1) 법정 사유

- 제척은 법률이 정한 구체적이고 객관적인 배제 사유가 있는 경우에 법관이 당연히 직무집행에서 배제되는 제도인 반면, 기피는 법정 제척 사유 이외에 재판의 공정성을 우려할 만한 객관적 사정이 존재할 때 당사자의 신청을 통해 배제되는 제도라는 점에서 구별된다.

(2) 직무 배제

- 제척은 별도의 신청 없이도 법률상 당연히 직무배제의 효력이 발생하는 데 반해, 기피는 반드시 당사자의 명시적인 신청과 이에 대한 다른 법관(또는 법원)의 구체적인 결정 재판이 있어야만 법적인 효력이 발생한다.

II. 기피사유 (재판의 공정을 기대하기 어려운 사정의 의미)

1. 객관적 사정의 의미

- 대법원은 재판의 공정을 기대하기 어려운 사정이란 당사자가 주관적으로 법관의 불공정을 우려하는 사정을 뜻하는 것이 아니라고 본다. 이는 통상인의 판단을 기준으로 하여, 객관적으로 법관과 사건의 관계나 친분 혹은 원한 등으로 인해 불공정한 재판을 할 것이라는 의심을 품을 만한 객관적·합리적인 사정이 배후에 존재하는 경우를 의미한다.

2. 당사자의 주관적 불복과의 구별

- 따라서 법관의 소송지휘나 증거채택 여부에 대한 단순한 불만, 당사자의 주관적인 의심 등은 기피사유에 해당하지 않는다. 기피사유는 제도를 무분별하게 남용하려는 의도를 억제하기 위하여 객관적이고 구체적인 사실에 의해 입증되는 범위 내로 엄격하게 한정 적용되어야 한다.

III. 기피신청의 절차 및 소송절차의 정지 원칙

1. 기피신청의 절차

(1) 신청의 방식 및 관할

- 당사자는 기피하고자 하는 법관의 소속 법원에 신청서를 제출하여 서면으로 신청하는 것이 원칙이다. 다만, 소송기일에는 법정에서 구술로도 신청할 수 있다.

(2) 신청의 시기

- 기피신청은 본안에 대하여 변론하거나 법관에게 질문을 받기 전에 제기하여야 한다. 다만, 변론 개시 후에 기피사유가 새로 발생하였거나 그 사유의 존재를 사후에 알게 된 경우에는 변론 중에도 신청이 가능하다.

2. 소송절차의 정지 원칙 [민사소송법 제48조]

(1) 정지 의무의 원칙적 강행성

- 민사소송법 제48조 본문에 따라 법관에 대한 기피신청이 접수되면 법원은 기피신청에 대한 재판이 확정될 때까지 원칙적으로 소송절차를 정지하여야 한다. 이는 기피당한 법관이 편파적인 심리를 속행하는 행위를 차단하기 위한 강행규정이다.

(2) 정지 원칙의 합리적 예외

- 소송의 지연을 목적으로 함이 명백한 기피신청이거나 긴급을 요하는 경우, 그리고 이미 변론이 종결되어 종국판결을 선고하는 경우에 해당할 때에는 소송절차를 정지하지 아니하고 심리를 진행할 수 있다.

IV. 기피신청의 남용과 간이각하결정

1. 기피신청 남용의 방지 필요성

- 기피제도는 공정한 재판을 위한 헌법상 보장 장치이나, 소송 당사자가 패소 판결을 늦추거나 재판부를 압박하기 위한 소송 지연의 수단으로 악용하는 부작용이 발생한다. 소송경제와 신속한 재판의 원칙을 수호하기 위해 이러한 남용 행위를 규제할 장치가 수반되어야 한다.

2. 간이각하결정 제도

(1) 주체 및 대상

- 기피신청이 단지 소송을 지연시킬 목적이 객관적으로 명백한 경우, 신청을 받은 해당 법원 또는 법관은 변론을 정지하지 않고 결정으로 기피신청을 즉시 각하할 수 있다.

(2) 법적 효과

- 간이각하결정이 내려지는 사안은 소송정지 의무를 발생시키지 않으므로, 법원은 본안사건의 심리 및 변론을 중단 없이 원활하게 속행할 수 있어 소송의 불필요한 지연을 예방한다.

V. 결론

- 법관 기피제도는 재판의 객관적 신뢰성과 당사자의 공정한 재판을 받을 권리를 실질적으로 보호하는 소송법상의 안전장치이다. 기피신청이 있는 경우 소송절차를 정지하도록 한 민사소송법 제48조의 강행규정은 이러한 가치를 보장하기 위한 핵심 원칙이다. 다만, 이를 소송 지연 전술로 악용하는 남용 행위로부터 사법 신뢰를 보호하기 위해, 법원은 객관적 판단 기준을 엄격히 고수하는 한편 악의적인 남용에 대해서는 간이각하 제도를 엄정하게 적용하여 법적 안정성과 소송의 신속을 조화롭게 도모해야 한다.

《【문제4.1】

<사례>

甲은 乙에게 1억 원을 대여하였다고 주장하며 소를 제기하고자 한다. 그런데 甲은 乙의 인적 사항을 정확히 알지 못하자, 평소 원한 관계에 있던 丙의 성명을 乙의 성명으로 기재하고 丙의 주소를 피고의 주소로 기재하여 소장을 제출하였다. 소장 부분을 송달받은 丙은 자신은 甲과 아무런 채권채무 관계가 없으므로 당황하였으나, 일단 법정에 출석하여 피고로서 답변하고 소송을 수행하였다.

甲이 丙의 성명을 모용하여 소를 제기한 경우, 이 소송의 당사자가 누구인지 확정하는 기준에 대하여 판례의 태도를 중심으로 기술하고, 만약 丙을 상대로 판결이 선고되어 확정되었다면 丙이 취할 수 있는 구제 수단을 논하시오.》

<문제4.1> 성명모용소송에서 당사자 확정 기준 및 피모용자의 구제 수단

I. 문제의 제기

- 사안에서 甲은 실제 채무자인 乙이 아닌 丙의 성명과 주소를 피고로 기재하여 소를 제기하였고, 丙은 소송에 출석하여 피고로서 소송을 수행한 후 판결이 확정될 수 있는 상황이다. 쟁점으로 <성명모용에 의한 소송에서 당사자를 확정하는 기준과 모용된 자를 상대로 판결이 확정된 경우 그에 대한 구제 수단>을 검토할 필요가 있다. 이하에서는 당사자확정의 기준과 丙이 취할 수 있는 구제수단에 대해 논한다.

II. 당사자 확정의 기준

1. 학설의 태도

(1) 의사설

- 원고가 당사자로 삼으려고 하는 자가 당사자라는 견해다.

(2) 표시설

- 소장의 기재나 표시를 기준으로 당사자를 결정해야 한다는 견해다.

(3) 행동설

- 소송에서 당사자로서 행동하거나 당사자로 취급된 자가 당사자라는 견해다.

(4) 규범적 분류설(판례)

- 소장의 기재를 기초로 하되, 전후 문맥을 살펴 합리적으로 해석하여 당사자를 확정해야 한다는 견해다.

2. 판례의 구체적 입장

- 판례는 원칙적으로 소장의 기재를 기준으로 당사자를 확정하나, 성명모용소송과 같이 표시된 성명과 실질적인 당사자가 일치하지 않는 경우에는 소장에 나타난 모든 기재와 보충적 자료를 종합하여 누가 당사자로 확정되는지를 판단한다. 사안과 같이 원고가 실제로는 乙을 상대로 소를 제기할 의사였으나 丙의 성명과 주소를 기재한 경우, 소장의 전취지와 소송의 경과를 고려하여 실질적인 피고를 乙로 볼 것인지 아니면 표시된 丙으로 볼 것인지 결정하게 된다.

III. 성명모용소송의 효력 및 절차

1. 소송계속 중의 처리

- 성명모용 사실이 발견되면 법원은 피고의 표시를 모용자(실질적 피고 乙)로 정정하도록 명해야 한다. 만약 모용당한 피모용자 丙이 소송에 관여하고 있다면 丙을 소송에서 배제하고 乙을 소송에 참여시켜야 한다.

2. 판결 선고 전의 지위

- 피모용자 丙은 실질적인 당사자가 아니므로, 丙을 상대로 판결을 내려서는 안 된다. 만약 丙이 출석하여 답변하였다 하더라도 이는 당사자 아닌 자의 소송행위로서 효력이 없는 것이 원칙이다.

IV. 피모용자의 구제 수단

1. 판결 확정 전의 구제 : 항소 및 상고

- 판결이 선고되었으나 아직 확정되지 않은 상태라면, 피모용자 丙은 자신에 대하여 판결이 선고된 것과 같은 외관을 제거하기 위하여 항소를 제기할 수 있다. 상급심 법원은 丙이 당사자가 아님을 이유로 원심판결을 취소하고 丙을 소송에서 탈퇴시켜야 한다.

2. 판결 확정 후의 구제

(1) 재심의 소(민사소송법 제451조 제1항 제3호 준용)

- 판례는 성명모용소송에서 피모용자가 자신도 모르는 사이에 판결이 확정된 경우, 민사소송법 제451조 제1항 제3호의 대리권의 흠결을 유추적용하여 재심의 소를 제기할 수 있다고 본다. 이는 피모용자가 자신의 의사와 무관하게 소송 절차에 관여하지 못한 채 판결의 불이익을 입게 된 것을 구제하기 위함이다.

(2) 판결의 당연무효 주장

- 성명모용판결은 실질적 당사자가 아닌 자를 상대로 한 것이므로 당연무효라는 견해도 있으나, 판례는 판결의 외관이 존재하는 이상 재심 절차 등을 통해 그 효력을 다투어야 한다는 입장이다. 따라서 丙은 확정판결의 기판력을 제거하기 위해 재심을 제기하는 것이 가장 확실한 방법이다.

V. 사안의 적용

1. 당사자의 확정

- 사안에서 甲은 乙을 피고로 삼으려 하였으나 표시를 丙으로 하였고, 丙이 실제로 법정에 출석하여 소송을 수행하였다. 판례의 규범적 분류설에 의하면 표시된 丙이 일단 피고로 확정된다. 그러나 甲의 진정한 의사가 乙을 향하고 있었다면 이는 피고 표시의 잘못에 해당하므로 피고표시정정 절차를 거쳐야 한다.

2. 丙의 구제

- 丙은 이미 법정에 출석하여 소송을 수행하였으므로 판결의 결과에 직접적인 영향을 받게 된다. 만약 丙을 피고로 하는 판결이 확정되었다면, 丙은 대리권 흠결을 이유로 한 재심의 소를 제기하여 자신에 대한 판결의 효력을 부정할 수 있다.

Ⅴ. 결론

- 성명모용소송에서 당사자는 원칙적으로 소장에 기재된 표시를 기준으로 확정되나 실질적 당사자가 누구인지에 따라 정정의 대상이 된다. 丙과 같이 성명을 모용당하여 확정판결을 받은 자는 대리권 흠결에 관한 재심 규정을 준용하여 재심의 소를 제기함으로써 구제받을 수 있다.

<제2편 소송의 주체.제04장 당사자.제02절 당사자의 자격>

[예상][4.02-1]당사자능력과 당사자적격의 비교

《【문제4.2】 당사자능력과 당사자적격에 대해 설명하시오.》

<문제4.2> 당사자능력과 당사자적격의 비교

I. 문제의 제기

- 민사소송이 적법하게 개시되고 진행되기 위해서는 소송의 주체인 당사자가 일정한 요건을 갖추어야 한다. 이를 당사자 조건이라 하며, 대표적으로 당사자능력과 당사자적격이 있다. 두 개념은 모두 소송요건에 해당하여 법원의 직권조사사항이라는 공통점이 있으나, 그 자격의 성질과 구체적인 판단 기준에서 명확히 구분된다. 실무상 이를 혼동할 경우 소송 요건의 흠결로 소각하 판결을 받게 되므로 명확한 구별이 필수적이다. 이하에서는 당사자능력과 당사자적격의 정의와 구체적 분류, 양자의 구별 실익에 대하여 설명한다.

II. 당사자능력의 개념 및 법적 성격

1. 당사자능력의 정의

- 당사자능력이란 소송의 당사자(원고 또는 피고)가 될 수 있는 추상적·일반적인 자격을 의미한다. 이는 실체법상 민법의 권리능력에 대응하는 소송법상의 개념이다. 따라서 권리를 가질 수 있는 자는 당연히 소송의 당사자가 될 수 있는 자격을 가진다.

2. 당사자능력자의 범위

(1) 자연인과 법인

- 모든 자연인(외국인, 미성년자 포함)과 법인은 권리능력을 가지므로 당연히 당사자능력을 가진다. 태아의 경우 민법상 개별 규정에 의해 권리능력이 인정되는 범위 내에서 예외적으로 소송법상 당사자능력이 인정될 수 있다.

(2) 비법인 사단·재단(민사소송법 제52조)

- 민법상 권리능력은 없으나 사단 또는 재단으로서의 실체를 갖추고 대표자나 관리인이 지정되어 있는 경우, 소송법상 예외적으로 당사자능력을 인정한다. 종종, 동창회, 아파트 입주자대표회의 등이 이에 해당한다.

(3) 민법상 조합의 예외

- 민법상 조합은 사단성이 결여되어 원칙적으로 당사자능력이 부정되며, 조합원 전원이 공동소송인으로 참여하여야 한다.

III. 당사자적격의 개념 및 법적 성격

1. 당사자적격의 정의

- 당사자적격이란 특정한 소송물에 대하여 원고(원고적격) 또는 피고(피고적격)로서 소송을 수행하고 판결을 받을 수 있는 구체적·개별적인 자격을 의미한다. 당사자능력이 소송에 참여할 수 있는 기본 자격이라면, 당사자적격은 당해 특정 재판의 당사자로서 적합한 자격이다.

2. 적격의 판단 기준

(1) 일반적 기준(관리처분권)

- 주로 실체법상의 권리관계에 기하여 결정된다. 즉, 소송의 대상이 된 권리나 법률관계의 주체인 자가 당사자적격을 갖는다. 이행의 소에서는 원고가 자기에게 권리가 있다고 주장하는 자가 원고적격을 갖고, 그로부터 이행을 청구받은 자가 피고적격을 갖는 것이 원칙이다.

(2) 제3자의 소송담당

- 실체법상 권리 주체가 아님에도 불구하고 법률의 규정(예 : 채권자대위소송에서의 채권자)이나 당사자의 지정에 의해 제3자가 당사자적격을 취득하여 소송을 수행하는 예외적인 형태가 존재한다.

IV. 두 개념의 주요 차이점 비교

1. 추상적 자격과 구체적 자격의 차이

- 당사자능력은 당해 사건의 내용과 무관하게 누가 소송의 주체가 될 수 있는가에 관한 추상적인 자격이다. 반면, 당사자적격은 특정 사건에 대하여 누가 재판을 이끌어갈 책임자인가를 묻는 구체적인 자격이다. 예를 들어, 자연인 A는 당사자능력을 언제나 가지지만, 타인의 채무 관계에 관한 소송에서는 당사자적격이 없다.

2. 실체법적 대응 개념의 차이

(1) 당사자능력

- 민법의 권리능력에 대응한다.

(2) 당사자적격

- 민법상의 소유권이나 채권 등 관리처분권과 대응한다. 따라서 재산의 처분 권한이 제한된 파산관재인 등은 원래 소유자가 당사자능력이 있음에도 불구하고 법률에 의해 당사자적격을 독점하게 된다.

3. 흠결 시 효과와 소송절차상의 차이

(1) 당사자능력의 흠결

- 소송 제기 당시 당사자능력이 없는 자(예 : 사망자, 존재하지 않는 단체)를 당사자로 삼은 경우, 원칙적으로 보정이 불가능하며 법원은 소를 각하하여야 한다. 다만 당사자 표시정정 등으로 해결할 수 있는 예외적 범위가 좁게 인정된다.

(2) 당사자적격의 흠결

- 소송 도중 당사자적격이 없는 자가 소를 제기한 것이 밝혀지면 역시 소각하 판결을 내린다. 그러나 임의적 당사자변경이나 소송인수, 소송참가 등의 소송법적 장치를 통해 적격이 있는 자로 당사자를 교체하거나 보정할 수 있는 여지가 당사자능력에 비해 상대적으로 넓다.

V. 관련 판례 및 실무적 적용

1. 사망자를 피고로 한 소송

- 판례는 소 제기 전에 이미 사망한 자를 피고로 하여 소를 제기한 경우, 그 소송은 당사자능력이 없는 자를 상대로 한 것이므로 부적법하여 각하되어야 한다고 본다. 다만, 소 제기 후에 사망한 경우에는 소송절차가 중단되며 상속인이 소송을 수계하는 형태로 진행되므로 구별이 필요하다.

2. 사단법인의 분열과 당사자적격

- 종중이나 교회 등이 분열되어 소송이 발생한 경우, 판례는 당해 법률관계에 대한 총유재산의 관리처분권이 누구에게 있는지를 기준으로 구체적인 당사자적격을 판단한다. 단순히 단체의 회원이라는 사정만으로는 대표하여 소송을 제기할 당사자적격이 인정되지 않는다.

Ⅵ. 결론

- 당사자능력과 당사자적격은 민사소송의 적법성을 담보하는 이중의 필터 역할을 한다. 당사자능력은 소송을 시작할 수 있는 인적·조직적 주체로서의 그릇을 심사하는 단계이며, 당사자적격은 그 그릇이 해당 분쟁에 합당한 실체적 권리 주체인지를 가리는 단계이다. 소송 실무에서는 원고와 피고를 지정할 때 이 두 가지 요건이 모두 충족되었는지를 면밀히 검토함으로써 무익한 절차의 반복이나 소각하 판결의 위험을 사전에 방지하여야 한다.

<제2편 소송의 주체.제04장 당사자.제02절 당사자의 자격>

[예상][4.02-2]소송상 당사자적격의 의의 및 당사자능력과의 구별, 권리주체, 소송법상 성질, 흠결 효과

《【문제4.2-2】 소송상 당사자적격에 대해 설명하시오. (25점)》

<문제4.2의 물음2> 소송상 당사자적격의 의의 및 당사자능력과의 구별, 권리주체, 소송법상 성질, 흠결 효과

I. 당사자적격의 의의 및 당사자능력·의사능력과의 구별

1. 당사자적격의 의의

- 당사자적격이란 특정의 소송물에 대하여 원고 또는 피고로서 소송을 수행하고 본안판결을 받기에 적합한 자격을 말한다. 소송을 수행할 수 있는 원고로서의 자격을 원고적격, 피고로서의 자격을 피고적격이라 한다.

2. 당사자능력 및 의사능력(소송능력)과의 구별

(1) 당사자능력과의 구별

- 당사자능력은 소송의 주체가 될 수 있는 일반적·추상적 능력을 의미하므로, 구체적 소송물과의 관계를 전제로 하는 개별적·구체적 자격인 당사자적격과 구별된다.

(2) 의사능력과의 구별

- 의사능력(소송법상 소송능력)은 스스로 유효하게 소송행위를 하거나 받을 수 있는 행위능력을 의미하므로, 소송물의 주체로서 소송을 수행할 자격인 당사자적격과 구별된다.

II. 당사자적격을 가지는 자 (원칙적 권리주체 및 제3자 소송담당)

1. 원칙적 권리주체

(1) 원고적격과 피고적격

- 이행의 소에서는 스스로 권리자라 주장하는 자에게 원고적격이, 의무자라 지정된 자에게 피고적격이 인정된다. 확인의 소에서는 확인의 이익을 가진 자에게 원고적격이 인정되며, 형성의 소에서는 법률이 규정한 자에게 적격이 인정된다.

(2) 주장 자체에 의한 결정

- 당사자적격의 유무는 원고의 주장 자체를 기준으로 판단하며, 실제로 그 권리·의무가 존재하는지는 본안심리 단계에서 판단할 문제이다.

2. 예외적 주체 (제3자 소송담당)

(1) 의의 및 종류

- 제3자 소송담당이란 권리관계의 주체가 아닌 제3자가 자기의 이름으로 소송을 수행할 수 있는 권능을 가진 경우를 말한다. 법률의 규정에 의해 부여되는 법정소송담당(채권자대위소송 등)과 권리주체의 의사에 기한 임의적 소송담당(선정당사자 등)이 있다.

(2) 판결의 효력

- 소송담당자가 판결을 받으면 그 기판력은 소송의 당사자가 아닌 실질적 권리관계의 주체인 본인에게도 미치게 된다.

III. 당사자적격의 소송법상 성질 및 조사 시기

1. 소송법상 성질

- 당사자적격은 법원이 본안심리를 하기 위해 갖추어야 할 소송요건 중 당사자에 관한 요건이다. 이는 공익적 성격을 가지므로 원칙적으로 강행규정에 해당한다.

2. 조사 시기 및 판단 기준

(1) 법원의 직권조사사항

- 소송요건이므로 피고의 항변을 기다리지 않고 법원이 소송의 모든 단계에서 직권으로 조사하여야 한다.

(2) 판단의 기준 시점

- 당사자적격의 존부는 사실심 변론종결 시를 기준으로 판단한다. 소 제기 당시에 적격이 없었더라도 사실심 변론종결 전까지 이를 구비하면 하자는 치유된다.

IV. 당사자적격 흠결의 소송법상 효과

1. 본안심리 거부 및 소각하 판결

- 법원은 소송요건인 당사자적격이 흠결된 경우, 본안에 대해 판단하지 않고 판결로 소를 부적법 각하하여야 한다.

2. 하자의 보정 및 하자 간과 판결의 효력

(1) 하자의 보정 가능성과 한계

- 당사자적격의 흠결은 원칙적으로 보정할 수 없는 요건이다. 다만, 단순한 오기를 정정하는 동일성 범위 내의 당사자표시정정은 허용되나, 전혀 다른 자로 당사자를 바꾸는 임의적 당사자변경은 원칙적으로 허용되지 않는다.

(2) 간과 판결의 효력 및 구제

- 적격 흠결을 간과한 판결은 상소를 통해 취소할 수 있으나, 재심사유에는 해당하지 않으므로 판결이 확정되면 그 효력은 유효하다.

V. 결론

- 당사자적격은 정당한 당사자에게 본안판결을 내림으로써 사법 자원의 낭비를 방지하고 실질적 권리구제를 도모하는 핵심적인 소송요건이다. 법원은 직권조사를 통해 당사자적격 유무를 엄격히 심사하되, 제3자 소송담당 제도 등을 조화롭게 운영하여 국민의 재판청구권을 보장하여야 한다.

<제2편 소송의 주체.제04장 당사자.제03절 소송상의 대리인>

[예상][4.03-1]특별수권사항의 의의, 구체적 범위, 특별수권없는 대리의 효력

《【문제4.3-1】특별수권사항에 대해 설명하시오. (25점)》

<문제4.3의 물음1> 특별수권사항의 의의, 구체적 범위, 특별수권없는 대리의 효력

I. 소송대리권 범위의 법정주의와 특별수권사항의 의의

1. 소송대리권 범위의 법정주의 [민사소송법 제90조 제1항]

- 소송법상 소송대리인의 권한 범위를 전적으로 사적 계약에만 의존하게 하면 소송 상대방이 예상치 못한 불이익을 입기 쉽고, 소송절차의 확실적·안정적인 진행을 해치게 된다. 따라서 우리 민사소송법은 소송대리인의 권한 범위를 법률로 획일화하여 직접 규정하는 법정주의를 채택하고 있다.

2. 특별수권사항의 의의

- 소송대리인 은 위임받은 소송에 대하여 소의 제기나 화해 등 일체의 소송행위를 할 수 있는 일반적 대리권을 가진다. 다만, 소송물의 처분이나 소송의 종료 등 본인의 실체적 권리관계에 심대한 영향을 미치는 특정 소송행위에 대해서는 본인의 명시적이고 개별적인 권한 수여를 요구하는데, 이를 특별수권사항이라 한다.

II. 구체적 특별수권사항의 범위

1. 소송의 개시·종결 등에 관한 사항 [민소법 제90조 제2항 제1호·제2호]

- 본인의 적극적인 의사 결정 및 처분의사가 필수적인 항목들로서, 반소의 제기, 소의 취하, 화해, 청구의 포기·인낙, 독립당사자참가소송탈퇴를 하려면 특별수권을 별도로 받아야 한다.

2. 대리인 선임 및 상소 등에 관한 사항 [민소법 제90조 제2항 제3호·제4호]

- 소송대리인이 자신이 가진 대리권에 기초하여 다른 대리인을 선임하는 복대리인의 선임, 심급을 이동시키거나 소송을 종료시키는 상소의 제기 또는 취하, 대리인의 선임을 하는 경우에도 반드시 특별수권이 존재하여야 한다.

III. 특별수권 없는 대리행위의 효력 및 본인의 추인 가부

1. 특별수권 없는 대리행위의 효력

(1) 원칙

- 특별수권이 결여된 채 이루어진 소송대리인의 소송행위는 소송법상 무권대리행위가 되어 원칙적으로 무효이다.

(2) 간과 판결 효과

- 다만, 이러한 하자를 법원이 간과하고 본안판결을 선고한 경우, 판결이 확정되기 전에는 상소(항소 및 상고)를 제기하여 판결을 취소할 수 있고 판결이 이미 확정되었다면 재심의 소를 제기하여 구제받을 수 있다.

2. 본인의 추인 가부

(1) 추인의 소급효와 요건

- 민사소송법 제97조가 제60조를 준용하여 무권대리인의 소송행위라도 소송경제 및 당사자의 이익을 위해 본인이 사후에 추인하는 것을 허용한다. 본인의 적법한 추인이 있으면 무권대리 소송행위는 행해진 시점으로 소급하여 대리권이 있었던 것과 동일하게 유효해진다.

(2) 추인의 방식 및 시기적 한계

- 추인의 방식은 반드시 서면이나 명시적 언동으로만 해야 하는 것은 아니며, 무권대리 소송행위의 결과를 묵묵히 받아들이는 등의 묵시적 방식으로도 가능하다. 추인을 할 수 있는 시기는 소송절차의 안정을 지나치게 해치지 않는 한 판결이 확정되기 전까지이며, 사실심은 물론 상고심에서도 자유롭게 추인할 수 있다.

IV. 결론

- 소송대리권 범위의 법정주의 체제 하에서 특별수권사항은 대리인의 독단적인 권리 처분 행위로부터 소송당사자 본인의 실질적 이익을 두텁게 보호하기 위한 법률상의 안전망이다. 따라서 법원은 소송절차의 정당성과 사법 신뢰를 확보하기 위해 대리권의 존부 및 특별수권 구비 여부를 직권으로 엄격하게 조사하여야 한다. 다만, 절차적 흠결이 발생한 대리행위에 대해서는 사후 추인 제도를 유연하게 조화시킴으로써 불필요한 소송 지연을 막고 사법자치를 조화롭게 실현하여야 할 것이다.

<제3편 제1심의 소송절차.제05장 소송 개시와 심리 대상.제02절 소송요건>
[예상][5.02-1]부제소특약의 간과와 본안기각판결 선고의 적법성 및 그 효력

《【문제5.2】

<사례>

甲은 乙을 상대로 1억 원의 대여금 청구소송을 제기하였다. 제1심 소송 계속 중, 피고 乙은 甲과 소를 제기하기 전에 이미 이 사건 분쟁에 대하여 법원에 소를 제기하지 않기로 합의(부제소특약)를 하였으므로 이 사건 소는 부적법하다고 주장하며 소각하를 청구하였다. 그러나 제1심 법원은 부제소특약의 존재 여부 및 그 적법성에 대해 구체적으로 심리하지 아니한 채, 변론기일을 열어 곧바로 대여금 채권의 성립 여부 등 본안에 관한 심리를 진행하였다. 제1심 법원은 심리 결과 대여금 채권이 시효로 소멸하였다는 이유로 甲의 청구를 기각하는 본안판결을 선고하였고, 甲은 이에 불복하여 항소하였다. 한편, 또 다른 사건에서 원고 A는 피고 B를 상대로 손해배상 청구소송을 제기하여 심리가 진행 중이다. 그런데 소송 계속 중 B는 A가 정신적 질환으로 인해 의사능력을 완전히 상실하였으므로 당사자능력에 흠결이 발생하였다고 주장하였다. 제1심 법원은 이러한 당사자능력과 같은 소송요건의 존재 여부를 어느 시점을 기준으로 판단해야 하는지, 그리고 해당 소송요건의 존부에 대한 증명책임은 소송법상 누구에게 귀속되는지 검토하고 있다.

(물음1) 피고 乙이 부제소특약의 합의가 존재한다고 주장하였음에도 제1심 법원이 소송요건의 존부를 판단하지 않고 본안기각판결을 선고한 조치의 적법성 여부를 소송요건의 조사 순서 및 소송요건 흠결을 간과한 판결의 효력과 관련하여 설명하시오.》

<문제5.2의 물음1> 부제소특약의 간과와 본안기각판결 선고의 적법성 및 그 효력

I. 문제의 제기

- 사안에서 甲은 乙을 상대로 대여금 청구소송을 제기하였는데, 乙이 부제소특약의 존재를 주장하였음에도 제1심 법원은 이에 대한 심리 없이 본안에 관하여 청구기각판결을 선고한 상황이다. 쟁점으로 <소송요건인 부제소특약의 존부를 본안에 앞서 심리하여야 하는지, 이를 간과한 채 선고한 본안판결의 적법성과 효력>을 검토할 필요가 있다. 이하에서는 소송요건의 조사 순서와 소송요건 흠결을 간과한 본안판결의 효력을 중심으로 제1심 법원의 조치의 적법성 여부를 설명한다.

II. 소송요건의 의의와 조사 순서

1. 소송요건의 의의와 부제소특약

(1) 소송요건의 의의

- 소송요건이란 소송이 적법한 상소로서 법원의 본안심판을 받기 위해 갖추어야 할 요건을 말한다. 이는 공익적 견지에서 법원이 직권으로 조사해야 하는 직권조사사항과 당사자의 이익이 있어야 비로소 조사하는 항변사항으로 나뉜다.

(2) 부제소특약의 성격

- 부제소특약은 당사자 간의 합의로 소송을 제기하지 않기로 약정하는 사법상 계약이다. 판례는 이를 권리보호의 이익(소의 이익)에 관한 소송요건으로 보며, 당사자가 주장해야 비로소 심리하는 소송법상의 항변사항으로 취급한다.

2. 소송요건의 조사 순서와 선순위성

(1) 조사 순서의 원칙

- 법원은 소가 적법한지(소송요건)를 먼저 심사한 후, 비로소 청구가 이유 있는지(본안)를 심리하여야 한다. 이를 소송요건심리의 선순위성이라고 한다. 소송요건이 구비되지 않은 소송은 부적법하므로 법원은 본안심리를 진행할 수 없다.

(2) 원칙의 위반 효과

- 소송요건에 흠결이 있는 소송에 대하여 본안판결을 선고하는 것은 소송요건심리의 선순위성 원칙에 반하여 허용되지 않는다. 즉, 소송요건에 대한 판단을 생략한 채 본안심리를 진행하여 판결하는 조치는 절차법적으로 부적법하다.

III. 소송요건 흠결을 간과한 판결의 효력

1. 간과판결의 효력 일반

(1) 당연무효 여부

- 소송요건의 흠결을 간과한 판결은 원칙적으로 당연무효가 아니다. 판결에 중대한 법령 위반이 존재하여 위법할 뿐이므로, 상소 제기를 통해 취소할 수 있는 사유(취소사유)에 불과하다. 만약, 상소기간이 경과하여 판결이 확정된다면 그 기판력 등의 효력은 그대로 유지된다.

(2) 예외적인 당연무효 사유

- 당사자능력이 원천적으로 결여된 사망자를 상대로 한 판결이나 대한민국 재판권이 미치지 않는 대상에 대한 재판 등 극히 이례적인 절차적 흠결이 존재하는 경우에 한하여 예외적으로 당연무효가 된다. 사안의 부제소특약 흠결은 이에 해당하지 않는다.

2. 항소심의 처리와 불이익변경금지의 원칙

(1) 항소법원의 조치

- 원고만이 항소한 경우, 항소심 법원은 제1심의 본안기각판결을 취소하고 소송요건 흠결을 이유로 소각하판결을 선고할 수 있다. 소각하판결은 본안심리를 거절하는 처분으로서 기판력이 본안에 미치지 않으므로, 원고에게 본안청구기각보다 불리한 결과가 아니다.

(2) 불이익변경금지의 원칙과의 관계

- 판례는 제1심의 청구기각(본안기각) 판결에 대하여 원고만이 항소한 경우, 항소심 법원이 소가 부적법함을 이유로 제1심 판결을 취소하고 소각하판결을 하더라도 불이익변경금지의 원칙에 반하지 않는다고 본다. 본안기각판결보다 소각하판결이 원고에게 더 유리하거나 최소한 동등한 위치에 있기 때문이다.

IV. 사안의 적용

1. 제1심 법원 조치의 위법성

(1) 조사 의무 위배

- 피고 乙이 소송 계속 중 부제소특약의 합의를 주장(항변)하였으므로, 제1심 법원은 본안심리에 나아가기 전에 부제소특약의 존부와 적법성 여부를 우선적으로 심리·판단해야 할 소송법상 의무가 있었다.

(2) 선순위성 위배

- 법원이 부제소특약 유무를 확인하지 않고 곧바로 채권의 시효 소멸을 이유로 기각한 조치는 소송요건심리의 선순위성을 위반한 위법한 재판이다.

2. 판결의 효력 및 구제 방법

(1) 판결의 효력

- 제1심 법원이 내린 청구기각 판결은 절차적으로 위법하나 당연무효는 아니다. 적법한 상소 대상이 되므로, 甲은 항소를 통해 원심판결의 위법성을 다투어 구제받을 수 있다.

(2) 항소심의 최종 판단

- 항소심 법원은 부제소특약의 존재를 심리하여 특약이 유효함이 인정된다면, 제1심 판결을 취소하고 소를 부적법 각하하는 판결을 내려야 한다. 이는 불이익변경금지원칙에 저촉되지 않는 적법한 하자의 시정이다.

V. 결론

- 제1심 법원이 피고 乙의 부제소특약 주장을 심리하지 않고 곧바로 본안기각판결을 선고한 조치는 소송요건심리의 선순위성 원칙을 위반한 위법한 조치이다. 다만, 이 판결은 당연무효가 아니며 취소사유에 해당한다. 따라서 항소심 법원은 乙의 부제소특약 주장을 심리한 후 특약이 유효함이 밝혀진다면, 제1심 판결을 취소하고 소각하판결을 선고하여 제1심의 위법을 시정하여야 한다.

【문제5.2】

<사례>

甲은 乙을 상대로 1억 원의 대여금 청구소송을 제기하였다. 제1심 소송 계속 중, 피고 乙은 甲과 소를 제기하기 전에 이미 이 사건 분쟁에 대하여 법원에 소를 제기하지 않기로 합의(부제소특약)를 하였으므로 이 사건 소는 부적법하다고 주장하며 소각하를 청구하였다. 그러나 제1심 법원은 부제소특약의 존재 여부 및 그 적법성에 대해 구체적으로 심리하지 아니한 채, 변론기일을 열어 곧바로 대여금 채권의 성립 여부 등 본안에 관한 심리를 진행하였다. 제1심 법원은 심리 결과 대여금 채권이 시효로 소멸하였다는 이유로 甲의 청구를 기각하는 본안판결을 선고하였고, 甲은 이에 불복하여 항소하였다. 한편, 또 다른 사건에서 원고 A는 피고 B를 상대로 손해배상 청구소송을 제기하여 심리가 진행 중이다. 그런데 소송 계속 중 B는 A가 정신적 질환으로 인해 의사능력을 완전히 상실하였으므로 당사자능력에 흠결이 발생하였다고 주장하였다. 제1심 법원은 이러한 당사자능력과 같은 소송요건의 존재 여부를 어느 시점을 기준으로 판단해야 하는지, 그리고 해당 소송요건의 존부에 대한 증명책임은 소송법상 누구에게 귀속되는지 검토하고 있다.

(물음2) A와 B의 소송에서 당사자능력 등 소송요건의 존재를 판단하는 기준 시점은 언제인지 설명하고, 소송요건의 존부에 대한 증명방법 및 증명책임의 분배 원칙에 대하여 기술하시오.》

<문제5.2의 물음2> 당사자능력 등 소송요건의 존재를 판단하는 기준 시점과 증명방법 및 증명책임의 분배 원칙

I. 문제의 제기

- 사안에서 원고 A와 피고 B 사이의 손해배상청구소송에서 피고가 원고의 당사자능력 흠결을 주장함에 따라 소송요건인 당사자능력 등의 존부를 판단하여야 하는 상황이다. 쟁점으로 <소송요건의 존부를 판단하는 기준 시점과 소송요건에 관한 증명방법 및 증명책임의 분배 원칙이 무엇인지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 소송요건의 판단 기준 시점과 소송요건의 증명방법 및 증명책임의 분배 원칙을 기술한다.

II. 소송요건의 존재 판단 기준시점

1. 원칙 : 사실심 변론종결시

- 소송요건은 본안판결을 선고하기 위한 전제조건이므로, 소 제기 당시뿐만 아니라 판결을 선고하는 시점에도 구비되어 있어야 한다. 따라서 소송요건의 존부를 판단하는 표준적인 기준시점은 사실심의 변론종결시가 된다. 소 제기 당시에 소송요건에 흠결이 있었다라도 사실심 변론종결시까지 보정되면 소는 적법해지며, 반대로 소 제기 당시에는 요건을 갖추었으나 소송 도중 흠결이 발생하고 변론종결 시까지 보정되지 않으면 부적법 각하된다.

2. 예외 : 소 제기시 등을 기준으로 하는 경우

- 일부 소송요건은 제도의 취지상 예외적인 기준시점을 갖는다. 예컨대 제소기간의 준수 여부는 소 제기를 기준으로 판단하며, 관할권의 존부는 민사소송법 제29조에 따라 소를 제기한 때를 기준으로 확정되는 관할항정의 원칙이 적용된다.

III. 소송요건의 증명방법 및 증명책임

1. 소송요건의 증명방법

(1) 직권조사사항과 자료수집의 범위

- 당사자능력을 비롯한 대부분의 소송요건은 직권조사사항에 해당하므로 법원은 직권으로 조사를 진행하여야 한다. 이때 자료의 수집까지 법원이 직권으로 행하는 직권탐지주의가 적용되는지, 아니면 자료의 제출은 당사자에게 맡기되 조사만 직권으로 하는 직권조사주의가 적용되는지에 대해 판례는 소송요건의 성질에 따라 판단한다. 공익적 성격이 강한 당사자능력, 대리권 존부 등은 직권탐지주의가 적용된다.

(2) 자유로운 증명

- 본안의 사실인정은 엄격한 증명에 의하여야 하므로 법정의 증거방법에 제한을 받으나, 소송요건에 관한 사실은 소송절차에 관한 사실에 불과하므로 증거방법의 제한이 없는 자유로운 증명으로 족하다. 따라서 법원은 신문조서, 공문서 외에 간이한 방법으로 사실을 확인할 수 있다.

2. 소송요건의 증명책임 분배 원칙

(1) 적극적 소송요건

- 소가 적법하기 위해 존재해야 하는 요건인 당사자능력, 당사자자격, 재판권 및 관할권의 존재에 대해서는 원칙적으로 소를 제기한 원고가 그 존재에 대한 증명책임을 부담한다.

(2) 소극적 소송요건

- 소가 적법하기 위해 존재하지 않아야 하는 장애사유인 기판력의 저촉, 중복소제의 금지 위배, 부제소특약의 존재에 대해서는 소의 부적법을 주장하며 각하를 구하는 피고가 그 존재에 대한 증명책임을 부담한다.

IV. 사안의 적용

1. 당사자능력 판단 기준시점의 적용

- 원고 A는 소송 계속 중 정신질환으로 의사능력을 상실하여 당사자능력의 흠결 문제가 발생하였다. 당사자능력은 적극적 소송요건이자 직권조사사항이므로, 제1심 법원은 사실심 변론종결시를 기준으로 A의 당사자능력 유무를 판단하여야 한다. 만약 변론종결 당시에도 A가 당사자능력을 회복하지 못했거나 적법한 특별대리인 등의 수계 절차가 이루어지지 않았다면 소는 부적법 각하되어야 한다.

2. 증명방법 및 증명책임의 적용

- 당사자능력의 존부는 공익적 소송요건이므로 법원은 직권탐지주의에 따라 자유로운 증명방법으로 A의 의사능력 상실 여부 및 병원 진단서 등을 검토할 수 있다. 소송법상 적극적 소송요건인 당사자능력의 존재에 대한 최종적인 증명책임은 원고 A 측에 귀속되지만, 법원은 직권으로 의사의 감정을 명하는 등 사실 조사를 선행하여 절차적 하자를 치유할 수 있도록 조치하여야 한다.

V. 결론

- 당사자능력 등 소송요건의 존재를 판단하는 기준시점은 원칙적으로 사실심 변론종결시이다. 소송요건의 증명은 증거방법에 제한이 없는 자유로운 증명으로 가능하며, 당사자능력과 같은 적극적 소송요건의 존부에 대한 최종적인 증명책임은 소를 제기한 원고에게 귀속된다. 따라서 법원은 변론종결시를 기준으로 A의 의사능력 결여 상태를 자유로운 증명방법으로 심리한 후, 요건 흠결이 확정된다면 소를 각하하여야 한다.

《【문제5.2-3】 소송요건에 대해 설명하십시오. (25점)》

<문제5.2-3> 소송요건의 의의, 구체적 분류, 조사 심리 절차, 요건 흠결 시 소송법상 효과

I. 소송요건의 의의

- 소송요건이란 법원이 원고의 소 청구에 대하여 실체적 당부를 판단하는 본안판결을 내리기 위하여 갖추어야 할 전제조건들을 말한다. 이는 소의 적법 여부를 결정하는 척도가 되며, 소송요건의 구비는 본안심리를 개시하기 위한 전제조건으로서 강행규정성 및 공익적 성격을 지닌다.

II. 구체적 분류

1. 소송 주체에 관한 요건

(1) 법원에 관한 요건

- 대한민국 법원의 재판권 및 소 제기 법원의 관할권의 존재가 이에 해당한다.

(2) 당사자에 관한 요건

- 당사자의 실재, 당사자능력, 소송능력, 대리권의 존재, 구체적 소송물과의 관계에서 판결을 받기에 적합한 자격인 당사자적격의 구비가 필요하다.

2. 소송 객체에 관한 요건

(1) 소송물에 관한 요건

- 소의 이익(권리보호이익)의 구비, 중복소제기 또는 기판력에 저촉되지 않을 것 등이 요구된다.

(2) 소제기에 관한 요건

- 소제기 방식의 적법성 및 소송비용의 담보제공이나 인지 첩부 등이 올바르게 이행되어야 한다.

III. 조사 심리 절차

1. 조사 권한의 성질에 따른 구별

(1) 직권조사사항의 원칙

- 소송요건은 원칙적으로 강행규정에 해당하므로 피고의 이의 제기를 기다리지 않고 법원이 언제나 스스로 심리해야 하는 직권조사사항이다.

(2) 항변사항의 예외

- 사적 자치가 허용되는 관할합의, 중재합의 등 예외적인 사항은 피고의 이의 제기가 있어야만 비로소 조사하는 항소·항변사항으로 취급된다.

2. 심리 방식과 조사 한계

(1) 직권조사주의의 적용

- 법원은 소송요건의 존부를 직권으로 조사하되, 그 사실의 주장과 증거제출 책임은 당사자에게 있는 직권조사주의가 적용된다.

(2) 사실탐지의 한계

- 당사자의 증명 활동과 무관하게 법원이 독자적으로 소송자료를 수집해야 하는 직권탐지주의와는 구별되어야 하므로 당사자의 사실 제출 독점권이 보장된다.

IV. 요건 흠결 시 소송법상 효과

1. 심리 단계에서의 임시 조치

(1) 석명권 행사와 보정명령

- 소송요건의 흠결을 발견한 경우 법원은 즉시 각하하지 않고, 당사자표시정정 등 보정이 가능한 하자에 대해서는 일정한 기간을 정해 보정을 촉구해야 한다.

(2) 하자의 치유

- 소송요건의 존부는 사실심 변론종결 시를 기준으로 하므로, 제소 당시에 흠결이 있었다라도 변론종결 전까지 하자가 치유되면 적법한 소가 된다.

2. 중국적인 판결 및 불복

(1) 소각하 판결의 원칙

- 흠결이 보정되지 않거나 보정이 불가능한 성질의 것인 때에는 법원은 본안심리를 거절하고 판결로써 소를 부적법 각하하여 소송을 바로 종료해야 한다.

(2) 하자 간과 판결의 구제

- 흠결을 간과한 본안판결에 대하여 당사자는 상소(항소 및 상고)로 취소를 구할 수 있으나, 확정되면 당연무효의 극단적 하자가 아닌 한 기판력이 발생하여 유효한 판결로 취급된다.

V. 결론

- 소송요건은 사법 자원의 불필요한 낭비를 방지하고 적법한 재판 청구만을 수용하려는 소송법적 안전망이다. 우리 민사소송법은 직권조사주의와 보정 명령 제도를 적절히 조화시켜, 절차의 엄격성을 수호하면서도 국민의 재판을 받을 권리를 부당하게 제한하지 않도록 균형 있게 조율하고 있다.

《【문제5.4】

<사례>

甲은 乙에게 자신의 소유인 X 토지를 매도하기로 하는 계약을 체결하고 소유권이전등기를 마쳐주었다. 그러나 이후 甲은 乙의 기망행위를 이유로 위 매매계약을 적법하게 취소하였다고 주장하며, 乙을 상대로 소유권이전등기의 말소를 구하는 소를 제기하였다. 이 소송에서 甲은 취소에 따른 원상회복으로서의 소유권귀속에 기한 물권적 청구권을 원인으로 내세웠다.

심리 결과 甲의 청구는 기각되었고 판결은 확정되었다. 그 후 甲은 다시 乙을 상대로 동일한 X 토지에 대하여 소유권이전등기말소청구의 소를 제기하면서, 이번에는 매매계약이 처음부터 무효였다는 점을 근거로 무효인 계약에 따른 원상회복청구권을 주장하였다.

한편, 丙은 丁이 운전하던 차량에 치여 부상을 당하였다. 丙은 丁을 상대로 치료비 1,000만 원의 지급을 구하는 소를 제기하였다. 이 소송의 변론 과정에서 丙은 丁의 과실에 의한 불법행위책임만을 주장하였으나, 법원은 丁이 운행공용자로서 자동차손해배상 보장법에 따른 책임을 질 수도 있다고 판단하였다.

(물음1) 甲이 제기한 후소의 소송물이 전소의 소송물과 동일한지 여부에 대하여 판례의 입장인 구실체법설(구이론)에 근거하여 논하고, 이에 따른 후소의 적법성 여부를 판단하시오.》

<문제5.4의 물음1> 구실체법설에 따른 전후소 소송물의 동일성 여부 및 후소의 적법성 판단

I. 문제의 제기

- 사안에서 甲은 X 토지에 관한 매매계약의 취소를 원인으로 소유권이전등기말소를 청구하였다가 패소확정된 후, 다시 동일한 토지에 대하여 매매계약의 무효를 원인으로 소유권이전등기말소를 청구하는 후소를 제기한 상황이다. 쟁점으로 <동일한 청구취지 아래 취소에 따른 원상회복청구권과 무효에 따른 원상회복청구권이 판례의 구실체법설상 동일한 소송물인지 및 이에 따라 후소가 기판력에 저촉되어 적법한지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 구실체법설에 따른 소송물의 동일성 및 후소의 적법성 여부를 판단한다.

II. 소송물 이론과 구실체법설

1. 소송물 이론의 의의

- 소송물 이론은 소송의 대상을 어떻게 확정할 것인가에 관한 논의로서, 이는 중복소제기 금지, 처분권주의의 범위, 청구의 변경, 기판력의 범위를 결정하는 기준이 된다.

2. 구실체법설(구이론)

(1) 내용

- 실체법상의 권리 또는 법률관계를 기준으로 소송물을 확정하는 견해다. 즉, 실체법상 권리마다 별개의 소송물이 성립한다고 본다.

(2) 판례의 입장

- 우리 대법원은 원칙적으로 구실체법설의 입장을 견지하고 있다. 따라서 실체법상 권리가 다르면 청구취지가 동일하더라도 소송물은 별개라는 것이 확립된 태도다.

III. 소송물의 동일성 여부 검토

1. 물권적 청구권과 소송물

(1) 소유권에 기한 방해배제청구권

- 판례는 소유권에 기한 말소등기청구소송에서 그 등기원인의 무효 사유가 다르더라도 소송물은 소유권에 기한 방해배제청구권으로서 하나라고 본다. 따라서 전소에서 주장하지 않은 무효 사유를 후소에서 주장하는 것은 소송물의 변경이 아니라 공격방어방법의 변경에 불과하다.

(2) 예외 : 청구권원 자체가 다른 경우

- 만약 전소는 계약상의 채권적 청구권이고 후소가 물권적 청구권이라면 이는 실체법상 권리가 다르므로 소송물이 별개로 취급된다.

2. 사안의 경우

(1) 전소의 소송물

- 甲은 취소에 따른 원상회복으로서 소유권귀속에 기한 물권적 청구권을 주장하였다. 이는 실체법상 소유권에 기한 방해배제청구권에 해당한다.

(2) 후소의 소송물

- 甲은 무효에 따른 원상회복을 주장하며 다시 말소등기를 청구하였다. 취소와 무효는 그 원인은 다르지만, 결국 실체법상으로는 동일한 소유권에 기한 방해배제청구권을 행사하는 것이다.

(3) 소결

- 판례의 태도에 의하면 등기원인의 무효 사유(취소 또는 무효)는 공격방어방법에 불과하므로, 전소와 후소의 소송물은 동일하다.

IV. 후소의 적법성 판단

1. 기판력의 의의 및 범위

(1) 의의

- 확정판결의 판단 내용이 후소의 법원을 구속하여 당사자가 이와 모순되는 주장을 할 수 없게 하는 효력이다.

(2) 시적 범위

- 기판력은 사실심 변론종결 시를 기준으로 발생한다. 당사자는 변론종결 전의 사유를 후소에서 다시 주장할 수 없다.

2. 기판력의 저촉 여부

- 사안의 전소 판결은 기각되어 확정되었다. 후소는 전소와 동일한 소송물(소유권에 기한 말소등기청구권)을 대상으로 하므로 전소 판결의 기판력이 미친다. 甲이 후소에서 주장하는 매매계약의 무효 사유는 전소의 변론종결 전에 이미 존재하던 사유이므로, 이를 뒤늦게 주장하는 것은 기판력의 차단효에 의해 허용되지 않는다.

V. 결론

- 구실체법설을 취하는 판례에 의할 때, 전소와 후소는 모두 소유권에 기한 물권적 청구권으로서 소송물이 동일하다. 따라서 후소는 전소의 확정판결의 기판력에 저촉된다. 법원은 기판력에 저촉되는 후소에 대하여 청구기각 판결을 내려야 한다는 것이 판례의 일반적인 태도다. 다만 최근에는 소송 요건으로 보아 소를 부적법각하해야 한다는 견해도 있으나, 판례는 대체로 실체적 판결로서 기각하는 방식을 취한다. 결론적으로 甲의 후소는 전소의 효력에 반하여 허용될 수 없다.

《【문제5.4】

<사례>

甲은 乙에게 자신의 소유인 X 토지를 매도하기로 하는 계약을 체결하고 소유권이전등기를 마쳐주었다. 그러나 이후 甲은 乙의 기망행위를 이유로 위 매매계약을 적법하게 취소하였다고 주장하며, 乙을 상대로 소유권이전등기의 말소를 구하는 소를 제기하였다. 이 소송에서 甲은 취소에 따른 원상회복으로서의 소유권귀속에 기한 물권적 청구권을 원인으로 내세웠다.

심리 결과 甲의 청구는 기각되었고 판결은 확정되었다. 그 후 甲은 다시 乙을 상대로 동일한 X 토지에 대하여 소유권이전등기말소청구의 소를 제기하면서, 이번에는 매매계약이 처음부터 무효였다는 점을 근거로 무효인 계약에 따른 원상회복청구권을 주장하였다.

한편, 丙은 丁이 운전하던 차량에 치여 부상을 당하였다. 丙은 丁을 상대로 치료비 1,000만 원의 지급을 구하는 소를 제기하였다. 이 소송의 변론 과정에서 丙은 丁의 과실에 의한 불법행위책임만을 주장하였으나, 법원은 丁이 운행공용자로서 자동차손해배상 보장법에 따른 책임을 질 수도 있다고 판단하였다.

(물음2) 丙이 제기한 소송에서 불법행위에 기한 손해배상청구권과 자동차손해배상 보장법에 기한 손해배상청구권의 관계를 소송물 이론의 관점에서 설명하고, 법원이 원고의 주장과 다른 법적 근거를 토대로 판결할 수 있는지 여부를 기술하시오.》

<문제5.4의 물음2> 불법행위책임과 자배법상 책임의 소송물 관계 및 법원의 법적 근거 선택 권한

I. 문제의 제기

- 사안에서 丙은 丁을 상대로 치료비 지급을 구하면서 불법행위책임만을 주장하였으나, 법원은 자동차손해배상 보장법(이하 '자배법')에 따른 책임도 인정하고 있는 상황이다. 쟁점으로 《불법행위에 기한 손해배상청구권과 자배법에 기한 손해배상청구권의 소송물 관계 및 법원이 원고가 주장하지 않은 법적 근거를 적용하여 판결할 수 있는지》 여부를 검토할 필요가 있다. 이하에서는 양 청구권의 소송물 관계와 법원의 법적 평가 및 다른 법적 근거에 의한 판단 가능 여부를 기술한다.

II. 소송물 이론에 따른 두 청구권의 관계

1. 학설의 태도

(1) 구실체법설

- 실체법상 권리마다 별개의 소송물이 성립한다고 본다. 이 견해에 의하면 민법상 불법행위책임과 자배법상 책임은 근거 법령이 다르므로 별개의 소송물이다.

(2) 신소송물이론(신이론)

- 신이론 중 일원설은 신청의 목적(청구취지)과 원인 사실이 같으면 소송물은 하나라고 본다. 이 견해에 의하면 손해배상이라는 하나의 목적을 가지므로 소송물은 단일하다.

2. 판례의 입장

- 판례는 원칙적으로 구실체법설의 입장을 취하고 있다. 그러나 손해배상청구 사건에 있어서는 실체법상 권리가 수개이더라도 원고가 청구하는 손해의 범위가 동일하다면 이를 하나의 소송물로 파악하려는 경향도 일부 존재한다. 하지만 자배법과 민법상 불법행위의 관계에 있어서는 양자를 별개의 성립 요건을 가진 독립된 청구권으로 보면서도, 실질적으로는 청구의 경합 관계에 있다고 판단한다.

III. 법원의 법적 근거 선택 및 판결 가능성

1. 법적 고지의 원칙과 법률판단의 전권

(1) 의의

- 법원은 당사자가 주장하는 사실관계에 구속될 뿐, 그 사실에 적용할 법률의 해석과 적용은 법원의 고유한 권한에 속한다. 이를 법적 고지의 원칙이라 한다.

(2) 처분권주의와의 관계

- 당사자는 소송의 개시, 심판 대상의 범위, 소송의 종료에 대하여 결정권(처분권주의)을 갖지만, 일단 확정된 사실에 대해 어떤 법을 적용할지는 법원의 영역이다. 따라서 원고가 민법 제750조만을 주장하더라도 법원이 사실관계를 통해 자배법 제3조가 적용된다고 판단한다면 그에 따라 판결할 수 있다.

2. 판례의 구체적 태도

- 판례는 민법상 불법행위책임과 자배법상 책임이 모두 청구원인으로 주장된 경우뿐만 아니라, 원고가 어느 하나만을 주장하더라도 법원은 요건이 충족되는 다른 법적 근거를 토대로 판결할 수 있다고 본다. 즉, 원고가 불법행위책임만을 주장하였더라도 소송 자료를 통해 자배법상 책임의 요건이 인정된다면, 법원이 자배법을 적용하여 승소 판결을 내리는 것은 처분권주의 위반이 아니라고 판단한다.

IV. 사안의 적용

1. 丙이 제기한 소송의 소송물

- 사안에서 丙은 丁의 과실을 근거로 한 불법행위책임을 주장하고 있다. 구실체법설에 의하면 이는 민법상 권리다. 그러나 자배법상 책임 역시 동일한 교통사고라는 사실관계에서 비롯된 손해배상청구권이다. 판례에 따르면 이들은 실체법상 경합 관계에 있으나, 법원은 원고가 구하는 손해배상액이라는 범위 내에서 두 법적 근거를 모두 심리할 수 있다.

2. 법원의 판결 가능성

- 법원은 丁이 운행공용자로서 자배법상의 책임을 질 수 있다고 판단하였다. 丙이 명시적으로 자배법을 언급하지 않았더라도, 丙이 제출한 사실관계(사고의 경위, 丁의 운전 사실 등)가 자배법상 책임 요건을 갖추고 있다면 법원은 자배법을 근거로 丙의 청구를 인용할 수 있다. 이는 법원이 법률을 적용하는 전권 사항에 해당하므로 처분권주의에 반하지 않는다.

V. 결론

- 丙이 제기한 소송에서 불법행위책임과 자배법상 책임은 실체법상 권리의 발생 근거를 달리하는 경합 관계에 있다. 소송물 이론상 구실체법설에 의하면 별개의 권리이지만, 법원은 사실관계의 동일성 범위 내에서 적절한 법률을 선택하여 적용할 권한이 있다. 따라서 법원은 丙이 불법행위책임만을 주장하였더라도 자배법상 책임을 토대로 판결할 수 있으며, 이는 정당한 법률적 판단권의 행사로 보아야 한다. 다만, 법원은 이 과정에서 당사자가 예상하지 못한 법적 판단으로 불이익을 입지 않도록 적절히 지적의무(석명권 행사의 일종)를 다하여 당사자에게 의견 제출의 기회를 주는 것이 바람직하다.

《【문제5.5】

<사례>

甲은 乙을 상대로 대여금 5,000만 원의 지급을 구하는 소를 서울중앙지방법원에 제기하였다. 甲이 제출한 소장 부분은 2023. 5. 1. 乙에게 적법하게 송달되었다. 그런데 乙은 위 소송이 진행 중임에도 불구하고, 2023. 6. 1. 역으로 甲을 상대로 하여 동일한 대여금 채무가 존재하지 아니한다는 채무부존재 확인의 소를 수원지방법원에 제기하였다.

한편, A는 B를 상대로 건물철거 및 토지인도소송을 제기하여 승소 판결을 받았고 이 판결은 확정되었다. 그 후 B는 해당 토지의 점유를 계속하면서 건물 을 제3자인 C에게 매도하고 소유권이전등기를 마쳐주었다. 이에 A는 다시 C를 상대로 건물철거를 구하는 소를 제기하고자 한다.

또한, 丙은 丁을 상대로 손해배상청구의 소를 제기하면서 소장에 청구금액을 1억 원으로 기재하였다. 소송 계속 중 丙은 동일한 사고로 인한 손해액이 사실은 2억 원임을 알게 되었고, 이미 제기한 소송의 청구취지를 확장하지 않은 채 나머지 1억 원에 대하여 별개의 소를 추가로 제기하였다.

(물음1) 乙이 甲을 상대로 제기한 채무부존재확인 소가 민사소송법 제259조의 중복소제기 금지 원칙에 위반되는지 여부를 판단하고, 만약 위반된다면 수원지방법원이 내려야 할 판결의 형식에 대하여 논하시오.》

<문제5.5의 물음1> 채무부존재확인 소의 중복소제기 금지 위반 여부 및 판결의 형식

I. 문제의 제기

- 사안에서 甲이 乙을 상대로 대여금 지급청구의 소를 제기하여 소송이 계속 중임에도 乙이 동일한 대여금채무의 부존재확인 소를 별도로 제기한 상황이다. 쟁점으로 <동일한 분쟁에 관한 후소가 민사소송법 제259조의 중복소제기 금지 원칙에 위반되는지 여부>와 <위반되는 경우 후소법원이 어떠한 형식의 재판을 하여야 하는지>를 검토할 필요가 있다. 이하에서는 乙이 제기한 채무부존재확인 소의 중복소제기 해당 여부 및 이에 따른 후소의 처리 방안을 논한다.

II. 중복소제기 금지의 요건

1. 당사자의 동일성

- 전소와 후소의 당사자가 동일해야 한다. 이때 당사자가 원고와 피고로서의 지위를 서로 바꾸어 소를 제기하는 이른바 반대소송의 경우에도 당사자의 동일성이 인정된다.

2. 소송물의 동일성

- 전소와 후소의 심판 대상인 소송물이 동일해야 한다. 사안의 경우 전소는 5,000만 원의 대여금 지급청구권의 존재를 전제로 하는 이행의 소이고, 후소는 동일한 대여금 채무가 존재하지 않는다는 확인을 구하는 소이다. 양 소송은 동일한 권리관계의 존부에 관한 것이므로 소송물의 동일성이 인정된다.

3. 전소의 계속 중 후소의 제기

- 후소가 제기될 당시 전소가 법원에 계속되어 있어야 한다. 사안에서 甲의 소장은 2023. 5. 1. 송달되어 소송계속이 발생하였고, 乙의 소는 그 이후인 2023. 6. 1. 제기되었으므로 이 요건을 충족한다.

III. 중복소제기 해당 여부에 관한 판례의 태도

1. 이행의 소와 채무부존재확인 소의 관계

- 판례는 동일한 채권채무 관계에 대하여 채권자가 이행의 소를 제기한 후 채무자가 채무부존재확인 소를 제기하거나, 반대로 채무자가 확인의 소를 제기한 후 채권자가 이행의 소를 제기하는 경우 모두 중복소제기에 해당한다고 본다.

2. 사안의 경우

- 사안에서 甲이 제기한 대여금 청구소송은 전소로서 이미 소송계속이 발생하였다. 乙이 그 후에 동일한 채무를 대상으로 제기한 채무부존재확인 소는 전소의 소송물과 실질적으로 동일한 대상을 확인받으려는 것이므로, 민사소송법 제259조에 위반되는 중복소제기에 해당한다.

IV. 수원지방법원이 내려야 할 판결의 형식

1. 소송요건으로서의 성질

- 중복소제기 금지는 법원의 직권조사 사항이며 소송요건에 해당한다. 소송요건은 소송 전체의 적법 여부를 판단하는 전제 조건이다.

2. 판결의 형식 : 소각하판결

- 후소가 중복소제기에 해당하여 부적법한 경우, 법원은 본안에 대한 심리를 하지 않고 소를 물리치는 소각하판결을 내려야 한다. 사안의 수원지방법원은 乙이 제기한 후소가 중복소제기 금지 원칙에 위배되어 부적법하다는 이유로 판결로써 소를 각하하여야 한다.

3. 예외 : 전소의 취하 또는 각하

- 만약 후소의 변론종결 전에 전소가 취하되거나 각하되어 소송계속이 소멸한다면 후소의 중복소제기 흠결은 치유될 수 있다. 그러나 사안에서 전소가 정상적으로 진행 중이라면 후소는 각하를 면할 수 없다.

V. 결론

- 乙이 甲을 상대로 제기한 채무부존재확인 소는 이미 계속 중인 甲의 대여금 청구소송과 당사자 및 소송물이 동일하므로 민사소송법 제259조의 중복소제기 금지 원칙에 정면으로 위반된다. 따라서 후소의 수소법원인 수원지방법원은 乙의 소가 소송요건을 갖추지 못한 부적법한 소라고 판단하여 소각하판결을 내려야 한다. 이러한 중복소제기 금지 원칙은 판결의 모순·저촉을 방지하고 소송 경제를 도모하기 위한 필수적인 절차적 규범이다.

《【문제5.5】

<사례>

甲은 乙을 상대로 대여금 5,000만 원의 지급을 구하는 소를 서울중앙지방법원에 제기하였다. 甲이 제출한 소장 부분은 2023. 5. 1. 乙에게 적법하게 송달되었다. 그런데 乙은 위 소송이 진행 중임에도 불구하고, 2023. 6. 1. 역으로 甲을 상대로 하여 동일한 대여금 채무가 존재하지 아니한다는 채무부존재 확인의 소를 수원지방법원에 제기하였다.

한편, A는 B를 상대로 건물철거 및 토지인도소송을 제기하여 승소 판결을 받았고 이 판결은 확정되었다. 그 후 B는 해당 토지의 점유를 계속하면서 건물 을 제3자인 C에게 매도하고 소유권이전등기를 마쳐주었다. 이에 A는 다시 C를 상대로 건물철거를 구하는 소를 제기하고자 한다.

또한, 丙은 丁을 상대로 손해배상청구의 소를 제기하면서 소장에 청구금액을 1억 원으로 기재하였다. 소송 계속 중 丙은 동일한 사고로 인한 손해액이 사실은 2억 원임을 알게 되었고, 이미 제기한 소송의 청구취지를 확장하지 않은 채 나머지 1억 원에 대하여 별개의 소를 추가로 제기하였다.

(물음2) 丙이 나머지 1억 원에 대하여 별소를 제기한 경우, 전소의 소장에서 청구 범위를 명확히 특정하지 않았을 때(일부청구임을 명시하지 않았을 때) 후소에 미치는 소송법적 효과 및 중복소제기 해당 여부를 판례의 태도에 근거하여 설명하시오.》

<문제5.5의 물음2> 일부청구임을 명시하지 않은 별소 제기의 중복소제기 해당 여부 및 효과

I. 문제의 제기

- 사안에서 丙은 손해배상금 1억 원을 청구하는 소를 제기한 후 일부청구임을 명시하지 않은 상태에서 동일한 사고로 인한 나머지 1억 원에 대하여 별소를 제기한 상황이다. 쟁점으로 <일부청구임을 명시하지 않은 전소가 후소에 어떠한 소송법적 효과를 미치는>와 <나머지 1억 원에 대한 후소가 중복소제기 금지 원칙에 위반되는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 일부청구임을 명시하지 않은 경우의 후소에 대한 소송법적 효과와 중복소제기 해당 여부를 설명한다.

II. 일부청구의 소송물과 명시 여부

1. 일부청구의 소송물에 관한 학설

(1) 일부설(판례)

- 일부청구임을 명시한 경우에는 그 일부만이 소송물이 되지만, 명시하지 않은 경우에는 채권 전액이 소송물이 된다는 견해다.

(2) 전부설

- 일부청구 여부와 상관없이 그 채권 전액이 소송물이 된다는 견해다.

2. 판례의 태도(일부청구 명시 필요성)

- 대법원은 가분채권의 일부만을 청구하는 경우, 소장에 그것이 채권의 일부임을 명시하여야 소송물이 그 일부로 제한된다고 본다. 만약 일부청구임을 명시하지 않았다면 채권의 전부가 소송물로 확정된다는 것이 확립된 판례의 입장이다.

III. 중복소제기 해당 여부 판단

1. 중복소제기 금지의 요건과 일부청구

(1) 전소에서 일부청구임을 명시한 경우

- 이 경우 전소의 소송물은 청구한 일부에 한정되므로, 나머지 부분에 대하여 별소를 제기하더라도 소송물이 달라 중복소제기에 해당하지 않는 것이 원칙이다.

(2) 전소에서 일부청구임을 명시하지 않은 경우

- 사안과 같이 일부청구임을 명시하지 않은 경우, 전소의 소송물은 채권 전액(2억 원)이 된다. 따라서 전소가 계속 중인 상태에서 나머지 부분(1억 원)에 대하여 다시 소를 제기하는 것은 동일한 소송물에 대하여 이중으로 소를 제기하는 것이 되어 중복소제기 금지 원칙에 위배된다.

2. 사안의 경우

- 丙은 전소에서 1억 원을 청구하면서 이것이 일부청구임을 명시하지 않았다. 판례에 따르면 전소의 소송물은 사고로 인한 손해배상청구권 전액이 된다. 따라서 丙이 후소로 제기한 나머지 1억 원 청구는 전소의 소송물 범위 내에 포함되는 것이며, 전소가 계속 중인 상태에서 제기되었으므로 민사소송법 제259조의 중복소제기에 해당하여 부적법하다.

IV. 후소에 미치는 소송법적 효과

1. 중복소제기 원칙 위반의 효과

- 후소의 수소법원은 丙의 후소가 중복소제기에 해당함을 이유로 소각하판결을 내려야 한다. 이는 소송 요건에 관한 흠결로서 본안 심리를 할 수 없는 사유에 해당한다.

2. 기판력의 범위와 차단효

(1) 전소 판결 확정 시의 영향

- 만약 전소에서 일부청구임을 명시하지 않은 채 판결이 확정된다면, 그 기판력은 채권 전액에 미치게 된다. 따라서 후소에서 나머지 금액을 청구하는 것은 전소의 확정판결과 모순되는 주장을 하는 것이 되어 허용되지 않는다.

(2) 잔액 청구의 봉쇄

- 원고가 일부청구임을 명시하지 않아 전소에서 채권 전액이 소송물로 확정되었음에도 불구하고 일부만 인용되었다면, 명시적 일부청구가 아니었으므로 나머지 잔액에 대해서는 기판력에 의해 더 이상 다룰 수 없게 된다.

3. 구제 수단 : 청구취지의 확장

- 丙은 별소를 제기할 것이 아니라, 현재 계속 중인 전소 절차 내에서 민사소송법 제262조에 따른 청구취지 확장을 통해 손해액을 2억 원으로 증액하여야 한다. 이는 소의 변경 중 추가적 변경에 해당하며, 소송의 지연이 없는 한 허용된다.

V. 결론

- 丙이 전소에서 일부청구임을 명시하지 않은 채 나머지 금액에 대하여 별소를 제기한 것은 전소와 후소의 소송물이 동일한 경우에 해당한다. 따라서 후소는 민사소송법 제259조의 중복소제기 금지 원칙에 위반되어 부적법하며 소각하판결의 대상이 된다. 판례는 가분채권의 소송물 범위를 원고의 명시 여부에 따라 결정함으로써 법률관계의 명확성과 피고의 응소 부담 경감을 도모하고 있다. 결과적으로 丙은 후소를 취하하고 전소에서 청구취지를 확장하는 방식을 취하여야 적법하게 권리구제를 받을 수 있다.

<제3편 제1심의 소송절차.제05장 소송 개시와 심리 대상.제06절 재판장의 소장심사와 그 후의 조치>
[예상][5.06-1]보정기한 도과 후 각하명령 송달 전 흠결 보정 시 소장각하명령의 효력

《【문제5.6】

<사례>

甲은 乙을 상대로 1억 원의 대여금 반환을 구하는 소를 제기하고자 서울중앙지방법원에 소장을 제출하였다. 그런데 甲은 소장에 乙의 주소를 기재하면서 서울 강남구 이하 불상이라고만 기재하였고, 청구원인에는 乙이 돈을 빌려가서 안 갚음이라고만 간략히 적어 제출하였다. 담당 재판장 A는 소장을 심사한 후 甲에게 7일 이내에 피고의 구체적인 주소를 보정하고 청구원인을 구체적으로 특정할 것을 명하는 보정명령을 내렸다.

위 보정명령은 2023. 10. 1. 甲에게 적법하게 송달되었으나, 甲은 2023. 10. 15.이 되어서야 보정서를 제출하였다. 한편, 재판장 A는 甲이 기한 내에 보정하지 않자 2023. 10. 10. 소장각하명령을 작성하였으나, 이 명령이 甲에게 송달되기 전인 10. 15.에 甲의 보정서가 법원에 도착하였다.

또 다른 사례로, 丙은 丁을 상대로 소를 제기하여 소장 부분이 丁에게 송달되었다. 그러나 丁은 주소지에 거주하지 않아 송달불능이 되었고, 재판장은 丙에게 주소보정을 명하였다. 丙은 丁의 소재를 알 수 없어 공시송달을 신청하였으나, 재판장은 요건 미비를 이유로 이를 받아들이지 않고 다시 주소보정을 명하며 이를 이행하지 않을 경우 소장을 각하하겠다고 통지하였다.

(물음1) 재판장 A가 내린 소장각하명령의 성질과 관련하여, 甲이 보정기한을 도과하였으나 각하명령이 송달되기 전에 흠결을 보정하였다면 재판장이 이미 작성한 소장각하명령을 그대로 집행할 수 있는지 여부를 판례의 태도에 근거하여 논하시오.》

<문제5.6의 물음1> 보정기한 도과 후 각하명령 송달 전 흠결 보정 시 소장각하명령의 효력

I. 문제의 제기

- 사안에서 甲은 보정명령에서 정한 기간을 경과하여 소장의 흠결을 보정하였으나, 그 보정서가 재판장이 작성한 소장각하명령이 송달되기 전에 법원에 제출된 상황이다. 쟁점으로 <소장각하명령의 법적 성질과 보정기간을 도과한 흠결보정이 각하명령 송달 전에 이루어진 경우 재판장이 이미 작성한 소장각하명령을 그대로 송달·집행할 수 있는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 소장각하명령의 성질과 각하명령 송달 전 흠결보정이 이루어진 경우 소장각하명령의 효력을 논한다.

II. 재판장의 소장심사권과 보정명령

1. 소장심사권의 의의

- 재판장은 소장이 제출되면 소장의 방식 적합 여부를 심사한다. 이는 소송절차의 경제와 피고의 부당한 응소 부담을 방지하기 위한 제도다.

2. 보정명령 및 소장각하명령

(1) 보정명령

- 소장에 필요적 기재사항(당사자, 법정대리인, 청구취지, 청구원인)이 누락되었거나 규정에 따른 인지를 붙이지 않은 경우, 재판장은 상당한 기간을 정하여 보정을 명한다.

(2) 소장각하명령

- 원고가 보정기한 내에 흠결을 보정하지 아니한 때에는 재판장은 명령으로 소장을 각하하여야 한다. 이는 판결이 아닌 명령의 형식으로 이루어지는 재판이다.

III. 소장각하명령의 성질 및 효력 발생 시기

1. 명령의 성질

- 소장각하명령은 재판장이 소송지휘권의 일환으로 행하는 재판이다. 이는 법원의 판단이 대외적으로 표시됨으로써 효력을 발생하게 된다.

2. 효력 발생 시기(송달 시)

- 판결이 선고에 의해 효력이 발생하는 것과 달리, 결정이나 명령은 당사자에게 송달됨으로써 그 효력이 발생한다. 따라서 소장각하명령이 작성되었다 하더라도 원고에게 송달되기 전까지는 대외적으로 완전한 효력을 가졌다고 보기 어렵다.

IV. 보정기한 도과 후 송달 전 보정의 효력

1. 학설의 태도

(1) 긍정설

- 보정기한은 불변기간이 아니므로, 각하명령이 송달되어 효력이 발생하기 전까지 보정이 이루어졌다면 소 제기는 적법해진다는 견해다.

(2) 부정설

- 일단 보정기한이 도과하면 재판장의 각하 의무가 발생하므로, 사후적인 보정으로 이미 발생한 각하 사유를 치유할 수 없다는 견해다.

2. 판례의 태도

- 판례는 소장각하명령이 내린 경우라도 그 명령이 원고에게 송달되기 전에 원고가 재판장의 보정명령 취지에 따라 흠결을 보정하였다면, 재판장은 그 소장각하명령을 송달할 수 없고 소송절차를 진행하여야 한다는 입장이다. 즉, 보정기한을 도과했더라도 각하명령의 효력 발생 전에 보정이 이루어지면 흠결은 치유된 것으로 본다.

V. 사안의 적용

1. 보정의 유효성 판단

- 사안에서 甲은 보정기한인 2023. 10. 8.을 도과하여 10. 15.에 보정서를 제출하였다. 그러나 재판장 A가 작성한 소장각하명령은 아직 甲에게 송달되지 않은 상태였다. 판례의 취지에 따르면 소장각하명령의 효력이 발생하기 전에 흠결이 실질적으로 보정되었으므로, 재판장은 이미 작성된 각하명령을 집행(송달)할 수 없다.

2. 재판장이 취해야 할 조치

- 재판장 A는 甲의 보정서가 제출된 이상, 기존에 작성했던 소장각하명령을 파기하거나 집행하지 않아야 한다. 소장의 흠결이 보정된 것으로 간주하여 소장 부분을 피고 乙에게 송달하고 변론기일을 지정하는 등 정상적인 소송절차를 개시하여야 한다.

VI. 결론

- 재판장의 소장각하명령은 원고에게 송달됨으로써 효력이 발생한다. 따라서 보정기한이 지났더라도 각하명령이 송달되기 전에 원고가 흠결을 보정하였다면 소장의 적법성은 회복된다. 사안의 甲은 비록 기한은 어겼으나 명령 송달 전 보정을 완료하였으므로 재판장은 소장각하명령을 그대로 집행할 수 없으며, 소송을 계속 진행하여야 한다. 이는 원고의 재판청구권을 과도하게 제약하지 않으면서도 실질적인 보정을 유도하고자 하는 판례의 타당한 해석이다.

<제3편 제1심의 소송절차.제05장 소송 개시와 심리 대상.제06절 재판장의 소장심사와 그 후의 조치>
[예상][5.06-2]소장 부분 송달불능 시 재판장의 조치인 소장각하명령과 소각하판결의 차이점

《【문제5.6】

<사례>

甲은 乙을 상대로 1억 원의 대여금 반환을 구하는 소를 제기하고자 서울중앙지방법원에 소장을 제출하였다. 그런데 甲은 소장에 乙의 주소를 기재하면서 서울 강남구 이하 불상이라고만 기재하였고, 청구원인에는 乙이 돈을 빌려가서 안 갚음이라고만 간략히 적어 제출하였다. 담당 재판장 A는 소장을 심사한 후 甲에게 7일 이내에 피고의 구체적인 주소를 보정하고 청구원인을 구체적으로 특정할 것을 명하는 보정명령을 내렸다.

위 보정명령은 2023. 10. 1. 甲에게 적법하게 송달되었으나, 甲은 2023. 10. 15.이 되어서야 보정서를 제출하였다. 한편, 재판장 A는 甲이 기한 내에 보정하지 않자 2023. 10. 10. 소장각하명령을 작성하였으나, 이 명령이 甲에게 송달되기 전인 10. 15.에 甲의 보정서가 법원에 도착하였다.

또 다른 사례로, 丙은 丁을 상대로 소를 제기하여 소장 부분이 丁에게 송달되었다. 그러나 丁은 주소지에 거주하지 않아 송달불능이 되었고, 재판장은 丙에게 주소보정을 명하였다. 丙은 丁의 소재를 알 수 없자 공시송달을 신청하였으나, 재판장은 요건 미비를 이유로 이를 받아들이지 않고 다시 주소보정을 명하며 이를 이행하지 않을 경우 소장을 각하하겠다고 통지하였다.

(물음2) 피고 丁에 대한 소장 부분의 송달이 불가능하여 재판장이 주소보정을 명하였음에도 丙이 이에 응하지 않거나 공시송달 요건을 갖추지 못한 경우, 재판장이 행할 수 있는 조치인 소장각하명령과 소각하판결의 차이점을 소송 계속의 발생 여부와 관련하여 설명하시오.》

<문제5.6의 물음2> 소장 부분 송달불능 시 재판장의 조치인 소장각하명령과 소각하판결의 차이점

I. 문제의 제기

- 사안에서 피고에 대한 소장 부분의 송달이 불가능한 상태에서 재판장이 주소보정을 명하였으나 원고가 이에 응하지 않거나 공시송달 요건도 갖추지 못한 상황이다. 쟁점으로 <소장 부분 송달 전후에 따른 소송 계속의 발생 여부를 기준으로 재판장의 소장각하명령과 법원의 소각하판결이 어떠한 차이가 있는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 피고에 대한 송달불능 상태에서 주소보정이 이루어지지 않은 경우 소장각하명령과 소각하판결의 차이점을 소송 계속의 발생 여부를 중심으로 설명한다.

II. 소장 부분의 송달과 소송계속의 발생

1. 소장 부분 송달의 의의

- 소장이 접수되면 법원은 이를 심사한 후 지체 없이 피고에게 소장 부분을 송달하여야 한다. 이는 피고에게 방어 기회 제공과 심판의 대상을 알리는 중요한 절차다.

2. 소송계속의 발생 시기

- 민사소송법상 소송계속은 소장 부분이 피고에게 적법하게 송달된 때에 발생한다. 소송계속이 발생하면 중복소제기 금지, 시효중단 등의 소송법적 효과가 발생하며, 이때부터 사건은 법원의 심판 대상으로서 완전히 정착된다.

III. 소장각하명령 [민사소송법 제254조]

1. 발생 단계 및 사유

- 소장 부분이 피고에게 송달되기 전, 즉 소송계속이 발생하기 전 단계에서 행해지는 조치다. 주소불명 등으로 인하여 소장 부분을 송달할 수 없는 경우 재판장은 주소보정을 명하고, 이에 응하지 않으면 명령으로 소장을 각하한다.

2. 성질 및 불복 방법

(1) 성질

- 재판장 개인의 권한으로 행하는 소송지휘적 처분이다. 소송계속 전이므로 변론을 거치지 않고 서면심사만으로 결정한다.

(2) 불복 방법

- 소장각하명령에 대해서는 즉시항고를 할 수 있다.

IV. 소각하판결 [민사소송법 제219조 등]

1. 발생 단계 및 사유

- 소장 부분이 피고에게 이미 송달되어 소송계속이 발생한 후의 단계에서 행해지는 조치다. 일단 송달은 되었으나 이후 소송요건의 흠결이 발견되거나, 공시송달 요건 미비 등으로 더 이상 절차 진행이 불가능하여 소송 자체가 부적법하다고 판단될 때 법원의 이름으로 내리는 재판이다.

2. 성질 및 불복 방법

(1) 성질

- 수소법원(합의부 또는 단독판사)이 내리는 종국판결이다. 원칙적으로 변론을 거쳐야 하나, 소송요건 흠결이 명백한 경우 변론 없이 판결할 수도 있다.

(2) 불복 방법

- 판결이므로 항소로써 불복하여야 한다.

V. 두 조치의 주요 차이점 비교

1. 주체와 형식의 차이

- 소장각하명령은 재판장 개인이 내리는 명령인 반면, 소각하판결은 당해 사건의 수소법원이 내리는 판결이다.

2. 소송계속 발생 여부에 따른 구별

(1) 소장각하명령

- 소장 부분이 송달되지 않아 소송계속이 발생하기 전의 조치다. 따라서 시효중단이나 제척기간 준수의 효력은 소급하여 소멸하게 된다.

(2) 소각하판결

- 이미 소장 부분이 송달되어 소송계속이 발생한 상태에서 내리는 재판이다. 즉, 법원이 사건을 수리하여 심리에 들어갔으나 형식적 요건 미비로 본안 심리를 거절하는 것이다.

3. 사안의 경우

- 丙이 丁의 주소를 보정하지 못해 소장 부분 자체가 송달되지 못한 단계라면 재판장은 소장각하명령을 내린다. 그러나 일단 송달은 되었으나 그 주소가 허위임이 판명되거나 공시송달 요건을 갖추지 못해 향후 절차 진행이 불가능한 사유가 소송계속 발생 후에 확인되었다면 소장하판결의 대상이 된다.

Ⅵ. 결론

- 소장각하명령과 소장하판결은 모두 소송의 흠결을 이유로 절차를 종료시키는 재판이라는 공통점이 있으나, 그 시점과 주체에서 명확히 구분된다. 소장각하명령은 소송계속 전 재판장의 권한으로 행하는 명령이며, 소장하판결은 소송계속 후 수소법원이 내리는 종국판결이다. 丙의 사례와 같이 주소보정 불이행 및 송달불능의 상황은 대개 소송계속 전 단계에 해당하므로 소장각하명령이 원칙적인 조치가 될 것이나, 구체적인 송달 여부에 따라 그 형식이 달라질 수 있다. 이를 정확히 구분하는 것은 원고의 불복 방법과 시효중단 등 실체법적 효과를 판단하는 데 있어 필수적이다.

<제3편 제1심의 소송절차.제06장 변론.제02절 심리에 관한 제 원칙>

[예상][6.02-1]처분권주의의 의의 및 적용 영역, 제한 및 예외, 위반의 효과

《【문제6.2-1】 처분권주의에 대해 설명하시오. (25점)》

<문제6.2의 물음1> 처분권주의의 의의 및 적용 영역, 제한 및 예외, 위반의 효과

I. 처분권주의의 의의 및 적용 영역

1. 처분권주의의 의의 ★

- 처분권주의란 민사소송법 제203조에 따라 소송의 개시, 심판대상 및 범위의 지정, 소송의 종료를 당사자의 의사에 맡기는 소송법상의 원칙을 말한다. 이는 실체법상의 사적자치의 원칙이 소송법적으로 구현된 것이다.

2. 적용 영역

(1) 소송의 개시 및 종료

- 소송은 원고의 소 제기에 의해서만 개시되며 법원이 직권으로 개시할 수 없다. 또한 당사자는 소의 취하, 청구의 포기·인낙, 소송상 화해를 통해 소송을 자유롭게 종료시킬 수 있다.

(2) 심판대상의 결정 및 범위

- 법원은 원고가 신청한 청구의 취지와 원인에 구속되므로, 신청하지 않은 청구에 대해 판결할 수 없고 신청 범위를 초과하여 판결할 수도 없다.

II. 처분권주의의 제한 및 예외

1. 공익적 성격에 따른 제한

(1) 가사소송 및 신분소송

- 혼인, 친자관계 등 신분관계 소송은 사회적 공익성이 크므로 당사자의 임의적 처분을 제한하고 직권탐지주의를 적용한다.

(2) 행정소송의 일부 영역

- 행정소송법은 법원이 필요하다고 인정할 때 직권으로 증거조사를 할 수 있도록 규정하여 처분권주의를 일부 제한하고 있다.

2. 형식적 형성의 소

(1) 공유물분할청구의 소

- 공유물분할청구의 소와 같이 법률관계의 형성을 법원의 재량에 맡기는 경우 법원은 당사자의 청구 방식에 구속되지 않고 독자적인 분할 방식을 결정할 수 있다.

(2) 경계확정의 소

- 토지의 경계확정을 구하는 소에서도 법원은 당사자가 주장하는 경계선에 구속되지 않고 객관적으로 정당한 경계를 확정하여야 한다.

III. 처분권주의 위반의 소송법상 효과 (상소사유)

1. 위반의 유형

(1) 양적 초과판결

- 원고가 청구한 수량이나 금액을 초과하여 판결하는 경우이다. 예를 들어 대여금 1,000만 원 청구에 대해 1,200만 원 인용 판결을 내리는 것은 처분권주의에 위배된다.

(2) 질적 초과판결

- 원고가 청구한 소송물과 전혀 다른 종류의 급부를 판결하는 경우이다. 이행의 소를 청구하였는데 법원이 직권으로 확인판결을 내리는 경우가 이에 해당한다.

2. 위반 판결의 효력 및 구제

(1) 상소에 의한 구제

- 처분권주의를 위반한 판결은 법령 위반의 하자가 있으므로 당사자는 상소(항소 또는 상고)를 제기하여 판결의 파기나 취소를 구할 수 있다.

(2) 확정 후의 효력

- 위반 판결이라도 당연무효는 아니며 재심사유(민사소송법 제451조)에도 해당하지 않으므로, 상소 제기 없이 판결이 확정되면 그 하자는 치유되고 기판력이 발생한다.

IV. 결론

- 처분권주의는 사적자치의 원칙을 민사소송 절차에 반영하여 당사자의 자주적인 분쟁 해결 의사를 존중하는 근간이다. 그러나 법적 안정성과 공익적 필요에 따라 형식적 형성의 소나 가사소송 등에서는 예외적으로 그 적용이 제한된다. 실무적으로 법원은 원고의 청구 취지와 원인을 엄격히 해석하여 처분권주의 위반으로 인한 심판 범위 일탈 및 상소 제기의 혼란을 방지하여야 할 것이다.

《【문제6.2-2】 주요사실과 간접사실에 대해 설명하시오. (25점)》

<문제6.2의 물음2> 주요사실과 간접사실의 개념, 구별기준, 소송법상 실익

I. 주요사실과 간접사실의 개념 정의

1. 주요사실의 의의

- 주요사실(요건사실)이란 권리의 발생·변경·소멸 등 법률효과를 발생시키는 실체법상의 법률요건에 직접 해당하는 사실을 말한다. 이는 변론주의가 적용되는 직접적인 심판 대상이 되므로, 당사자가 소송에서 주장하지 않으면 법원이 이를 판결의 기초로 삼을 수 없다.

2. 간접사실의 의의

- 간접사실이란 주요사실의 존재 여부를 경험칙에 의하여 추인하는 데 도움을 주는 사실을 의미한다. 이는 주요사실을 입증하기 위한 증거자료와 유사한 성격을 가지며, 당사자의 주장이 없더라도 법원이 변론의 전취지에 나타난 자료와 자유심증에 의하여 판결의 기초로 삼을 수 있다.

II. 양자의 구별 기준 (법률요건분류설적 관점)

1. 법률요건분류설의 내용 및 원칙

- 대법원은 주요사실과 간접사실을 구별할 때 실체법 규정의 구성요건을 기준으로 삼는 법률요건분류설(다수설)을 취하고 있다. 이에 따르면 법률효과를 규정한 법조문 자체에 명시된 요건사실만이 주요사실에 해당하며, 그 요건사실의 존재를 추단케 하는 사실들은 모두 간접사실에 불과하다.

2. 구체적 구별의 양상

(1) 주요사실의 구체적례

- 대여금 반환청구소송에서 소비대차계약의 체결, 목적물의 인도, 변제기의 도래 등은 법률효과 발생에 직접 필요한 요건이므로 주요사실이다.

(2) 간접사실의 구체적례

- 대여금 반환청구소송에서 돈을 건네줄 당시 당사자가 현장에 동석하였다는 사실이나 차용증을 작성하는 모습을 보았다는 목격자의 존재 등은 계약 체결이라는 주요사실을 추정케 하는 간접사실이다.

III. 구별의 소송법상 실익

1. 변론주의의 적용 여부

(1) 주장책임과 판결 기초의 제한

- 변론주의 원칙상 주요사실은 당사자가 반드시 주장하여야 하며, 법원은 주장하지 않은 주요사실을 판결의 기초로 삼을 수 없다. 반면 간접사실은 당사자의 명시적인 주장이 없더라도 증거조사 등 변론에 나타난 자료를 통해 법원이 직권으로 인정할 수 있다.

(2) 재판상 자백의 구속력

- 재판상 자백은 주요사실에 대해서만 성립하며, 자백이 성립하면 당사자와 법원을 구속하는 강력한 효력이 발생한다. 그러나 간접사실에 대한 자백은 자백의 구속력이 발생하지 않으므로, 법원은 이에 구속되지 않고 자유롭게 사실을 인정할 수 있다.

2. 석명권 및 이유 기재 범위

(1) 석명권의 대상

- 법원의 석명권은 당사자가 주장한 주요사실의 취지가 불분명하거나 모순이 있을 때 이를 명확히 하도록 유도하는 데 집중된다. 법원은 주장책임이 없는 간접사실에 대해서는 적극적으로 석명권을 행사할 의무가 없다.

(2) 판결서의 이유 기재 의무

- 법원은 판결서 이유에 당사자의 주장 중 법률상 요건에 해당하는 주요사실에 대한 판단만을 명시하면 족하다. 법원이 간접사실의 존부에 대하여 판결서에 일일이 판단을 기재하지 않더라도 기판력의 범위를 판단하는 데 영향을 미치지 않는다.

IV. 결론

- 주요사실과 간접사실의 구별은 당사자의 주장책임 범위를 명확히 규정하고 법원의 자의적인 판결을 방지하는 소송법상의 안전핀이다. 사법 자치와 적절한 재판을 보장하기 위해 법원은 법률요건분류설적 기준을 엄격하게 적용하여 변론주의의 적용 범위를 확정하되, 구체적 정의 실현을 위해 유기적으로 심리를 운영해야 할 것이다.

《【문제6.8】

<사례>

甲은 乙을 상대로 X 건물에 대한 소유권이전등기청구소송을 제기하여 제1심이 진행 중이다. 그런데 변론이 종결되기 전인 2023. 11. 1. 피고 乙이 교통 사고로 급작스럽게 사망하였다. 乙에게는 유일한 상속인으로 아들 丙이 있다.

당시 乙은 변호사 A를 소송대리인으로 선임하여 소송을 수행하게 한 상태였으며, A에게는 당해 심급의 소송행위뿐만 아니라 상소의 제기 등에 관한 특별수권도 부여되어 있었다. 이러한 사실을 알지 못한 법원은 변론기일을 진행하였고, 2023. 12. 1. 원고 甲의 승소 판결을 선고하였다.

또 다른 상황으로, 丁은 戊를 상대로 대여금 청구소송을 제기하였다. 소송 진행 중 丁은 파산선고를 받았고, 파산관재인으로 B가 선임되었다. 丁은 파산 선고 사실을 법원에 알리지 않은 채 계속해서 소송을 수행하고자 한다.

(물음1) 사례에서 피고 乙이 사망하였으나 소송대리인 A가 있는 경우, 민사소송법 제233조에도 불구하고 소송절차가 중단되지 않는 근거를 설명하고, 이 경우 선고된 판결의 효력 및 상속인 丙이 소송에 참여하기 위해 취해야 할 절차에 대하여 논하시오.》

<문제6.8의 물음1> 소송대리인이 있는 경우의 소송절차 중단 예외와 판결의 효력 및 수계절차

I. 문제의 제기

- 사안에서 소송 계속 중 피고 乙이 사망하였으나 소송대리인 A가 선임된 상태에서 소송이 진행되어 판결이 선고되었고, 원고 甲의 승소 판결이 선고된 상황이다. 쟁점으로 <소송대리인이 있는 경우 당사자의 사망에도 소송절차가 중단되지 않는지>와 <그에 따라 선고된 판결의 효력 및 상속인의 소송참가 절차>를 검토할 필요가 있다. 이하에서는 소송대리인이 있는 경우 소송절차 중단의 예외와 판결의 효력 및 상속인 丙의 소송참가 절차를 논한다.

II. 소송대리인이 있는 경우의 절차 중단 예외

1. 법적 근거 및 취지

(1) 법적 근거

- 민사소송법 제238조는 소송대리인이 있는 경우에는 당사자의 사망 등 중단 사유가 발생하더라도 소송절차가 중단되지 아니한다고 규정하고 있다.

(2) 제도적 취지

- 소송대리인이 있는 경우에는 당사자가 사망하더라도 소송대리인이 그 사무를 계속 처리할 수 있어 소송을 중단시킬 필요가 적고, 오히려 소송을 진행하는 것이 소송경제와 상대방의 이익 보호에 부합하기 때문이다.

2. 소송대리권의 불소멸

- 민법상의 위임 계약은 위임인의 사망으로 종료되나, 민사소송법 제95조 제1호는 소송대리권은 당사자의 사망으로 소멸하지 않는다고 규정하여 특칙을 두고 있다. 이에 따라 대리인 A의 소송대리권은 乙의 사망 후에도 상속인 丙을 위하여 유지된다.

III. 선고된 판결의 효력

1. 판례의 태도

(1) 원칙적 유효성

- 판례는 소송대리인이 있는 경우 당사자가 사망하더라도 소송절차는 중단되지 않으므로, 법원이 사망 사실을 알지 못한 채 망자를 그대로 당사자로 표시하여 판결을 선고하더라도 그 판결은 유효하다고 본다.

(2) 판결의 귀속 대상

- 이 경우 판결의 효력은 당연히 상속인에게 미치게 된다. 비록 판결서상 당사자 표시가 망자로 되어 있더라도, 이는 당사자 표시의 잘못에 불과할 뿐 실질적인 당사자는 상속인인 丙으로 확정된 것으로 본다.

2. 사안의 경우

- 법원이 2023. 12. 1. 선고한 甲 승소 판결은 소송대리인 A의 존재로 인하여 소송절차가 적법하게 진행된 상태에서 내려진 것이므로 유효하다. 해당 판결의 효력은 상속인 丙에게 귀속된다.

IV. 상속인 丙이 취해야 할 절차

1. 소송수계신청의 의의

- 소송수계란 소송계속 중 당사자에게 중단 사유가 발생한 경우, 그 소송물을 승계한 자가 중단된 소송을 인계받아 진행하는 절차를 말한다.

2. 수계절차의 개시 시점

(1) 심급의 종료와 중단

- 소송대리인이 있는 경우 해당 심급의 판결이 송달될 때까지는 소송절차가 중단되지 않는다. 그러나 판결이 송달된 후 다음 심급으로 이행하기 위한 준비 단계에서는 소송절차가 중단된다고 보는 것이 판례의 태도다.

(2) 수계신청의 방법

- 상속인 丙은 법원에 수계신청서와 함께 乙의 사망 및 자신이 유일한 상속인임을 증명하는 서류(가족관계증명서 등)를 제출하여야 한다. 법원은 이를 심사하여 수계 여부를 결정한다.

3. 당사자 표시정정

- 丙은 판결서상의 당사자 표시를 망자 乙에서 상속인 丙으로 바로잡기 위해 당사자 표시정정 신청을 병행할 수 있다. 이는 판결의 집행력을 명확히 하기 위해 필요한 절차다.

V. 결론

- 피고 乙이 사망하였으나 소송대리인 A가 선임되어 있으므로 민사소송법 제238조 및 제95조에 따라 소송절차는 중단되지 않으며 소송대리권도 소멸하지 않는다. 따라서 법원이 선고한 판결은 적법하고 유효하며, 그 효력은 상속인 丙에게 미친다. 丙은 판결 선고 이후 소송절차를 공식적으로 인계받기 위해 법원에 소송수계신청을 하여야 한다. 이러한 제도는 당사자의 갑작스러운 유고 시에도 소송대리인을 통해 절차의 안정성을 유지하고 원활한 권리구제를 도모하는 데 그 목적이 있다.

《【문제6.8】

<사례>

甲은 乙을 상대로 X 건물에 대한 소유권이전등기청구소송을 제기하여 제1심이 진행 중이다. 그런데 변론이 종결되기 전인 2023. 11. 1. 피고 乙이 교통 사고로 급작스럽게 사망하였다. 乙에게는 유일한 상속인으로 아들 丙이 있다.

당시 乙은 변호사 A를 소송대리인으로 선임하여 소송을 수행하게 한 상태였으며, A에게는 당해 심급의 소송행위뿐만 아니라 상소의 제기 등에 관한 특별권도 부여되어 있었다. 이러한 사실을 알지 못한 법원은 변론기일을 진행하였고, 2023. 12. 1. 원고 甲의 승소 판결을 선고하였다.

또 다른 상황으로, 丁은 戊를 상대로 대여금 청구소송을 제기하였다. 소송 진행 중 丁은 파산선고를 받았고, 파산관재인으로 B가 선임되었다. 丁은 파산 선고 사실을 법원에 알리지 않은 채 계속해서 소송을 수행하고자 한다.

(물음2) 원고 丁이 파산선고를 받은 경우 소송절차의 중단 여부를 판단하고, 만약 중단된다면 파산관재인 B가 소송을 인계받는 절차와 丁이 파산 선고 사실을 숨기고 받은 판결의 효력에 대하여 기술하시오.》

<문제6.8의 물음2> 원고의 파산선고에 따른 소송절차 중단과 수계 및 판결의 효력

I. 문제의 제기

- 사안에서 원고 丁이 소송 계속 중 파산선고를 받고 파산관재인 B가 선임되었음에도 파산 사실을 법원에 알리지 않은 채 계속 소송을 수행하려는 상황이다. 쟁점으로 <파산선고에 따른 소송절차의 중단 여부와 파산관재인에게 수계절차, 그리고 파산선고 사실을 숨긴 채 선고된 판결의 효력>을 검토할 필요가 있다. 이하에서는 원고의 파산선고에 따른 소송절차의 중단 여부와 수계절차 및 파산선고 사실을 숨기고 받은 판결의 효력을 기술한다.

II. 파산선고에 따른 소송절차의 중단

1. 중단의 법적 근거 및 요건

(1) 법적 근거

- 민사소송법 제239조 및 채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제347조에 의거하여, 파산재단에 속하는 재산에 관한 소송은 파산선고와 동시에 중단된다.

(2) 대상 소송

- 중단되는 소송은 파산재단에 속하는 재산에 관한 것이어야 한다. 대여금 청구소송은 파산재단을 구성하는 채권에 관한 것이므로 중단 대상에 해당한다.

2. 중단의 시기 및 예외

(1) 중단의 시점

- 파산선고가 내려진 때로부터 즉시 중단된다. 당사자가 그 사실을 알았는지 여부나 법원에 통지되었는지 여부와 관계없이 법률상 당연히 중단된다.

(2) 소송대리인이 있는 경우의 예외

- 당사자 사망의 경우와 마찬가지로, 파산한 당사자에게 소송대리인이 있는 경우에는 민사소송법 제238조가 준용되어 소송절차가 중단되지 않는다. 다만 사안에서는 丁이 직접 소송을 수행하고 있는 것으로 보이므로 중단 사유가 발생한다.

III. 파산관재인 B의 소송수계절차

1. 수계의 주체 및 시기

- 파산재단에 관한 소송물은 파산관재인에게 관리처분권이 이전되므로, 파산관재인 B가 소송을 수계하여야 한다. 파산관재인은 파산선고 후 즉시 또는 중단된 사실을 안 때로부터 수계신청을 할 수 있다.

2. 수계절차의 방식

(1) 수계신청

- 파산관재인 B는 법원에 파산선고 결정문 사본과 관재인 선임 증명서를 첨부하여 소송수계신청서를 제출한다.

(2) 법원의 결정

- 법원은 수계신청이 있으면 상대방에게 이를 통지하고, 수계의 적법성을 심사하여 절차를 재개한다. 만약 수계신청이 이유 없다고 판단되면 결정으로 이를 기각한다.

IV. 파산 사실을 숨기고 받은 판결의 효력

1. 중단 중의 소송행위 및 판결의 효력

(1) 소송행위의 유효성

- 소송절차가 중단된 상태에서 행해진 소송행위는 원칙적으로 무효다. 그러나 판례는 절차 중단 중임을 알지 못하고 진행된 소송행위라도 후에 수계인이 이를 추인하면 유효해질 수 있다고 본다.

(2) 판결의 효력

- 법원이 중단 사유를 알지 못하고 판결을 선고한 경우, 그 판결은 당연히 무효는 아니며 대리권 흠결이 있는 판결과 유사하게 취급된다. 즉, 상소나 재심을 통해 취소할 수 있는 상태에 놓이게 된다.

2. 파산관재인 B의 구제 수단

(1) 상소의 제기

- 판결이 송달되기 전이라면 수계절차를 밟아 소송을 재개해야 하며, 이미 판결이 선고된 경우라면 파산관재인은 판결의 무효를 주장하며 상소를 제기하거나 상소 절차에서 수계하여 다룰 수 있다.

(2) 재심의 청구

- 판결이 확정되었다면 민사소송법 제451조 제1항 제3호를 유추적용하여 대리권의 흠결 등을 이유로 재심을 청구할 수 있다는 것이 일반적인 견해다.

V. 결론

- 원고 丁이 파산선고를 받은 순간 대여금 청구소송은 법률상 당연히 중단된다. 丁은 파산재단에 대한 관리처분권을 상실하였으므로 더 이상 소송을 수행할 자격이 없다. 파산관재인 B는 법원에 수계신청을 하여 소송을 인계받아야 하며, 丁이 파산 사실을 숨기고 받은 판결은 절차상 중대한 하자가 있는 재판으로서 상소나 재심의 대상이 된다. 법원은 소송의 적법한 진행을 위해 당사자의 파산 여부를 엄격히 확인하여 파산관재인에 의한 절차 수행을 보장하여야 한다.

《【문제7.2】

<사례>

甲은 乙을 상대로 1억 원의 대여금 청구소송을 제기하였다. 甲은 소장에서 2023. 1. 1. 乙에게 1억 원을 이자 월 1%로 정하여 대여하였다는 사실을 주장하였다. 이에 대하여 乙은 제1회 변론기일에 출석하여 돈을 빌린 것은 맞지만 이미 전액 변제하였다고 답변하였다. 이후 소송이 진행되던 중 乙은 제3회 변론기일에서 사실은 돈을 빌린 적이 없으며, 이전의 진술은 착오에 의한 것이었다고 주장하며 기존 진술을 취소하겠다는 의사를 표시하였다.

한편, 丙은 도로 관리 주체인 지방자치단체 丁을 상대로 도로 파손으로 인한 자동차 파손 손해배상청구소송을 제기하였다. 丙은 사고 당시 해당 지역에 이례적인 폭우가 내려 도로가 유실되었음을 주장하였으나, 이에 관한 별도의 기상자료를 제출하지는 않았다. 丁은 그러한 폭우가 내린 사실이 없다고 다투고 있다. 또한, 이 사건 심리 중 법원은 해당 지역의 지적도와 토지대장의 내용 등 공공기관에 비치된 기록에 나타난 사실을 토대로 丙의 과실 여부를 판단하고자 한다.

(물음1) 乙이 제1회 변론기일에 행한 진술의 법적 성질을 재판상 자백의 요건과 관련하여 검토하고, 제3회 변론기일에서 행한 자백 취소의 허용 여부 및 그 요건에 대하여 판례의 태도를 근거로 논하시오.》

<문제7.2의 물음1> 재판상 자백의 성립 요건과 자백 취소의 허용 여부 및 요건

I. 문제의 제기

- 사안에서 甲이 제기한 대여금 청구소송에서 乙은 처음에는 대여사실은 인정하면서 변제항변을 하였다가 이후 대여사실 자체를 부인하며 종전 진술을 취소한 상황이다. 쟁점으로 <진술이 재판상 자백에 해당하는지>와 <자백취소의 허용 여부>를 검토할 필요가 있다. 이하에서는 재판상 자백의 성립요건과 그 법적 효력, 자백취소의 허용요건 및 판례의 태도를 논한다.

II. 재판상 자백의 성립 요건

1. 의의 및 대상

- 재판상 자백이란 변론 또는 기일에서 당사자가 상대방이 주장하는 자기에게 불리한 구체적 사실을 인정하는 진술이다. 자백의 대상은 원칙적으로 사실에 한하며, 법률적인 판단이나 권리관계에 대한 인정을 의미하는 것은 아니다.

2. 주요 요건

(1) 상대방의 주장과 일치할 것

- 상대방이 주장하는 사실과 당사자의 진술이 내용상 일치하여야 한다.

(2) 자기에게 불리한 사실의 인정일 것

- 자백이 성립하려면 당사자가 인정하는 사실이 그 당사자에게 불리한 것이어야 한다. 여기서 불리한 사실이란 상대방이 입증책임을 지는 사실을 의미하는 것이 통설 및 판례의 태도다.

(3) 구체적 사실에 관한 진술일 것

- 단순한 가치판단이 아니라 경험할 수 있는 구체적인 과거의 사실에 대한 인정이어야 한다.

III. 乙의 제1회 변론기일 진술의 법적 성질

1. 자백의 성립 여부 검토

- 사안에서 원고 甲은 1억 원의 대여 사실을 주장하였고, 피고 乙은 돈을 빌린 것은 맞다고 진술하였다. 이는 甲의 청구원인 사실을 乙이 그대로 시인한 것이며, 대여 사실의 입증책임은 원고인 甲에게 있으므로 乙에게는 불리한 사실에 해당한다. 따라서 乙의 진술 중 대여 사실에 관한 부분은 재판상 자백이 성립한다.

2. 이익불리진술과 항변의 구별

- 乙은 대여 사실을 인정함과 동시에 전액 변제하였다는 사실을 추가로 주장하였다. 이를 소송법상 재판상 자백과 항변이 결합된 형태인 행위적 자백 또는 가정적 자백의 관점에서 볼 수도 있으나, 일반적으로는 원고의 주장 사실을 인정(자백)하고 별개의 소멸 사유를 주장(항변)한 것으로 본다. 변제 사실은 乙에게 유리한 사실이므로 자백의 대상이 아니며, 오직 돈을 빌렸다는 부분에 대해서만 자백의 효력이 발생한다.

IV. 자백 취소의 허용 여부 및 요건

1. 원칙적 불가변성

- 재판상 자백이 성립하면 법원은 그 자백에 구속되어 그와 반대되는 사실을 인정할 수 없고, 당사자 역시 임의로 자백을 취소할 수 없는 것이 원칙이다.

2. 예외적 취소 요건 (판례의 태도)

- 민사소송법상 자백의 취소는 다음의 경우에 한하여 예외적으로 허용된다.

(1) 상대방의 동의가 있는 경우

- 상대방이 자백의 취소에 동의하면 언제든지 취소할 수 있다.

(2) 자백이 진실에 어긋나고 착오로 말미암은 것이 증명된 경우

- 판례는 자백을 취소하려는 자가 자백이 진실에 반한다는 사실과 착오로 인한 것이라는 사실을 모두 증명하여야 한다고 본다. 이때 진실에 반한다는 사실이 증명되면 착오에 의한 자백임이 사실상 추정된다는 것이 판례의 완화된 입장이다.

(3) 형사상 처벌할 수 있는 행위에 의한 경우

- 자백이 제3자의 강박 등 형사상 처벌 대상이 되는 행위로 인하여 이루어진 경우 재심 사유에 준하여 취소가 가능하다.

V. 사안의 적용

1. 乙의 진술 번복의 효력

- 乙은 제3회 변론기일에 돈을 빌린 적이 없다며 기존의 자백을 취소하였다. 乙이 이 취소를 유효하게 하기 위해서는 단순히 착오였다고 주장하는 것만으로는 부족하며, 실제로 돈을 빌리지 않았다는 객관적 사실(진실에 반함)을 입증하여야 한다.

2. 판례에 근거한 판단

- 만약 乙이 금융거래 내역이나 계약서의 부존재 등을 통해 대여 사실이 없었음을 증명한다면, 특별한 사정이 없는 한 착오에 의한 자백으로 인정되어 취소가 허용될 수 있다. 그러나 증명을 하지 못한다면 자백의 구속력이 유지되어 법원은 대여 사실을 그대로 기초로 삼아 판결하여야 한다.

Ⅵ. 결론

- 乙이 제1회 변론기일에서 행한 진술 중 대여 사실에 관한 부분은 재판상 자백에 해당하여 법원과 당사자를 구속한다. 乙이 제3회 변론기일에서 이를 취소하기 위해서는 해당 자백이 진실에 반하고 착오에 의한 것임을 증명하여야 한다. 乙이 이를 성공적으로 증명할 경우에만 자백의 효력에서 벗어날 수 있으며, 그렇지 못할 경우 법원은 乙이 주장하는 변제 사실의 존부만을 심리하게 된다. 이는 소송의 안정성과 신의칙을 보호하기 위한 민사소송법상의 핵심적 원칙이다.

《【문제7.2】

<사례>

甲은 乙을 상대로 1억 원의 대여금 청구소송을 제기하였다. 甲은 소장에서 2023. 1. 1. 乙에게 1억 원을 이자 월 1%로 정하여 대여하였다는 사실을 주장하였다. 이에 대하여 乙은 제1회 변론기일에 출석하여 돈을 빌린 것은 맞지만 이미 전액 변제하였다고 답변하였다. 이후 소송이 진행되던 중 乙은 제3회 변론기일에서 사실은 돈을 빌린 적이 없으며, 이전의 진술은 착오에 의한 것이었다고 주장하며 기존 진술을 취소하겠다는 의사를 표시하였다.

한편, 丙은 도로 관리 주체인 지방자치단체 丁을 상대로 도로 파손으로 인한 자동차 파손 손해배상청구소송을 제기하였다. 丙은 사고 당시 해당 지역에 이례적인 폭우가 내려 도로가 유실되었음을 주장하였으나, 이에 관한 별도의 기상자료를 제출하지는 않았다. 丁은 그러한 폭우가 내린 사실이 없다고 다투고 있다. 또한, 이 사건 심리 중 법원은 해당 지역의 지적도와 토지대장의 내용 등 공공기관에 비치된 기록에 나타난 사실을 토대로 丙의 과실 여부를 판단하고자 한다.

(물음2) 사례에서 丙이 주장하는 폭우 사실과 법원이 인지한 지적도의 내용 등이 현저한 사실로서 증명을 요하지 않는 사항에 해당하는지 여부를 구분하여 설명하고, 이러한 사실을 근거로 판결하기 위해 필요한 절차적 요건을 기술하시오.》

<문제7.2의 물음2> 현저한 사실의 의의와 범위 및 이를 근거로 한 판결의 절차적 요건

I. 문제의 제기

- 사안에서 지방자치단체 丁을 상대로 도로파손으로 인한 자동차 파손 손해배상청구소송을 제기한 丙은 이례적인 폭우로 도로가 유실되었다는 사실을 주장하나 별도의 증거를 제출하지 않았고, 법원은 공공기관에 비치된 지적도와 토지대장의 내용을 기초로 판단하고자 하는 상황이다. 쟁점으로 <폭우 사실과 지적도 등의 내용이 현저한 사실로서 증명을 요하지 않는 사항에 해당하는지>와 <이를 판결의 기초로 삼기 위한 절차적 요건>을 검토할 필요가 있다. 이하에서는 폭우 사실과 지적도 등의 내용이 현저한 사실에 해당하는지, 이를 판결의 기초로 하기 위한 절차적 요건을 기술한다.

II. 현저한 사실의 의의 및 종류

1. 의의

- 현저한 사실이란 법관이 증거조사를 거치지 않고도 그 존부를 확신할 수 있을 정도로 객관적으로 명백한 사실을 말한다. 이러한 사실은 증명을 요하지 않으므로 변론주의의 예외가 된다.

2. 종류

(1) 공지의 사실

- 일반 사회인에게 널리 알려져 있어 보통의 지식과 경험을 가진 사람이라면 누구나 의심하지 않을 정도로 알려진 사실이다. 예컨대 전쟁, 천재지변, 널리 알려진 역사적 사실 등이 이에 해당한다.

(2) 직무상 현저한 사실

- 법관이 그 직무 수행 과정에서 경험하여 알고 있는 사실로서, 명확한 기록 등에 의하여 증명 없이도 확신을 가질 수 있는 사실이다.

III. 사안에서의 현저한 사실 해당 여부 판단

1. 이례적인 폭우 사실 (공지의 사실 여부)

(1) 판단 기준

- 천재지변이나 기상 현상이 현저한 사실이 되기 위해서는 해당 지역 사회에서 누구나 알 수 있을 정도의 규모와 영향력을 가져야 한다.

(2) 사안의 경우

- 사안의 폭우가 이례적이고 도로가 유실될 정도의 대규모 재해였다면 공지의 사실로서 현저한 사실에 해당할 여지가 크다. 다만, 특정 일시와 국소적 지역에 내린 비의 양은 객관적 자료 없이 법관이 당연히 안다고 단정하기 어려우므로, 판례는 기상청의 관보나 기록 등에 의하여 확인되지 않는 한 원칙적으로 증명을 요하는 사실로 보는 경향이 있다.

2. 지적도와 토지대장의 내용 (직무상 현저한 사실 여부)

(1) 판단 기준

- 공공기관이 작성하여 보관하는 기록이라 하더라도, 법관이 당해 사건이나 과거에 취급한 사건을 통해 구체적으로 인지하고 있는 기록이 아니라면 단순히 비치되어 있다는 사실만으로 직무상 현저한 사실이라 할 수 없다.

(2) 사안의 경우

- 법원이 인지한 지적도나 토지대장의 내용은 공적 기록에 불과하며, 법관이 직무상 당연히 알고 있는 사실이라고 보기 어렵다. 판례 역시 관공서에 비치된 대장이나 도면의 기재 내용은 특별한 사정이 없는 한 현저한 사실로 보지 않으며 증거조사를 거쳐야 한다고 본다.

IV. 사실을 근거로 판결하기 위한 절차적 요건

1. 석명의무와 의견진술 기회의 부여

(1) 의의

- 법원이 현저한 사실을 판결의 기초로 삼고자 할 때에는 당사자가 예상하지 못한 불의의 판결을 받지 않도록 소송관계에 대하여 질문하거나 입증을 촉구하는 석명권을 행사하여야 한다.

(2) 절차적 요건

- 법원은 인지한 현저한 사실에 대하여 당사자에게 변론의 기회를 주어야 한다. 특히 당사자가 주장하지 않은 사실을 법원이 직권으로 인지하여 판결의 기초로 삼을 경우, 해당 사실의 존부와 그에 따른 법적 결과에 대해 당사자가 다룰 수 있도록 지적의무를 다하여야 한다.

2. 변론주의와의 관계

- 현저한 사실은 증명을 요하지 않으나, 사실의 주장 자체는 변론주의의 원칙상 당사자가 하여야 한다. 법원이 당사자가 주장하지도 않은 사실을 현저한 사실이라는 이유만으로 직권으로 도입하여 판결하는 것은 변론주의 위반이 될 수 있다. 따라서 법원은 당사자에게 해당 사실을 주장하도록 유도하거나, 최소한 그 사실에 대한 의견을 물어야 한다.

V. 결론

- 사안에서 이례적인 폭우 사실은 그 규모와 명백성에 따라 공지의 사실로서 현저한 사실이 될 수 있으나, 지적도나 토지대장의 기재 내용은 증거조사를 요하는 일반 사실로 보아야 한다. 법원이 이러한 사실들을 근거로 丙의 과실을 판단하기 위해서는 단순히 직권으로 인지하는 것에 그치지 않고, 변론기일에서 당사자에게 해당 사실에 대한 지적을 함으로써 의견 진술과 반박의 기회를 부여하는 절차적 정당성을 확보하여야 한다. 이는 실체적 진실 발견과 당사자의 절차적 기본권 보장 사이의 조화를 꾀하기 위함이다.

《【문제7.6-1】 법률상 추정에 대해 설명하시오. (25점)》

<문제7.6의 물음1> 법률상 추정의 의의 및 사실상 추정과의 구별, 분류, 효과

I. 법률상 추정의 의의 및 사실상 추정과의 구별

1. 법률상 추정의 의의

- 법률상 추정이란 법률이 정한 규정에 따라 어떤 전제사실이 증명되면 이로부터 다른 추정사실 또는 권리관계의 존재를 당연히 인정하는 소송법상 제도를 말한다. 이는 실체법적 권리 보호와 증명곤란의 구제를 목적으로 한다.

2. 사실상 추정과의 구별

- 사실상 추정은 법률의 명문 규정 없이 법관이 자유심증과 일반적인 경험칙에 의하여 전제사실로부터 추정사실을 추단하는 신빙성 평가의 영역이다. 반면 법률상 추정은 법률이 직접 전제사실과 추정사실 간의 인과적 연결을 규정하고 있으므로 법관의 자유심증이 제한된다는 점에서 구별된다.

II. 법률상 추정의 분류

1. 법률상 사실추정

- 전제사실의 증명을 통해 다른 사실의 존재를 법률상 추정하는 경우를 말한다. 예를 들어 점유자가 점유 개시 시와 그 후의 어느 시점에 점유한 사실이 증명되면 그 사이의 점유는 계속된 것으로 추정하는 것(민법 제198조)이 이에 해당한다.

2. 법률상 권리추정

- 어떤 사실의 증명을 통해 특정한 권리 또는 법률관계의 존재를 법률상 추정하는 경우이다. 동산의 점유자가 그 동산에 대하여 행사하는 권리는 적법하게 보유한 것으로 추정하는 것(민법 제200조)이나 부동산 등기의 추정력이 대표적이다.

III. 소송법상 효과 (증명책임의 전도 및 상대방의 반증 제시 의무)

1. 증명책임의 완화와 전도

- 추정의 이익을 받는 당사자는 법률상 추정된 사실이나 권리 자체를 직접 증명할 필요가 없다. 단지 추정의 바탕이 되는 전제사실만을 증명하면 족하므로 입증의 곤란이 획기적으로 완화된다. 전제사실이 증명되면 추정사실에 대한 증명책임은 이를 다투는 상대방에게 전도된다.

2. 상대방의 방어 방법과 증명의 성질

(1) 전제사실에 대한 반증

- 추정의 상대방은 추정의 기초가 되는 전제사실 자체를 부정하여 추정력의 발생을 차단할 수 있다. 전제사실은 상대방이 증명책임을 지는 것이 아니므로, 상대방은 이에 대해 법관에게 의심을 심어주는 수준의 반증만을 제시하면 족하다.

(2) 추정사실 또는 권리에 대한 본증

- 전제사실이 확정된 경우 상대방이 추정의 효과를 깨뜨리기 위해서는 추정된 사실이나 권리가 실제로 존재하지 않음을 적극적으로 증명하여야 한다. 이는 상대방에게 증명책임이 전도된 결과이므로 단순한 의심 유발을 넘어 확실한 확신을 주는 본증을 제시하여야 한다.

IV. 결론

- 법률상 추정은 소송법상 증명의 어려움을 겪는 당사자를 구제하고 실체법상 권리관계를 두텁게 보호하기 위한 법정책적 조율 장치이다. 법원은 법률상 추정 규정을 엄격하게 해석하여 자의적인 사실 인정을 방지하되, 증명책임의 분배 원칙과 상대방의 방어 수단인 본증 및 반증의 체계를 유기적으로 조화시킴으로써 민사재판의 적정과 실체적 진실 발견을 균형 있게 달성해야 할 것이다.

<제4편 소송의 종료.제09장 당사자 행위에 의한 종료.제02절 청구의 포기·인낙>

[예상][9.02-1]강박에 의한 청구인낙에 대한 불복 방법 및 그 요건

《【문제9.2】

<사례>

甲은 乙을 상대로 1억 원의 대여금 청구소송을 제기하였다. 소송 진행 중 乙은 자신의 채무를 인정하고 조속히 분쟁을 종결하기 위해 제2회 변론기일에 출석하여 甲의 청구가 전부 정당함을 시인하는 청구의 인낙 의사를 표시하였다. 법원 사무관은 이를 변론조서에 기재하였고, 이에 따라 청구인낙조서가 작성되었다.

그런데 乙은 인낙조서가 작성된 후 2주가 지난 시점에서, 당시 자신이 극심한 궁박 상태에 있었으며 甲의 강박에 의해 어쩔 수 없이 인낙의 의사표시를 한 것이라고 주장하며 해당 조서의 효력을 다투고자 한다. 또한 乙은 위 대여금 채무가 이미 소멸시효가 완성되었음에도 불구하고 이를 간과하고 인낙하였다는 사실을 뒤늦게 깨달았다.

한편, 별개의 소송에서 丙은 丁을 상대로 소유권이전등기청구소송을 제기하였다. 丁은 변론기일에 출석하지 않고 미리 청구의 인낙 의사가 담긴 답변서를 제출하였으나, 해당 답변서에는 丁의 인감증명서가 첨부되어 있지 않았다. 법원은 丁이 출석하지 않은 상태에서 위 서면에 기재된 내용대로 청구인낙이 성립한 것으로 처리할 수 있는지 고민하고 있다.

(물음1) 청구의 인낙이 성립하기 위한 요건 중 당사자의 처분권과 관련하여, 강박에 의한 인낙의 의사표시가 있었을 경우 乙이 확정판결과 동일한 효력이 있는 인낙조서에 대하여 취할 수 있는 불복 방법 및 그 요건을 설명하시오.》

<문제9.2의 물음1> 강박에 의한 청구인낙에 대한 불복 방법 및 그 요건

I. 문제의 제기

-사안에서 乙은 대여금청구소송에서 청구를 전부 인낙하여 청구인낙조서가 작성된 후 강박에 의한 인낙과 소멸시효 완성 사실을 이유로 그 효력을 다투려는 상황이다. 쟁점으로 <청구의 인낙이 처분권주의의 대상이 되는 요건과 강박에 의한 인낙이 있는 경우 인낙조서에 대하여 취할 수 있는 불복방법 및 그 요건>을 검토할 필요가 있다. 이하에서는 강박에 의한 청구인낙의 효력을 전제로 인낙조서에 대한 불복방법과 그 요건을 설명한다.

II. 청구인낙의 성립과 효력

1. 의의 및 성립요건

-청구의 인낙은 피고가 원고의 청구권의 존재를 인정하는 법원에 대한 의사표시이다. 이는 당사자가 자유롭게 처분할 수 있는 권리관계에 관한 것이어야 하며, 그 의사표시가 변론조서 등에 기재됨으로써 성립한다.

2. 인낙조서의 효력

-민사소송법 제220조에 따라 청구의 인낙을 기재한 조서는 확정판결과 동일한 효력을 가진다. 따라서 기판력과 집행력이 발생하며, 더 이상 동일한 사안으로 다룰 수 없는 것이 원칙이다.

III. 인낙조서에 대한 불복 방법 (준재심의 소)

1. 준재심의 소의 의의

-민사소송법 제461조에 따라 재판상 화해나 청구의 인낙 등 확정판결과 동일한 효력이 있는 조서에 대하여, 재심 사유와 같은 중대한 하자가 있는 경우 그 효력을 다투기 위해 제기하는 소송이다.

2. 불복 방법의 한정성

-판례는 재판상 화해나 인낙조서에 기판력이 인정되므로, 그 조서가 당연무효인 사유(예 : 당사자의 부존재 등)가 없는 한 오로지 준재심의 소에 의해서만 그 효력을 다투 수 있다고 본다. 따라서 乙은 별개의 소를 제기하거나 기판력을 무시할 수 없고 준재심을 제기하여야 한다.

IV. 준재심의 소의 요건

1. 재심 사유의 존재

-준재심은 민사소송법 제451조가 규정한 재심 사유가 있어야 한다. 사안과 관련하여 다음의 사유가 검토된다.

(1) 제451조 제1항 제5호 (형사상 처벌 행위)

-강박에 의해 인낙이 이루어진 경우, 그 강박행위가 형사상 처벌을 받을 수 있는 범죄행위에 해당하고 그에 관한 유죄의 확정판결이 있거나 증거부족 외의 이유로 확정판결을 얻을 수 없는 때에는 재심 사유가 된다.

(2) 의사표시의 하자 준용 여부

-판례는 재판상 화해나 인낙과 같은 소송행위에도 민법상의 의사표시에 관한 규정(제109조 착오, 제110조 강박 등)이 적용될 수 있다고 본다. 다만, 소송절차의 안정을 위해 이를 재심 사유인 판결의 기초가 된 서류의 위조 등에 준하는 사유로 엄격히 해석한다.

2. 제척기간의 준수

-준재심의 소는 재심 사유를 안 날로부터 30일 이내, 조서가 작성된 날로부터 5년 이내에 제기하여야 한다.

V. 사안의 적용

1. 乙의 불복 수단

-乙은 인낙조서가 작성된 지 2주가 경과하였으므로, 30일의 단기 제척기간 내에 준재심의 소를 제기하여야 한다. 乙이 주장하는 강박은 민법 제110조에 해당하므로 소송행위의 취소 사유가 될 수 있다.

2. 요건 구비 여부

-乙은 甲의 강박 행위가 형사상 처벌 대상임을 입증하거나, 소송행위 당시 의사결정의 자유가 완전히 박탈될 정도의 강박이 있었음을 증명하여야 한다. 단순히 소멸시효 완성을 간과했다는 실체법적 사유만으로는 준재심 사유가 되기 어려우나, 강박으로 인한 의사표시의 하자가 인정된다면 준재심을 통해 조서의 효력을 취소할 수 있다.

VI. 결론

-乙은 확정판결과 동일한 효력을 가지는 인낙조서를 다투기 위해 민사소송법 제461조에 따른 준재심의 소를 제기하여야 한다. 이때 乙은 甲의 강박행위가 재심 사유에 해당함을 증명하여야 하며, 재심 사유를 안 날로부터 30일 이내에 소를 제기하여야 한다는 절차적 요건을 준수하여야 한다. 만약 준재

심이 인용된다면 인낙조서의 효력은 소급하여 상실되고, 원래의 소송절차가 부활하여 대여금 채무의 존부를 다시 심리하게 된다.

<제4편 소송의 종료.제09장 당사자 행위에 의한 종료.제02절 청구의 포기·인낙>
[예상][9.02-2]서면에 의한 청구인낙의 성립 요건 및 기판력의 범위와 효력 부인

《【문제9.2】

<사례>

甲은 乙을 상대로 1억 원의 대여금 청구소송을 제기하였다. 소송 진행 중 乙은 자신의 채무를 인정하고 조속히 분쟁을 종결하기 위해 제2회 변론기일에 출석하여 甲의 청구가 전부 정당함을 시인하는 청구의 인낙 의사를 표시하였다. 법원 사무관은 이를 변론조서에 기재하였고, 이에 따라 청구인낙조서가 작성되었다.

그런데 乙은 인낙조서가 작성된 후 2주가 지난 시점에서, 당시 자신이 극심한 공박 상태에 있었으며 甲의 강박에 의해 어쩔 수 없이 인낙의 의사표시를 한 것이라고 주장하며 해당 조서의 효력을 다투고자 한다. 또한 乙은 위 대여금 채무가 이미 소멸시효가 완성되었음에도 불구하고 이를 간과하고 인낙하였다는 사실을 뒤늦게 깨달았다.

한편, 별개의 소송에서 丙은 丁을 상대로 소유권이전등기청구소송을 제기하였다. 丁은 변론기일에 출석하지 않고 미리 청구의 인낙 의사가 담긴 답변서를 제출하였으나, 해당 답변서에는 丁의 인감증명서가 첨부되어 있지 않았다. 법원은 丁이 출석하지 않은 상태에서 위 서면에 기재된 내용대로 청구인낙이 성립한 것으로 처리할 수 있는지 고민하고 있다.

(물음2) 丁이 제출한 답변서에 의한 청구인낙의 가부(서면에 의한 인낙)와 관련하여 민사소송법 제148조 및 제248조의 취지를 검토하고, 청구인낙이 성립하였을 때 발생하는 기판력의 범위와 소멸시효 완성 등 실체법상 사유를 근거로 인낙조서의 효력을 부인할 수 있는지 여부를 기술하시오.》

<문제9.2의 물음2> 서면에 의한 청구인낙의 성립 요건 및 기판력의 범위와 효력 부인

I. 문제의 제기

- 사안에서 丁이 변론기일에 출석하지 않은 채 인감증명서가 첨부되지 않은 청구인낙 취지의 답변서를 제출한 상황에서 그 서면에 의한 청구인낙의 성립 여부와, 청구인낙조서의 효력을 실체법상 사유로 다투려는 상황이다. 쟁점으로 <서면에 의한 청구인낙의 허용 요건과 인감증명서 첨부 필요 여부, 청구인낙 성립 시 발생하는 기판력의 범위 및 소멸시효 완성 등 실체법상 사유를 이유로 인낙조서의 효력을 부인할 수 있는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 서면에 의한 청구인낙의 성립 여부와 청구인낙 성립 시 기판력의 범위 및 실체법상 사유에 의한 인낙조서 효력 부인 가능성을 기술한다.

II. 서면에 의한 청구인낙의 성립 가부

1. 관련 규정의 취지

(1) 민사소송법 제148조 (진술간주)

- 당사자가 변론기일에 출석하지 아니하고 소장·답변서 그 밖의 준비서면을 제출한 때에는 그 서면에 기재된 사항을 진술한 것으로 본다. 다만, 화해·인낙 등 처분적 소송행위는 원칙적으로 구술에 의하여야 하므로 제148조만으로는 성립되지 않는다.

(2) 민사소송법 제248조 (서면에 의한 인낙 등)

- 2002년 개정 민사소송법은 소송계속 후 당사자가 청구의 인낙 취지가 적힌 서면을 제출하고 공증기관의 인증을 받거나 인감증명서를 첨부한 경우에는, 상대방이 기일에 출석하여 이를 원용함으로써 기일 불출석 상태에서도 인낙이 성립할 수 있도록 규정하였다.

2. 사안의 경우 (인감증명서 미첨부의 효과)

- 사안에서 丁은 답변서에 인감증명서를 첨부하지 않았다. 민사소송법 제248조 제1항은 본인의 의사를 명확히 확인하기 위해 인감증명서의 첨부 또는 공증을 필수적 요건으로 규정하고 있다. 따라서 丁이 기일에 불출석한 상태에서 인감증명서가 없는 답변서만으로는 청구인낙이 성립할 수 없으며, 법원은 이를 처리할 수 없다.

III. 인낙조서의 기판력과 실체법상 사유

1. 기판력의 발생 및 범위

(1) 발생 근거

- 청구인낙이 조서에 기재되면 확정판결과 동일한 효력이 발생한다.(민사소송법 제220조) 이에 따라 기판력이 발생하며, 당사자는 동일한 청구에 대하여 나중에 다시 다투 수 없다.

(2) 시적 범위

- 기판력은 원칙적으로 인낙의 의사표시가 조서에 기재된 시점을 기준으로 발생한다. 이 시점 이전에 존재하였던 모든 공격방어방법은 차단되는 차단효과 발생한다.

2. 실체법상 사유에 의한 효력 부인 여부

(1) 소멸시효 완성 등의 사유

- 소멸시효 완성과 같은 실체법상 사유는 인낙 성립 이전에 존재하던 사정이다. 확정판결과 동일한 효력이 있는 조서에 대하여는 기판력의 차단효과 적용되므로, 인낙 이후에 '사실은 시효가 완성되었었다'는 사유를 내세워 조서의 효력을 다투는 것은 허용되지 않는다.

(2) 예외적 불복 방법

- 인낙조서의 효력을 부인하기 위해서는 당연히무 사유가 있거나, 준재심 사유가 있어야 한다. 단순히 실체법적 사실관계의 착오나 권리 소멸 사유를 뒤늦게 깨달았다는 것만으로는 준재심 사유에 해당하지 않으므로 효력을 부인할 수 없다.

IV. 사안의 적용

1. 丁의 사례

- 丁의 경우 답변서에 인감증명서가 첨부되지 않았으므로 서면에 의한 인낙은 성립하지 않는다. 법원은 丁에게 보정을 명하거나, 기일에 출석하여 직접 의사를 표시하도록 유도하여야 한다.

2. 乙의 사례

- 乙은 이미 인낙조서가 성립하였으므로 기판력의 구속을 받는다. 乙이 뒤늦게 주장하는 '소멸시효 완성'은 인낙 이전에 발생한 사유로서 기판력의 차단효과에 의해 더 이상 주장할 수 없다. 따라서 乙은 실체법상 사유만으로는 인낙조서의 효력을 부인할 수 없다.

V. 결론

- 서면에 의한 청구인낙은 당사자의 진정한 의사를 확인하기 위해 법정된 요건(인감증명서 첨부 등)을 엄격히 갖추어야 하므로, 丁의 답변서만으로는 인낙이 성립하지 않는다. 또한 청구인낙이 일단 유효하게 성립하여 조서가 작성되면 확정판결과 동일한 기판력이 발생하므로, 乙과 같이 소멸시효 완성 등의 실체법상 사유를 근거로 사후에 그 효력을 부정하는 것은 불가능하다. 이는 소송절차의 안정과 확정된 권리관계의 존중이라는 민사소송법의 대원칙에 따른 결과이다.

<제5편 병합소송.제11장 병합청구소송.제02절 청구의 후발적 병합>

[예상][11.02-1]청구의 변경의 의의 및 허용 필요성, 적법요건, 소송절차 및 관할, 위반 시 조치

《【문제11.2-1】 청구의 변경에 대해 설명하시오. (25점)》

<문제11.2의 물음1> 청구의 변경의 의의 및 허용 필요성, 적법요건, 소송절차 및 관할, 위반 시 조치

I. 청구변경의 의의 및 허용 필요성

1. 청구변경의 의의

- 청구의 변경이란 소송의 계속 중에 원고가 소송물인 청구의 취지 또는 청구원인을 변경하여 새로운 청구에 대하여 판결을 구하는 소송행위를 말한다. 이는 구소의 취하와 신소의 제기가 결합된 성격을 지닌다.

2. 청구변경의 허용 필요성

- 단일한 소송절차 내에서 관련된 분쟁을 일거에 해결함으로써 소송경제를 도모하고 판결의 모순·저축을 방지하기 위하여 인정된다. 다만 피고의 방어권 침해와 소송 지연을 예방하기 위하여 일정한 한계 규정이 수반된다.

II. 청구변경의 적법 요건

1. 소송 절차상의 요건 및 시기적 한계

(1) 동종의 소송절차와 관할의 공통

- 변경된 청구가 원래의 청구와 동종의 소송절차에 따라 심리될 수 있어야 하며, 변경 후의 청구에 대해서도 수소법원에 관할권이 인정되어야 한다.

(2) 사실심 변론종결 전의 신청

- 원고는 사실심 변론종결 전까지만 청구를 변경할 수 있다. 상고심은 법률심이므로 상고심 단계에서의 청구변경은 원칙적으로 허용되지 않는다.

2. 실질적 제한 요건

(1) 청구기초의 동일성 유지

- 청구변경이 허용되려면 원래 청구와 변경 청구 간에 청구기초의 동일성이 있어야 한다. 이는 양 청구의 사실관계나 경제적 이익이 법적으로 밀접한 유기적 관련성을 가질 것을 요하며, 기존의 소송자료를 그대로 활용할 수 있는 수준이어야 한다.

(2) 소송절차의 현저한 지연 예방

- 청구의 변경으로 인해 새로운 증거조사 등이 불가피하게 요구되어 소송절차가 현저히 지연되어서는 안 된다. 지연 여부는 소송의 진행 정도와 변경 내용 등을 종합하여 법원이 결정한다.

III. 청구변경의 절차 및 위반 시의 조치

1. 청구변경의 소송 절차

(1) 서면에 의한 신청 원칙

- 청구의 변경은 소의 제기와 유사하므로 서면으로 신청하여야 하며, 법원은 그 서면을 피고에게 송달하여 방어의 기회를 부여해야 한다.(민사소송법 제262조 제2항)

(2) 변경의 형태적 분류

① 교환적 변경

- 구청구를 취하하고 완전히 새로운 신청구로 교체하는 형태로, 구소의 취하와 신소의 제기가 결합된 형태이다.

② 추가적 변경

- 구청구를 유지하면서 새로운 청구를 병합하여 함께 심판을 구하는 형태로, 소의 단순 추가 또는 객관적 병합에 해당한다.

2. 요건 위반 시의 소송법상 조치

(1) 법원의 기각 결정

- 청구변경의 요건이 결여된 경우 법원은 직권 또는 피고의 이의에 의하여 결정으로 청구변경을 허용하지 아니한다.(동법 제263조 제1항) 이 불허결정에 대해서는 독립하여 즉시항고로 불복할 수 없다.

(2) 상대방의 응소와 하자의 치유

- 청구변경에 하자가 있더라도 피고가 이에 대하여 이의를 제기하지 않고 본안 변론을 진행한 경우, 피고의 이익권 상실 또는 묵시적 동의에 의하여 청구변경의 하자는 치유된다.

IV. 결론

- 청구의 변경은 원고에게 소송제도의 유연성을 부여하고 사법 자원의 효율적 배분을 유도하는 소송법상 제도이다. 다만 법원은 청구기초의 동일성과 소송 지연 방지라는 한계를 엄격하게 심사하여, 소송경제와 상대방의 방어권 보장이라는 소송법상의 핵심적 가치들이 유기적인 균형을 이루도록 정교하게 운영해야 할 것이다.

<제5편 병합소송.제12장 다수당사자소송.제01절 공동소송>

[예상][12.01-1]민법상 조합의 당사자능력 및 선정당사자 제도의 요건과 효과

《【문제12.1】

<사례>

A, B, C 세 사람은 공동으로 식당을 운영하기 위하여 동업계약을 체결하고 행복식당이라는 명칭을 정하였다. 이들은 식당 운영에 필요한 자재를 공급받았으나 그 대금을 지급하지 못하고 있다. 자재 공급업자인 丁은 행복식당 또는 동업자들을 상대로 소를 제기하여 대금을 회수하고자 한다.

또한, 위 동업자들은 식당 인근의 공사 현장에서 발생하는 소음으로 인해 영업에 큰 차질을 빚게 되자, 공사 업체인 戊를 상대로 손해배상청구의 소를 제기하기로 하였다. 이들은 소송의 효율성을 위해 동업자 중 1인인 A를 소송수행자로 정하여 소를 제기하고자 한다.

丁이 행복식당 자체를 피고로 하여 소를 제기할 수 있는지 여부를 민법상 조합의 당사자능력 관점에서 판단하고, A가 동업자들을 대표하여 戊를 상대로 소를 제기하기 위해 필요한 민사소송법상 요건 및 그 효과에 대하여 설명하시오.》

<문제12.1> 민법상 조합의 당사자능력 및 선정당사자 제도의 요건과 효과

I. 문제의 제기

- 사안에서 A, B, C가 공동으로 식당을 운영하는 동업관계에 있고, 자재대금채권자인 丁이 행복식당 또는 동업자들을 상대로 소를 제기하려 하며, 동업자들이 A를 소송수행자로 정하여 손해배상청구소송을 제기하려는 상황이다. 쟁점으로 <민법상 조합의 당사자능력 인정 여부와 선정당사자 제도에 따른 소송수행의 요건 및 그 효과>를 검토할 필요가 있다. 이하에서는 조합의 당사자능력과 선정당사자에 의한 소송수행의 허용 요건 및 법적 효과를 설명한다.

II. 민법상 조합의 당사자능력

1. 원칙 : 당사자능력의 부정

(1) 조합의 실체

- 민법상 조합은 2인 이상이 상호 출자하여 공동사업을 경영할 것을 약정함으로써 성립하는 계약 관계에 불과하다. 따라서 조합은 법인격이 없으며, 원칙적으로 민사소송법 제51조 및 제52조에 따른 당사자능력이 인정되지 않는다.

(2) 소송 수행 방식

- 조합의 채권자나 채무자는 조합원 전원을 공동원고 또는 공동피고로 하여 소를 제기하여야 한다. 이는 조합 재산이 조합원의 합유에 속하기 때문에 발생하는 소송법적 결과다.

2. 판례의 태도

(1) 비법인사단과의 구별

- 판례는 단체의 실체가 사단적 형태를 갖추고 대표자가 정해져 있는 등 비법인사단(민사소송법 제52조)으로 볼 수 있는 경우에는 당사자능력을 인정한다. 그러나 단순한 동업 계약에 기초한 민법상 조합에 대해서는 일관되게 당사자능력을 부정하고 있다.

(2) 행복식당의 경우

- 사안의 행복식당은 A, B, C의 동업 계약에 의해 운영되는 단체이므로, 특별한 사단적 실체가 증명되지 않는 한 민법상 조합에 해당한다. 따라서 丁은 행복식당 자체를 피고로 할 수 없고, 동업자 A, B, C 전원을 공동피고로 하여 소를 제기하여야 한다.

III. 선정당사자 제도

1. 의의 및 취지

- 선정당사자란 공동의 이해관계를 가진 다수의 사람 중에서 그들을 대표하여 소송을 수행하기 위해 선정된 자를 말한다. 이는 다수당사자 소송의 복잡함을 피하고 소송 경제를 도모하기 위한 제도다.

2. 요건

(1) 공동의 이해관계

- 선정자와 피선정자 사이에 소송물이 공통되거나 소송의 목적이 되는 권리·의무가 같은 법률상 또는 사실상의 원인에 바탕을 두고 있어야 한다. 사안의 동업자들은 공사 소음으로 인한 영업권 침해라는 동일한 사실관계에 기초한 손해배상청구권을 가지므로 공동의 이해관계가 인정된다.

(2) 다수자의 존재

- 선정자는 여러 명이어야 하며, 이들이 피선정자(선정당사자)를 선임해야 한다.

(3) 피선정자의 자격

- 선정당사자는 공동의 이해관계를 가진 당사자 중에서 선정되어야 한다. 동업자 중 1인인 A는 당사자 중 한 명이므로 피선정자 자격이 있다.

3. 선정의 방법과 시기

- 선정은 서면으로 증명해야 하며, 소송 계속 전후를 불문하고 가능하다. 또한 심급마다 선정할 수도 있고 전 소송을 통틀어 선정할 수도 있다.

IV. 선정의 효과 및 소송수행

1. 선정자의 지위

- 선정이 완료되면 선정자들은 소송에서 탈퇴하게 되며, 소송의 당사자 지위를 상실한다. 따라서 이들은 별도로 소를 제기하거나 소송에 직접 참여할 수 없다.

2. 선정당사자의 권한

(1) 소송수행권의 독점

- 선정당사자는 선정자들을 위하여 일체의 소송행위를 할 권한을 갖는다. 여기에는 소의 취하, 화해, 포기, 인낙 등 처분권 행사가 포함되나, 선정자들이 권한을 제한한 경우에는 그에 따라야 한다.

(2) 판결의 효력(기판력)

- 선정당사자가 받은 판결의 효력은 민사소송법 제218조 제3항에 따라 선정자 전원에게 미친다. 따라서 판결 확정 후 선정자들은 동일한 사안으로 다시 소를 제기할 수 없다.

V. 사안의 적용

1. 丁의 소 제기

- 丁은 민법상 조합인 행복식당을 피고로 삼을 수 없다. 판례에 따라 당사자능력이 없는 조합을 상대로 한 소는 부적법각하 대상이 되므로, 丁은 동업자 A, B, C를 공동피고로 하여 소를 제기하여야 한다.

2. A의 선정당사자 소송

- 동업자 B와 C가 A를 선정당사자로 선정하는 서면을 제출한다면, A는 동업자 전체를 대표하여 戊를 상대로 소를 제기할 수 있다. 이 경우 B와 C는 소송에서 탈퇴하며, A가 얻은 판결의 결과는 B와 C에게도 귀속된다. 이는 변호사 대리의 원칙을 잠탈하지 않으면서도 다수자의 소송 편의를 도모하는 적법한 방식이다.

VI. 결론

- 민법상 조합은 당사자능력이 없으므로 조합 자체를 피고로 할 수 없으나, 조합원들이 선정당사자 제도를 이용하는 것은 가능하다. A가 적법하게 선정당사자로 선임된다면 동업자들의 공동 이해관계를 효율적으로 실현할 수 있으며, 그 판결의 효력은 동업자 전원에게 미치게 된다.

《【문제12.1-2】 필수적 공동소송에 대해 설명하시오. (25점)》

<문제12.1의 물음2> 필수적 공동소송의 의의 및 통상공동소송과의 구별, 분류 및 발생원인, 심리상 특징

I. 필수적 공동소송의 의의 및 통상공동소송과의 구별

1. 필수적 공동소송의 의의

- 필수적 공동소송이란 소송물이 공동소송인 전체에 대하여 합일적으로 확정되어야 하는 공동소송을 말한다.(민사소송법 제67조) 이는 공동소송인 간에 서로 모순·저촉되는 판결이 선고되는 것을 방지함으로써 법적 안정성을 도모하고 분쟁을 유기적으로 해결하기 위해 인정되는 제도이다.

2. 통상공동소송과의 구별

- 통상공동소송은 각 공동소송인이 독립하여 소송을 수행하는 공동소송인 독립의 원칙(동법 제66조)이 적용된다. 따라서 공동소송인 중 1인의 소송행위가 다른 공동소송인에게 영향을 미치지 않는다. 반면 필수적 공동소송은 판결의 합일확정 필요성으로 인하여 이러한 독립의 원칙이 배제되고 심리상의 강력한 제약과 특칙이 적용된다는 점에서 구별된다.

II. 필수적 공동소송의 분류 및 발생 원인

1. 고유필수적 공동소송

- 고유필수적 공동소송은 공동소송인 전원이 함께 소를 제기하거나 제기하여야만 소송당사자적격(소송수행권)이 인정되는 형태이다. 만약 일부가 누락된 채 소가 제기되면 당사자적격 흠결로 소 전체가 부적법 각하된다. 대표적인 발생 원인으로는 공유물분할청구의 소, 합유물에 관한 소송 등이 있다.

2. 유사필수적 공동소송

- 유사필수적 공동소송은 당사자들이 처음부터 반드시 공동으로 소를 제기할 필요는 없지만, 일단 공동소송이 된 이상 판결이 합일적으로 확정되어야 하는 형태이다. 일부가 누락되더라도 소 제기 자체는 적법하지만, 공동소송이 개시된 후에는 합일확정을 위한 심리 특칙이 적용된다. 주주총회결의취소의 소 등이 이에 해당한다.

III. 심리상의 특칙 (민소법 제67조의 소송행위의 공동 원칙)

1. 소송자료의 제출과 소송행위의 공동 원칙

(1) 유리한 소송행위의 효력

- 공동소송인 중 1인의 소송행위는 전원의 이익을 위해서만 효력을 가진다.(동법 제67조 제1항) 따라서 공동소송인 중 1인이 제출한 유리한 소송자료(증거의 제출, 항변 등)는 다른 공동소송인에게도 유효하게 효력을 미친다.

(2) 불리한 소송행위의 제한

- 공동소송인 중 1인의 소송행위가 다른 공동소송인에게 불리한 경우(소의 취하, 청구의 포기·인낙, 재판상 자백 등)에는 공동소송인 전원이 공동으로 하지 아니하면 그 효력이 발생하지 않는다.(동법 제67조 제2항)

2. 상대방의 소송행위와 소송절차의 중단

(1) 상대방의 소송행위의 효력

- 상대방이 공동소송인 중 1인에 대하여 한 소송행위(예: 소송고지, 상소 제기 등)는 공동소송인 전원에 대하여 그 효력이 발생한다.(동법 제67조 제3항)

(2) 소송절차의 중단 및 수계

- 공동소송인 중 1인에게 소송절차의 중단 사유(예: 사망)가 발생한 경우, 소송절차는 전원에 대하여 중단된다. 이에 따른 소송 수계 신청 역시 전원에 대하여 행해져야만 중단 상태가 해소된다.

IV. 공동소송인의 추가 제도 (민소법 제68조)

1. 공동소송인 추가의 의의와 요건

- 고유필수적 공동소송에서 공동소송인의 일부가 누락된 경우 소각하 판결을 피하기 위하여 법원의 허가를 얻어 누락된 자를 소송에 추가하는 제도이다. 이는 제1심의 변론종결 전까지 원고의 신청에 의하여만 가능하며, 서면으로 신청하여야 한다.

2. 추가 결정의 법적 효과

- 법원의 허가 결정이 있으면 추가된 자는 최초로 소가 제기된 때에 공동소송인으로 소를 제기하거나 제기당한 것으로 본다.(소급효) 이로 인해 제척기간의 준수나 소멸시효 중단의 효력이 소급하여 발생한다.

V. 결론

- 필수적 공동소송은 재판의 합일확정이라는 공익적 요청을 달성하기 위한 제도로서, 통상공동소송과 달리 심리상의 엄격한 통일성을 요한다. 민사소송법 제67조는 공동소송인 간의 이해관계를 조절하기 위해 유리한 소송행위와 불리한 소송행위의 효력을 다르게 규정하고 있으며, 제68조의 추가 제도를 두어 당사자적격의 흠결로 소가 무자비하게 각하되는 것을 예방하고 있다. 법원은 이러한 제도들을 유기적으로 결합하여 소송경제와 실체적 정의를 함께 달성해야 할 것이다.

<제6편 상소심절차.제13장 총설.제02절 상소의 적법요건>
[예상][13.02-1]항소기간 도과와 소송행위의 추후보완 요건 및 절차

《【문제13.2】

<사례>

甲은 乙을 상대로 2억 원의 손해배상청구소송을 제기하였다. 제1심 법원은 심리 결과 乙의 과실을 60%로 인정하여 乙은 甲에게 1억 2,000만 원을 지급 하라는 원고 일부승소 판결을 선고하였다. 판결서 정본은 2024. 2. 1. 甲과 乙에게 각각 적법하게 송달되었다.

乙은 위 판결에 불복하고자 하였으나, 항소장 제출 기한인 2024. 2. 15.에 갑작스러운 폭설로 인해 교통이 마비되어 법원에 출석하지 못하였고 전자소송 시스템에도 접속하지 못하여 결국 2024. 2. 16.에야 항소장을 제출하였다. 한편, 甲은 제1심 판결 선고 직후 乙과 만나 더 이상 이 사건으로 다투지 않겠 다며 상소권을 포기하기로 합의하였으나, 마음을 바꿔 2024. 2. 10. 항소를 제기하였다.

또한, 별개의 사건에서 丙은 丁을 상대로 소유권이전등기청구소송을 제기하여 전부 승소 판결을 받았다. 그런데 판결 이유 중에서 법원은 丙이 주장한 매매계약의 성립 시점을 丙의 주장과 다르게 판단하였다. 丙은 판결 결과(주문)에는 만족하지만, 판결 이유 중의 사실인정이 향후 다른 분쟁에 영향을 미 칠 것을 우려하여 항소를 제기하고자 한다.

(물음1) 乙이 항소기간을 도과하여 제출한 항소가 책임질 수 없는 사유로 인한 것인지 여부를 검토하고, 민사소송법 제173조에 따른 소송행위의 추후보 완(추완)이 인정되기 위한 요건과 그 절차에 대하여 설명하시오.》

<문제13.2의 물음1> 항소기간 도과와 소송행위의 추후보완 요건 및 절차

I. 문제의 제기

- 사안에서 乙은 제1심 판결에 대한 항소기간 내 항소장을 제출하지 못하였고, 폭설로 인한 교통 마비 및 전자소송 장애를 이유로 기간 도과 후 항소를 제기하려는 상황이다. 쟁점으로 <항소기간 도과가 당사자가 책임질 수 없는 사유에 의한 것인지 여부와 추후보완의 요건 및 절차>를 검토할 필요가 있 다. 이하에서는 소송행위의 추후보완 제도의 의의와 책임질 수 없는 사유의 판단 기준 및 추완절차를 설명한다.

II. 소송행위의 추후보완(추완) 일반론

1. 의의 및 취지

- 당사자가 그 책임을 질 수 없는 사유로 말미암아 불변기간을 지킬 수 없었던 경우에는 그 사유가 없어진 날부터 2주 이내에 게을리한 소송행위를 보 완할 수 있다.(민사소송법 제173조 제1항) 이는 절차의 안정을 위한 불변기간의 엄격성과 당사자의 권리 구제라는 실질적 형평을 조화시키기 위한 제도 이다.

2. 추완의 대상

- 항소기간, 상고기간, 재심제기기간 등 법률이 불변기간으로 정한 것에 한정된다. 사안의 항소기간(2주)은 대표적인 불변기간에 해당한다.

III. 책임질 수 없는 사유의 판단 기준

1. 학설 및 판례의 태도

(1) 개념 정의

- 책임질 수 없는 사유란 당사자가 소송행위를 하기 위하여 일반적으로 하여야 할 주의를 다하였음에도 불구하고 피할 수 없었던 사정을 의미한다.

(2) 구체적 사례

- 천재지변, 갑작스러운 중병, 법원의 잘못된 교시 등이 이에 해당한다. 단순히 당사자의 과실이나 소송대리인의 부주의, 주소지 부재 등은 원칙적으 로 포함되지 않는다.

2. 사안의 검토 (폭설 및 전산 장애)

- 폭설로 인해 교통이 완전히 마비되어 물리적으로 법원에 출석할 수 없었고, 동시에 전자소송 시스템까지 접속이 불가능하여 전자적 제출도 할 수 없 었던 상황이라면, 이는 당사자가 통상적인 주의력을 행사하더라도 피할 수 없는 객관적 장애에 해당한다. 따라서 乙에게 책임을 묻기 어려운 사유로 볼 수 있다.

IV. 추완의 요건 및 절차

1. 요건

(1) 불변기간의 도과

- 적법한 불변기간(항소기간 등)이 경과하여야 한다.

(2) 당사자의 무과실

- 당사자나 그 대리인이 기간을 지키지 못한 데에 과실이 없어야 한다.

(3) 기간의 준수

- 사유가 없어진 날부터 2주(외국에 있는 경우 30일) 이내에 추완신청을 하여야 한다.

2. 절차 및 방법

(1) 신청 방식

- 게을리한 소송행위(항소장 제출 등)를 함과 동시에 추완신청서를 제출하는 것이 일반적이다. 별도의 신청서 없이 항소장을 제출하면서 그 사유를 기재하는 방식도 허용된다.

(2) 심리 및 재판

- 추완 사유의 존부는 수소법원이 심리한다. 사유가 인정되면 본안 심리에 들어가고, 인정되지 않으면 소각하 판결(또는 항소각하)을 한다.

V. 사안의 적용

1. 乙의 과실 유무

- 乙은 항소기간 마지막 날에 예상치 못한 폭설과 시스템 장애라는 이중의 장애에 직면하였다. 판례의 경향에 비추어 볼 때, 천재지변에 준하는 교통 마비와 전산 마비는 당사자의 책임 범위를 벗어난 것으로 판단될 가능성이 높다.

2. 추완의 적법성

- 乙은 장애 사유가 해소된 직후인 2024. 2. 16.에 바로 항소장을 제출하였다. 이는 사유가 없어진 날부터 2주 이내라는 기간 요건을 충족한 것이며, 게을리한 소송행위인 항소장 제출을 완료하였으므로 추완의 절차적 요건을 모두 갖추었다고 볼 수 있다.

Ⅵ. 결론

- 乙이 제출한 항소는 민사소송법 제173조에 따른 소송행위의 추후보완 요건을 갖춘 것으로 판단된다. 갑작스러운 폭설과 전산망 장애는 당사자가 책임질 수 없는 사유에 해당하며, 乙은 사유 종료 후 즉시 항소장을 제출함으로써 절차를 이행하였다. 따라서 법원은 乙의 항소를 적법한 것으로 받아들여 제1심 판결에 대한 본안 심리를 진행하여야 한다.

<제6편 상소심절차.제13장 총설.제02절 상소의 적법요건>
[예상][13.02-2]상소권 포기의 효력 및 형식적 불복설에 따른 상소의 이익 인정 여부

《【문제13.2】

<사례>

甲은 乙을 상대로 2억 원의 손해배상청구소송을 제기하였다. 제1심 법원은 심리 결과 乙의 과실을 60%로 인정하여 乙은 甲에게 1억 2,000만 원을 지급 하라는 원고 일부승소 판결을 선고하였다. 판결서 정본은 2024. 2. 1. 甲과 乙에게 각각 적법하게 송달되었다.

乙은 위 판결에 불복하고자 하였으나, 항소장 제출 기한인 2024. 2. 15.에 갑작스러운 폭설로 인해 교통이 마비되어 법원에 출석하지 못하였고 전자소송 시스템에도 접속하지 못하여 결국 2024. 2. 16.에야 항소장을 제출하였다. 한편, 甲은 제1심 판결 선고 직후 乙과 만나 더 이상 이 사건으로 다투지 않겠 다며 상소권을 포기하기로 합의하였으나, 마음을 바꿔 2024. 2. 10. 항소를 제기하였다.

또한, 별개의 사건에서 丙은 丁을 상대로 소유권이전등기청구소송을 제기하여 전부 승소 판결을 받았다. 그런데 판결 이유 중에서 법원은 丙이 주장한 매매계약의 성립 시점을 丙의 주장과 다르게 판단하였다. 丙은 판결 결과(주문)에는 만족하지만, 판결 이유 중의 사실인정이 향후 다른 분쟁에 영향을 미 칠 것을 우려하여 항소를 제기하고자 한다.

(물음2) 甲이 상소권 포기 합의 후 제기한 항소가 적법한지 여부를 상소권 포기의 방식 및 효력과 관련하여 논하고, 전부 승소한 丙이 판결 이유만을 다 투기 위해 제기한 항소에 상소의 이익이 인정되는지 판례의 태도인 형식적 불복설에 근거하여 기술하시오.》

<문제13.2의 물음2> 상소권 포기의 효력 및 형식적 불복설에 따른 상소의 이익 인정 여부

I. 문제의 제기

- 사안에서 甲은 乙과 상소권 포기에 관한 합의를 한 후 항소를 제기하였고, 丙은 전부 승소판결을 받은 뒤 판결 이유의 사실인정만을 다투기 위해 항소 하려는 상황이다. 쟁점으로 <상소권 포기의 방식과 효력에 따른 항소의 적법 여부> 및 <전부 승소한 당사자에게 판결 이유에 대한 상소의 이익이 인정되 는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 상소권 포기의 요건과 효력 및 형식적 불복설에 따른 상소의 이익 인정 여부를 기술한다.

- 상소는 당사자의 자유로운 의사에 따라 포기할 수 있으나, 그 방식과 시기에 일정한 제한이 있다. 사안에서는 甲이 乙과 상소권 포기 합의를 한 후 항 소를 제기한 경우 그 항소의 적법성 여부가 문제된다. 또한, 전부 승소한 丙이 판결 주문이 아닌 이유 중의 사실인정을 다투기 위해 항소할 수 있는지와 관련하여 상소의 이익에 관한 판례의 태도인 형식적 불복설을 검토할 필요가 있다. 이하에서는 이에 대하여 살펴본다.

II. 상소권의 포기

1. 의의 및 방식

(1) 의의

- 상소권의 포기란 상소권을 행사하지 않겠다는 당사자의 의사표시이다. 이는 소송계속 중 또는 판결 선고 후에 이루어질 수 있으며, 상소권을 소멸 시키는 효과를 가진다.

(2) 방식 (민사소송법 제394조)

- 상소권의 포기는 상소를 제기하기 전에는 제1심 법원에, 상소를 제기한 후에는 기록이 있는 법원에 서면으로 신청하여야 한다. 다만, 변론기일 등 에서는 말로 할 수 있으며 이를 조서에 기재하여야 한다.

2. 상소권 포기 합의의 효력

(1) 소송외 합의의 성질

- 사안과 같이 당사자 쌍방이 법정 밖에서 만나 `더 이상 다투지 않겠다`고 약정하는 것은 이른바 부상소의 합의(소송협약)에 해당한다. 판례는 이러 한 소송외 합의가 유효하기 위해서는 처분할 수 있는 권리에 관한 것이어야 하고, 특정된 법률관계에 기반하며, 합의 시 당사자가 예상할 수 있는 범위 내여야 한다고 본다.

(2) 위반 시의 효과

- 적법한 부상소 합의가 있음에도 불구하고 상소를 제기한 경우, 판례는 이를 권리보호의 이익이 없는 부적법한 상소로 보아 각하 판결을 내린다.

III. 상소의 이익과 형식적 불복설

1. 상소의 이익의 의의

- 상소의 이익이란 상소를 통해 제1심 판결보다 유리한 판결을 얻을 수 있는 가능성을 의미한다. 상소의 이익이 없는 상소는 부적법하여 각하된다.

2. 판단 기준에 관한 판례의 태도 (형식적 불복설)

(1) 개념

- 판례는 상소의 이익 유무를 판단함에 있어 원칙적으로 형식적 불복설을 취하고 있다. 이는 당사자가 제1심에서 신청한 청구취지와 비교하여 판결 주문상 그보다 적은 결과를 얻었을 때(일부 패소)에만 상소의 이익을 인정하는 견해이다.

(2) 구체적 적용

- 승소 판결의 이유에 불만이 있다 하더라도 주문에서 청구한 바를 전부 얻어냈다면 원칙적으로 상소의 이익이 없다. 즉, 사실인정의 오류나 법리 판 단의 불만은 상소 사유가 되지 않는다.

IV. 사안의 적용

1. 甲의 항소 제기 건

(1) 합의의 효력

- 甲은 판결 선고 후 乙과 상소권을 포기하기로 합의하였다. 이는 특정된 손해배상청구 사건에 관한 것으로서 유효한 부상소의 합의이다.

(2) 항소의 적법성

- 甲이 합의를 어기고 항소를 제기한 것은 소송법상 신의칙 또는 부상소 합의의 효력에 반하는 것으로서 권리보호의 이익이 없다. 따라서 甲의 항소 는 부적법하여 각하되어야 한다.

2. 丙의 항소 제기 건

(1) 사실관계의 확인

- 丙은 제1심에서 전부 승소 판결을 받았다. 판결 주문은 丙이 원하는 대로 소유권이전등기를 명하고 있다.

(2) 상소의 이익 판단

- 형식적 불복설에 의하면 전부 승소한 丙은 판결 주문에서 불이익을 입은 바가 없다. 비록 판결 이유 중 매매계약 성립 시점에 대한 판단이 자신의 주장과 다르다 하더라도, 이는 기판력이 발생하는 주문의 결론이 아니므로 상소로써 다툴 이익이 없다. 따라서 丙의 항소 역시 부적법하여 각하 대상이다.

V. 결론

- 甲의 항소는 유효한 상소권 포기 합의에 위반하여 제기된 것이므로 소송법상 권리보호이익이 없어 부적법하다. 또한 丙의 항소는 판결 이유만을 다투기 위한 것으로서, 형식적 불복설을 취하는 판례의 태도에 비추어 볼 때 전부 승소한 자에게는 상소의 이익이 인정되지 않으므로 이 또한 부적법하다. 민사소송 절차는 판결 주문상의 불이익을 구제하는 것을 목적으로 하므로, 당사자 간의 합의나 객관적인 승소 결과는 절차의 종료를 정당화하는 강력한 근거가 된다.

《[문제14.3]

<사례>

甲은 乙을 상대로 1억 원의 대여금 청구소송을 제기하였다. 제1심 소송에서 乙은 대여사실 자체를 부인하였으나, 법원은 증거조사를 거쳐 甲의 주장을 인정하고 원고 전부승소 판결을 선고하였다. 乙은 이에 불복하여 항소를 제기하였다.

항소심 변론기일에서 乙은 제1심에서 주장하지 않았던 새로운 방어방법으로, 설령 대여사실이 인정된다 하더라도 이미 시효가 완성되어 채무가 소멸하였다는 소멸시효 항변을 제출하였다. 이에 대해 甲은 乙이 제1심에서 충분히 주장할 수 있었음에도 불구하고 소송을 지연시키기 위해 뒤늦게 항변을 제출하는 것이라며 이를 각하해 달라고 요청하였다.

한편, 항소심 재판부는 심리 중 제1심에서 제출되지 않았던 새로운 증인 丙의 진술이 사건의 핵심 열쇠라고 판단하였다. 하지만 丙은 甲의 친인척으로서 제1심 당시에도 충분히 증인으로 신청할 수 있었던 인물이었다. 또한 乙은 항소심 진행 중에 甲에 대하여 별도로 가지고 있던 5,000만 원의 채권을 가지고 상계항변을 추가로 제출하고자 한다.

(물음1) 민사소송법상 항소심의 구조인 속심제의 의의와 관련하여, 乙이 항소심에서 처음으로 제출한 소멸시효 항변이 적법한 공격방어방법으로서 수용될 수 있는지 여부와 민사소송법 제285조 및 제412조에 따른 제출 제한 사유(실기한 공격방어방법 등)를 근거로 논하시오.》

<문제14.3의 물음1> 항소심의 속심제 구조와 소멸시효 항변의 적시제출의무 위반 여부

I. 문제의 제기

- 사안에서 乙은 제1심에서 대여사실을 부인하여 패소한 후 항소심에서 소멸시효 항변 등 새로운 공격방어방법을 제출하는 상황이다. 쟁점으로 <항소심의 속심적 구조에 따라 새로운 공격방어방법의 제출이 허용되는지>와 <실기한 공격방어방법 등에 의한 제출 제한 여부를 검토>할 필요가 있다. 이하에서는 乙이 항소심에서 제출한 소멸시효 항변의 적법성과 그 제한 사유를 논한다.

II. 항소심의 구조와 속심제

1. 속심제의 의의

- 속심제란 항소심이 제1심의 판결이 사후적으로 옳은가를 심판하는 것이 아니라, 제1심의 심리상태를 인계받아 변론종결 시까지 제출된 모든 자료를 기초로 사건의 본안을 다시 심리하는 구조를 말한다.

2. 속심제의 효과

(1) 새로운 자료의 제출

- 당사자는 항소심 변론종결 전까지 새로운 공격방어방법을 제출할 수 있는 것이 원칙이다. 이는 제1심에서 제출하지 못했던 증거나 항변을 보완할 기회를 부여한다.

(2) 제1심과의 연속성

- 제1심에서 행한 소송행위와 증거조사 결과는 항소심에서도 그대로 효력을 유지하며, 항소심은 이를 기초로 추가적인 심리를 진행한다.

III. 공격방어방법의 제출 제한 (적시제출주의)

1. 적시제출주의의 원칙 [민사소송법 제146조]

- 공격 또는 방어의 방법은 소송의 정도에 따라 적절한 시기에 제출하여야 한다. 이는 소송의 지연을 방지하고 집중심리를 구현하기 위함이다.

2. 실기한 공격방어방법의 각하 [민사소송법 제285조]

(1) 요건

- ① 당사자가 고의 또는 중대한 과실로 적절한 시기를 놓쳐 뒤늦게 제출하였어야 한다. ② 그 결과 소송의 완결을 지연시키게 되어야 한다.

(2) 항소심에서의 적용 [민사소송법 제412조]

- 항소심에서도 적시제출주의는 적용된다. 특히 제1심에서 충분히 제출할 수 있었음에도 불구하고 항소심에 이르러서야 새로운 항변을 제출하는 것은 실기한 공격방어방법으로 취급될 가능성이 높다.

IV. 사안의 적용

1. 乙의 소멸시효 항변과 속심제

- 속심제의 원칙에 따르면 乙이 항소심에서 새로운 방어방법인 소멸시효 항변을 제출하는 것 자체는 일단 허용된다. 항소심은 제1심의 속행으로서 새로운 사실관계와 법률적 주장을 수용할 수 있는 구조적 유연성을 갖기 때문이다.

2. 실기한 공격방어방법 해당 여부

(1) 고의·중과실 여부

- 乙은 제1심에서 대여사실 자체만을 다투었으나, 소멸시효는 채무자로서 통상적으로 쉽게 인지할 수 있는 사항이다. 특별한 사정이 없는 한 제1심에서 충분히 주장 가능했음에도 항소심에 이르러 제출한 것은 乙의 과실이 인정될 소지가 크다.

(2) 소송 지연 여부

- 만약 乙의 항변을 심리하기 위해 새로운 증거조사나 추가 기일이 필요하게 된다면, 이는 제1심에서 종결될 수 있었던 사건을 불필요하게 연장하는 결과가 되어 소송의 완결을 지연시키는 것으로 볼 수 있다.

(3) 소결

- 甲의 주장처럼 乙의 항변이 오로지 소송 지연을 목적으로 하거나, 乙의 중과실로 뒤늦게 제출되어 새로운 심리가 불가피하다면 법원은 민사소송법 제285조 및 제412조에 의거하여 해당 항변을 각하할 수 있다.

V. 결론

- 항소심은 속심제를 취하므로 乙이 소멸시효 항변을 제출하는 것은 원칙적으로 가능하나, 이는 적시제출주의의 제한을 받는다. 乙이 제1심에서 충분히 제출할 수 있었음에도 불구하고 만연히 항소심에서 이를 주장한 것이 소송의 완결을 지연시킨다고 판단될 경우, 재판부는 이를 실기한 공격방어방법

으로 보아 각하할 수 있다. 다만 실무적으로 소멸시효와 같은 강력한 법률적 방어수단은 실체적 진실 발견을 위해 각하에 신중을 기하는 경향이 있으나, 요건을 충족한다면 절차적 정의를 위해 각하될 수 있음이 타당하다.

《【문제14.3】

<사례>

甲은 乙을 상대로 1억 원의 대여금 청구소송을 제기하였다. 제1심 소송에서 乙은 대여사실 자체를 부인하였으나, 법원은 증거조사를 거쳐 甲의 주장을 인정하고 원고 전부승소 판결을 선고하였다. 乙은 이에 불복하여 항소를 제기하였다.

항소심 변론기일에서 乙은 제1심에서 주장하지 않았던 새로운 방어방법으로, 설령 대여사실이 인정된다 하더라도 이미 시효가 완성되어 채무가 소멸하였다는 소멸시효 항변을 제출하였다. 이에 대해 甲은 乙이 제1심에서 충분히 주장할 수 있었음에도 불구하고 소송을 지연시키기 위해 뒤늦게 항변을 제출하는 것이라며 이를 각하해 달라고 요청하였다.

한편, 항소심 재판부는 심리 중 제1심에서 제출되지 않았던 새로운 증인 丙의 진술이 사건의 핵심 열쇠라고 판단하였다. 하지만 丙은 甲의 친인척으로서 제1심 당시에도 충분히 증인으로 신청할 수 있었던 인물이었다. 또한 乙은 항소심 진행 중에 甲에 대하여 별도로 가지고 있던 5,000만 원의 채권을 가지고 상계항변을 추가로 제출하고자 한다.

(물음2) 항소심에서 변론의 범위는 제1심 변론과 어떻게 연결되는지(변론의 집중)를 설명하고, 乙이 추가로 제출하려는 상계항변이 항소심의 심리 단계에서 어느 정도까지 허용되는지 판례가 제시하는 적시제출의 원칙과 관련하여 기술하시오.》

<문제14.3의 물음2> 항소심 변론의 범위와 상계항변의 적시제출주의 위반 여부 및 판례의 태도

I. 문제의 제기

- 사안에서 乙은 항소심 계속 중 제1심에서 주장하지 않았던 상계항변을 추가로 제출하려는 상황이다. 쟁점으로 <항소심에서의 변론 범위와 변론의 집중에 따른 새로운 공격방어방법 제출의 허용 여부 및 적시제출의 원칙에 따른 제한>을 검토할 필요가 있다. 이하에서는 乙이 항소심에서 추가한 상계항변의 허용 범위와 그 제출 제한 여부를 기술한다.

II. 항소심 변론의 범위와 제1심과의 연결

1. 변론의 일체성 (단일성)

(1) 의의

- 항소심의 변론은 제1심 변론의 속행으로서, 제1심에서 행한 소송행위와 증거조사 결과는 항소심에서도 그대로 효력을 가진다. 이를 변론의 일체성 또는 단일성이라 한다.

(2) 변론의 집중과 속심제

- 항소심은 제1심의 심리를 인계받아 변론종결 시까지 제출된 모든 자료를 기초로 판결한다. 따라서 당사자는 원칙적으로 항소심 변론종결 전까지 새로운 공격방어방법을 제출할 수 있다.

2. 변론의 집중을 위한 제한

- 실질적으로 항소심이 제1심의 반복이 되는 것을 방지하고 재판의 신속을 기하기 위하여, 민사소송법은 적시제출주의(제146조)를 근거로 실기한 공격방어방법의 각하(제285조, 제412조) 규정을 두고 있다. 이는 항소심에서의 무분별한 새로운 주장 제출을 억제하는 기능을 한다.

III. 상계항변의 제출과 적시제출의 원칙

1. 상계항변의 특수성

- 상계항변은 소송 외적인 채권·채무 관계를 소송 내로 끌어들이 심리하는 것으로, 다른 방어방법에 비해 심리가 복잡해질 가능성이 크다. 따라서 이를 뒤늦게 제출하는 경우 소송 지연의 우려가 더 높게 평가될 수 있다.

2. 적시제출주의와 실기한 공격방어방법

(1) 각하 요건

- ① 당사자가 고의 또는 중대한 과실로 적기에 제출하지 않았어야 한다. ② 그 방어방법의 제출로 인하여 소송의 완결이 지연되어야 한다.

(2) 판례의 태도

- 판례는 상계항변이 제1심에서 충분히 주장할 수 있었음에도 불구하고 항소심에 이르러서야 제출된 경우, 그것이 소송의 상태에 비추어 새로운 증거조사를 필요로 하거나 심리 기일을 연장시키는 결과를 초래한다면 실기한 공격방어방법으로서 각하될 수 있다고 본다.

(3) 판단 기준

- 판례에 따르면 소송의 완결을 지연시키는지 여부는 그 방어방법을 각하했을 때 소송이 즉시 종결될 수 있는 상태인지를 기준으로 판단한다. 즉, 이미 심리가 충분히 이루어져 판결을 내릴 수 있는 단계에서 새로운 상계항변이 제출되어 추가적인 심리가 필요하다면 이는 지연으로 간주된다.

IV. 사안의 적용

1. 乙의 상계항변 제출 시기

- 乙은 제1심에서 대여사실만을 부인하다가 항소심 진행 중에 비로소 5,000만 원의 채권을 근거로 상계항변을 제출하려 한다. 상계의 기초가 되는 채권이 제1심 당시 이미 존재하고 있었고 乙이 이를 인지하고 있었다면, 이를 항소심에서야 제출하는 것은 고의 또는 중대한 과실에 의한 지연으로 평가될 가능성이 높다.

2. 소송 지연의 실질적 판단

- 사안에서 항소심 재판부가 이미 새로운 증인 丙의 진술을 핵심 열쇠로 판단하여 심리를 진행 중인 상황이라 하더라도, 乙이 제출하려는 상계항변이 별개의 채권 존재 여부를 다투어야 하는 등 추가적인 증거조사를 필요로 한다면 이는 명백히 소송의 완결을 지연시키는 사유가 된다. 특히 상계항변은 반대채권의 존부에 대한 심리가 선행되어야 하므로 소송 경제 측면에서 엄격히 제한될 수 있다.

V. 결론

- 乙의 상계항변은 항소심이 속심제라는 점에서 원칙적으로 제출 가능하나, 판례가 제시하는 적시제출의 원칙에 따라 엄격한 제한을 받는다. 乙이 제1심에서 충분히 주장할 수 있었던 사정(고의·중과실)이 인정되고, 해당 항변으로 인해 기존에 예정된 항소심 판결 시기가 늦춰진다면(소송 지연), 법원은

민사소송법 제412조 및 제285조를 적용하여 이를 각하하여야 한다. 이는 항소심을 사실상의 제2의 제1심으로 오용하는 것을 방지하고 변론의 집중을 실현하기 위한 필수적인 조치이다.

《【문제14.4】

<사례>

甲은 乙을 상대로 2억 원의 손해배상청구소송을 제기하였다. 제1심 법원은 乙의 책임을 인정하면서도 과실상계를 적용하여 乙은 甲에게 1억 원을 지급 하라는 원고 일부승소 판결을 선고하였다. 이에 대하여 피고 乙만이 항소하였고, 원고 甲은 항소하지 않았다.

항소심 심리 결과, 재판부는 乙의 과실이 제1심판결보다 더 크다고 판단하여 손해배상액이 1억 5,000만 원이 적정하다는 결론에 도달하였다. 반면, 乙은 제1심판결이 전제한 사실관계 자체가 오인되었으므로 제1심판결을 취소하고 甲의 청구를 전부 기각해야 한다고 주장하고 있다.

또 다른 사건에서, A는 B를 상대로 소를 제기하였으나 제1심 법원은 소의 제기 요건에 흠결이 있다는 이유로 소각하판결을 선고하였다. A는 이에 불복 하여 항소하였고, 항소심 법원은 심리 결과 제1심의 판단과 달리 소의 요건이 구비되어 적법하다고 판단하였다. 그러나 항소심 법원은 본안 심리를 충분히 하지 않은 상태에서 스스로 판결(자판)을 내릴지, 아니면 다시 제1심 법원으로 사건을 돌려보낼지 검토 중이다.

(물음1) 피고 乙만이 항소한 사례에서 항소심 법원이 제1심판결보다 乙에게 불리한 1억 5,000만 원의 지급을 명하는 판결을 선고할 수 있는지 여부를 불 이익변경금지의 원칙과 관련하여 논하고, 만약 항소가 이유 없다고 판단될 때 항소심 법원이 내려야 할 항소기각 재판의 형식을 기술하시오.》

<문제14.4의 물음1> 피고만이 항소한 경우 불이익변경금지의 원칙 적용 여부와 항소기각의 재판 형식

I. 문제의 제기

- 사안에서 乙만이 제1심 일부승소판결에 대하여 항소하여 항소심에서 제1심보다 증액된 손해배상액의 판단 가능성이 문제되는 상황이다. 쟁점으로 <항소심 법원이 불이익변경금지의 원칙에 따라 원심보다 불리한 판결을 할 수 있는지>와 <항소가 이유 없다고 판단될 경우의 재판 형식>을 검토할 필요가 있다. 이하에서는 항소심의 불이익변경금지 적용 여부와 항소기각 판결의 형식을 기술한다.

II. 불이익변경금지의 원칙

1. 의의 및 근거

(1) 의의

- 불이익변경금지의 원칙이란 상소심 법원은 상소인(항소인)이 신청한 불복의 한도 내에서만 제1심 판결의 당부를 조사할 수 있으며, 상소인에게 제1심 판결보다 불리한 판결을 할 수 없다는 원칙을 말한다.

(2) 근거

- 이는 처분권주의(제203조)의 상소심적 발현이다. 상소인은 자신이 불복한 범위 내에서만 심판을 구하는 것이므로, 상대방이 부대항소를 제기하는 등의 특별한 사정이 없는 한 법원이 그 범위를 넘어서는 심판을 할 수 없다.

2. 사안의 경우 적용 여부

(1) 심판의 범위

- 피고 乙만이 항소한 경우, 항소심의 심판 대상은 乙이 불복한 1억 원 지급 부분에 한정된다. 원고 甲은 항소하지 않았으므로 甲이 패소한 나머지 1억 원 부분은 항소심의 심판 대상에서 제외된다.

(2) 불이익변경의 판단

- 제1심 판결은 1억 원 지급을 명하였으나, 항소심 법원이 1억 5,000만 원 지급을 명하는 것은 항소인인 乙에게 제1심보다 더 무거운 의무를 지우는 것이다. 이는 전형적인 불이익변경에 해당하며, 원고 甲의 항소나 부대항소가 없는 이상 허용되지 않는다.

3. 예외적 허용 범위

- 상대방이 부대항소를 제기하거나, 판결의 주문이 아닌 이유 중의 판단(예 : 과실상계 비율 등)을 변경하는 과정에서 계산상의 차이가 발생하는 경우 등 극히 예외적인 상황이 아니라면 이 원칙은 엄격히 준수되어야 한다.

III. 항소기각 재판의 형식

1. 항소기각 판결의 의의

- 항소인이 제기한 항소가 절차상 적법하기는 하나, 실체적인 심리 결과 제1심 판결이 정당하다고 인정될 때 항소심 법원이 항소를 배척하는 판결을 말한다.

2. 재판의 형식 (민사소송법 제414조)

(1) 항소기각 판결의 원칙

- 항소심 법원이 제1심 판결을 검토한 결과 乙의 항소이유가 근거 없고 제1심의 결론(1억 원 지급)이 적절하다고 판단한다면, 피고의 항소를 기각한다는 판결을 선고해야 한다.

(2) 이유 교체에 의한 기각 (제414조 제2항)

- 제1심 판결의 이유(예 : 사실관계 판단이나 과실상계 비율)는 부당하더라도 다른 이유에 의하여 그 결과(1억 원 지급)가 정당하다고 인정되는 경우에도 항소심 법원은 항소를 기각하여야 한다. 사안에서 법원이 乙의 과실이 더 크다고 보아 1억 5,000만 원이 적정하다고 판단했더라도, 불이익변경금지 원칙상 1억 원을 초과하여 인용할 수 없으므로 결국 결론적으로는 제1심의 1억 원 인용이 유지되어야 하며, 이때의 형식 역시 항소기각이 된다.

IV. 사안의 적용

1. 불이익변경금지 원칙의 위반

- 피고 乙만이 항소한 본 사안에서 항소심 법원이 1억 5,000만 원을 지급하라고 판결하는 것은 乙에게 불리하게 판결을 변경하는 것이므로 불이익변경금지의 원칙에 위배되어 위법하다. 비록 객관적인 손해액이 1억 5,000만 원이라 하더라도 법원은 1억 원을 한도로 판결할 수밖에 없다.

2. 재판 형식의 결정

- 乙의 항소이유(사실오인에 따른 전부 기각 주장)가 이유 없고, 법원이 보기에 제1심 판결의 액수(1억 원)가 乙에게 최소한 억울하지 않은 금액(오히려 더 적은 금액)임이 확인되었다면, 법원은 제1심 판결의 주문을 유지하는 항소기각 판결을 내려야 한다. 이때 법원은 판결 이유 중에서 제1심의 과실상계가 잘못되었음을 지적하되, 원고의 항소가 없으므로 주문에서는 1억 원을 유지한다는 취지를 명시하게 된다.

V. 결론

- 항소심 법원은 피고 乙만이 항소한 경우 불이익변경금지의 원칙에 따라 제1심 판결인 1억 원보다 乙에게 불리한 1억 5,000만 원을 선고할 수 없다. 설령 항소심 재판부가 실체적 진실에 비추어 1억 5,000만 원이 적정하다고 판단하더라도, 처분권주의에 의한 절차적 제약으로 인해 제1심의 인용 금액을 유지해야 한다. 따라서 법원은 乙의 항소가 이유 없음을 이유로 항소기각 판결을 선고함으로써 제1심 판결의 효력을 존속시켜야 한다.

《[문제14.4]

<사례>

甲은 乙을 상대로 2억 원의 손해배상청구소송을 제기하였다. 제1심 법원은 乙의 책임을 인정하면서도 과실상계를 적용하여 乙은 甲에게 1억 원을 지급 하라는 원고 일부승소 판결을 선고하였다. 이에 대하여 피고 乙만이 항소하였고, 원고 甲은 항소하지 않았다.

항소심 심리 결과, 재판부는 乙의 과실이 제1심판결보다 더 크다고 판단하여 손해배상액이 1억 5,000만 원이 적정하다는 결론에 도달하였다. 반면, 乙은 제1심판결이 전제한 사실관계 자체가 오인되었으므로 제1심판결을 취소하고 甲의 청구를 전부 기각해야 한다고 주장하고 있다.

또 다른 사건에서, A는 B를 상대로 소를 제기하였으나 제1심 법원은 소의 제기 요건에 흠결이 있다는 이유로 소각하판결을 선고하였다. A는 이에 불복 하여 항소하였고, 항소심 법원은 심리 결과 제1심의 판단과 달리 소의 요건이 구비되어 적법하다고 판단하였다. 그러나 항소심 법원은 본안 심리를 충분히 하지 않은 상태에서 스스로 판결(자판)을 내릴지, 아니면 다시 제1심 법원으로 사건을 돌려보낼지 검토 중이다.

(물음2) A가 제기한 항소심에서 제1심의 소각하판결이 부당하다고 인정되는 경우, 항소심 법원이 사건을 반드시 제1심 법원으로 환송해야 하는지(필수 적 환송) 아니면 직접 본안판결을 할 수 있는지 여부를 민사소송법 제418조의 규정과 심급의 이익 관점에서 설명하시오.》

<문제14.4의 물음2> 제1심의 소각하판결이 부당한 경우 항소심 법원의 환송 및 재판 여부

I. 문제의 제기

- 사안에서 A가 제1심 소각하판결에 불복하여 항소하였고, 항소심에서 제1심 판단과 달리 소가 적법하다고 인정된 상황이다. 쟁점으로 <소각하판결이 취소되는 경우 항소심 법원이 심급의 이익을 고려하여 사건을 제1심 법원에 환송하여야 하는지> 또는 <직접 본안판결을 할 수 있는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 민사소송법 제418조에 따른 필수적 환송 여부와 항소심의 재판 가능성을 설명한다.

II. 필수적 환송과 재판의 범위

1. 민사소송법 제418조의 규정

(1) 원칙 : 필수적 환송

- 민사소송법 제418조 본문은 소를 각하한 제1심 판결을 취소하는 경우에 그 소송절차가 본안판결을 할 수 있을 정도로 심리되어 있지 않다면 항소 심 법원은 사건을 제1심 법원에 환송하여야 한다고 규정하고 있다. 이는 제1심에서 본안심리가 이루어지지 않았음을 전제로 한다.

(2) 예외 : 재판의 허용

- 다만, 동조 단서에서는 사건이 본안판결을 할 수 있을 정도로 충분히 심리되었거나, 당사자의 동의가 있는 경우에는 항소심 법원이 스스로 본안판 결을 할 수 있도록 규정하고 있다.

2. 심급의 이익 관점

(1) 의의

- 심급의 이익이란 당사자가 동일한 쟁점에 대하여 하급심과 상급심에서 반복하여 재판을 받을 수 있는 권리를 의미한다. 우리 민사소송법은 원칙적 으로 3심제를 채택하여 당사자에게 충분한 방어 기회를 부여하고 있다.

(2) 소각하판결과 심급의 이익

- 제1심에서 소제기 요건만을 이유로 소를 각하한 경우, 본안의 실체적 쟁점에 대해서는 아무런 심리가 이루어지지 않은 상태이다. 만약 항소심이 곧 바로 본안판결을 내린다면, 당사자는 실질적으로 본안에 대하여 단 한 번의 사실심 재판만을 받게 되어 3심제 하에서의 심급의 이익을 침해당하게 된다. 따라서 제418조 본문의 필수적 환송 규정은 이러한 심급의 이익을 보장하기 위한 제도적 장치이다.

3. 환송 여부의 판단 기준

(1) 본안심리의 정도

- 제1심에서 비록 소각하판결을 하였더라도, 기록상 본안에 관한 증거조사가 충분히 이루어져 항소심에서 즉시 판결을 내릴 수 있는 상태라면 예외 적으로 재판이 가능하다.

(2) 당사자의 동의

- 심급의 이익은 사익적 성격이 강하므로, 당사자가 신속한 재판을 위해 항소심에서의 재판에 동의한다면 환송하지 않고 직접 판결할 수 있다.

III. 사안의 적용

1. 제1심 판결의 부당성 확인

- 사안에서 항소심 법원은 심리 결과 제1심의 판단과 달리 소의 요건이 구비되어 적법하다고 판단하였다. 따라서 제1심의 소각하판결은 부당하므로 항소심 법원은 이를 취소하여야 한다.

2. 필수적 환송의 원칙 적용

- 문제에서 항소심 법원은 본안 심리를 충분히 하지 않은 상태라고 명시하고 있다. 이는 민사소송법 제418조 단서의 재판 요건인 사건이 본안판결을 할 수 있을 정도로 심리되었을 때에 해당하지 않음을 의미한다.

3. 심급의 이익 보호의 필요성

- 원고 A와 피고 B는 본안의 실체 관계(손해배상 책임의 유무 등)에 대하여 제1심 법원의 판단을 받을 기회를 전혀 가지지 못하였다. 만약 항소심 법원 이 재판을 강행할 경우 당사자의 심급의 이익이 심각하게 침해된다. 따라서 특별한 사정(당사자의 전원 동의 등)이 없는 한 법원은 사건을 제1심 법원으 로 환송하여 본안 심리를 처음부터 다시 받게 해야 한다.

IV. 결론

- 민사소송법 제418조에 의하면 제1심의 소각하판결이 부당하여 취소하는 경우, 본안 심리가 충분히 이루어지지 않았다면 사건을 제1심 법원으로 환 송하는 것이 원칙이다.(필수적 환송) 이는 당사자가 본안에 대하여 하급심의 판단을 받아볼 수 있는 심급의 이익을 보호하기 위함이다. 사안의 경우 본안 심리가 불충분하므로 항소심 법원은 스스로 판결을 내릴 것이 아니라 사건을 제1심 법원으로 환송하여야 한다.

《【문제15.2】

<사례>

甲은 乙을 상대로 대여금 청구소송을 제기하여 제1심과 항소심에서 모두 승소하였다. 항소심 판결은 2024. 3. 1. 乙에게 송달되었고, 乙은 항소심 판결 중 사실인정에 채증법칙 위반의 잘못이 있고 대여금의 소멸시효가 완성되었음을 주장하며 상고를 제기하고자 한다.

그런데 乙은 상고장 제출 당시 상고이유를 기재하지 않았고, 상고기록 접수통지를 받은 날로부터 20일이 지나도록 상고이유서를 제출하지 않았다. 그 후 乙은 뒤늦게 상고이유서를 제출하면서, 항소심 판결에 관여한 판사 A가 제1심 판결에도 관여하여 민사소송법 제424조 제1항 제1호의 법률에 따라 판결에 관여할 수 없는 판사가 판결에 관여한 때에 해당한다는 점을 새로이 주장하였다.

또한, 별개의 사건에서 丙은 丁을 상대로 소를 제기하였으나 항소심에서 패소하였다. 丙은 상고심에서 항소심 판결이 이유를 밝히지 아니하거나 이유에 모순이 있는 때에 해당한다며 상고하였다. 그런데 대법원은 심리 중 丙의 상고이유와는 별개로, 이 사건 항소심 재판의 전제가 된 소송대리권의 흠결이나 전속관할 위반 여부 등에 대해 의문을 갖게 되었다.

(물음1) 乙이 상고이유서 제출기한을 도과하여 제출한 상고이유서에 기재된 절대적 상고이유(판결에 관여할 수 없는 법관의 관여)를 상고심 법원이 심리할 수 있는지 여부를 민사소송법 제429조(상고이유서를 내지 아니한 경우의 처분)와 관련하여 논하시오.》

<문제15.2의 물음1> 상고이유서 제출기한 도과 후 제출된 절대적 상고이유의 심리 가능성 여부

I. 문제의 제기

- 사안에서 乙이 항소심 판결에 대하여 상고를 제기하였으나 상고이유서 제출기간을 도과한 후 절대적 상고이유를 주장한 상황이다. 쟁점으로 <상고이유서 미제출 또는 지연제출의 경우에도 절대적 상고이유에 해당하는 사유를 상고심 법원이 직권으로 심리할 수 있는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 민사소송법 제429조에 따른 상고이유서 제출의무와 절대적 상고이유의 심리 가능성을 논한다.

II. 상고이유서 제출기한과 상고기각

1. 민사소송법 제427조 및 제429조의 규정

(1) 상고이유서 제출기한

- 상고인은 상고장에 상고이유를 적지 아니한 때에는 상고기록 접수통지를 받은 날부터 20일 이내에 상고이유서를 제출하여야 한다. 이 기한은 법정 기간으로서 연장될 수 없는 것이 원칙이다.

(2) 기한 도과의 효과

- 민사소송법 제429조 본문에 의하면 상고인이 위 기간 내에 상고이유서를 제출하지 아니한 때에는 상고심 법원은 결정이 아닌 판결로 상고를 기각하여야 한다. 이는 상고심의 신속한 진행을 위한 제재적 규정이다.

2. 상고기각 판결의 예외

- 민사소송법 제429조 단서에 의하면 상고이유서가 제출되지 않았거나 기한을 넘겼더라도, 상고장에 상고이유가 적혀 있거나 직권으로 조사하여야 할 사유가 있는 경우에는 기한 도과를 이유로 바로 상고를 기각할 수 없다.

III. 절대적 상고이유의 심리 가능성

1. 절대적 상고이유의 의의 및 성격

(1) 의의

- 민사소송법 제424조 제1항 각 호에 규정된 사유들로, 판결에 관여할 수 없는 판사가 판결에 관여한 경우(제1호), 법률에 따라 판결에 관여할 수 없는 법관이 판결에 관여한 경우 등을 포함한다.

(2) 법적 성격

- 이러한 사유들은 소송절차의 중대한 하자를 구성하며, 당사자의 상고이유 기재 여부와 관계없이 법원이 직권으로 조사하여 판결의 당부를 판단해야 하는 직권조사사항에 해당한다.

2. 제출기한 도과와의 관계

(1) 직권조사사항에 대한 판례의 태도

- 대법원은 상고이유서 제출기간 내에 상고이유서를 제출하지 않았거나, 기간 경과 후에 상고이유서를 제출한 경우라 하더라도, 그 상고이유서에 기재된 내용이 직권조사사항에 해당하거나 절대적 상고이유에 해당하는 경우에는 법원이 이를 심리하여야 한다고 판단한다.

(2) 법리적 근거

- 상고이유서 제출기한을 두는 목적은 상고심의 효율성이지만, 법률에 어긋난 재판이나 중대한 절차적 하자가 있는 판결을 그대로 확정시키는 것은 재판의 적정성과 정의에 반하기 때문이다. 따라서 제429조 단서의 직권으로 조사하여야 할 사유에는 절대적 상고이유가 포함되는 것으로 해석된다.

IV. 사안의 적용

1. 乙의 상고이유 분석

- 乙이 뒤늦게 주장한 사유는 판결에 관여할 수 없는 판사가 판결에 관여한 경우이다. 이는 민사소송법 제424조 제1항 제1호에 해당하는 절대적 상고이유이자 직권조사사항이다.

2. 법원의 심리 의무

- 乙이 상고기록 접수통지를 받은 날로부터 20일을 지나 상고이유서를 제출한 것은 사실이나, 제출된 내용에 중대한 법률 위반인 절대적 상고이유가 포함되어 있다. 민사소송법 제429조 단서에 따라 직권조사사항이 있는 경우에는 기한 도과를 이유로 상고를 기각할 수 없으므로, 상고심 법원은 乙의 상고이유서 제출 시점과 관계없이 해당 사유를 심리하여야 한다.

V. 결론

- 상고이유서 제출기한을 도과하여 제출된 상고이유서라 하더라도, 그 내용이 민사소송법 제424조 제1항의 절대적 상고이유에 해당하는 경우에는 법원이 이를 직권으로 심리하여야 한다. 이는 민사소송법 제429조 단서가 규정한 직권조사사항의 예외에 해당하기 때문이다. 따라서 사안에서 상고심 법

원은 乙이 주장한 법관의 관여 문제를 심리하여 항소심 판결의 위법 여부를 판단하여야 한다.

《【문제15.2】

<사례>

甲은 乙을 상대로 대여금 청구소송을 제기하여 제1심과 항소심에서 모두 승소하였다. 항소심 판결은 2024. 3. 1. 乙에게 송달되었고, 乙은 항소심 판결 중 사실인정에 채증법칙 위반의 잘못이 있고 대여금의 소멸시효가 완성되었음을 주장하며 상고를 제기하고자 한다.

그런데 乙은 상고장 제출 당시 상고이유를 기재하지 않았고, 상고기록 접수통지를 받은 날로부터 20일이 지나도록 상고이유서를 제출하지 않았다. 그 후 乙은 뒤늦게 상고이유서를 제출하면서, 항소심 판결에 관여한 판사 A가 제1심 판결에도 관여하여 민사소송법 제424조 제1항 제1호의 법률에 따라 판결에 관여할 수 없는 판사가 판결에 관여한 때에 해당한다는 점을 새로이 주장하였다.

또한, 별개의 사건에서 丙은 丁을 상대로 소를 제기하였으나 항소심에서 패소하였다. 丙은 상고심에서 항소심 판결이 이유를 밝히지 아니하거나 이유에 모순이 있는 때에 해당한다며 상고하였다. 그런데 대법원은 심리 중 丙의 상고이유와는 별개로, 이 사건 항소심 재판의 전제가 된 소송대리권의 흠결이나 전속관할 위반 여부 등에 대해 의문을 갖게 되었다.

(물음2) 상고심이 원칙적으로 상고이유서에 기재된 범위 내에서만 심리하는 법률심임에도 불구하고, 丙의 사례와 같이 상고이유에 포함되지 않은 소송요건이나 전속관할 위반 등의 사항을 대법원이 직권으로 조사하여 판단할 수 있는지 그 근거와 한계에 대하여 기술하시오.》

<문제15.2의 물음2> 상고심의 직권조사사항의 근거와 한계

I. 문제의 제기

- 사안에서 丙이 항소심 판결에 대하여 상고를 제기하면서 이유불비 등의 상고이유를 주장하였으나, 상고심 법원이 소송요건이나 전속관할 위반 여부를 별도로 발견한 상황이다. 쟁점으로 <법률심인 상고심이 상고이유서에 기재되지 않은 사항에 대하여도 직권으로 조사·판단할 수 있는지와 그 범위>를 검토할 필요가 있다. 이하에서는 상고심의 심리범위와 직권조사사항의 인정 근거 및 한계를 기술한다.

II. 상고심의 심리 범위와 직권조사사항

1. 변론주의와 직권조사사항의 관계

(1) 원칙(상고이유 구속의 원칙)

- 민사소송법 제431조에 의하면 상고법원은 상고이유에 의하여 불복신청한 범위 안에서 심리한다. 이는 당사자가 제기한 오류에 대해서만 판단하겠다는 취지이다.

(2) 예외(직권조사사항)

- 소송요건이나 전속관할, 소송대리권의 존부 등 소송의 전제가 되는 사항은 당사자의 주장 여부와 상관없이 법원이 스스로 조사하여 판결의 기초로 삼아야 한다. 이는 공공의 이익과 직결되는 절차적 정당성을 확보하기 위함이다.

2. 민사소송법상 근거

(1) 제434조(준용규정)

- 상고심 절차에는 항소심의 규정이 준용되며, 항소심에서는 소송요건 등 직권조사사항에 대해 당사자의 불복 유무를 불문하고 심리할 수 있다.

(2) 제429조 단서

- 상고이유서 제출기한을 도과하더라도 직권으로 조사하여야 할 사유가 있는 경우에는 상고를 기각할 수 없다고 규정하여, 직권조사사항이 상고이유에 우선함을 명시하고 있다.

III. 직권조사사항의 구체적 범위와 근거

1. 소송요건 및 소송대리권

- 소송요건은 법원이 소송의 주체, 객체, 절차에 관하여 공익적 견지에서 미리 확정해 두어야 할 사항이다. 특히 소송대리권의 흠결은 적법한 절차를 거치지 않은 재판이 될 우려가 있으므로 상고심에서도 반드시 직권으로 조사해야 한다.

2. 전속관할

- 관할권 중 전속관할은 국가의 사법행정상 이유나 공익적 목적에 의해 강제된 것이므로, 당사자의 합의나 변론으로 변경할 수 없다. 따라서 전속관할 위반 여부는 상고심의 직권조사 대상이 된다.

3. 절대적 상고이유

- 민사소송법 제424조 제1항 각 호에 규정된 절대적 상고이유(법률에 따라 판결에 관여할 수 없는 판사의 관여 등)는 그 하자가 매우 중대하여 당사자의 주장이 없더라도 대법원이 스스로 파악하여 파기 사유로 삼을 수 있다.

IV. 직권조사의 한계

1. 사실인정의 한계

- 상고심은 법률심이므로 새로운 증거조사를 할 수 없는 것이 원칙이다. 따라서 직권조사사항이라 하더라도 그 기초가 되는 사실관계가 원심 판결문이나 기록에 나타나 있어야 한다. 다만, 소송요건 중 법원의 권한에 속하는 사항은 필요한 경우 예외적으로 사실을 탐지할 수 있다.

2. 상고의 이익에 의한 한계

- 상고인은 자기에게 불이익한 판결에 대해서만 상고할 수 있다. 직권조사사항이라 하더라도 원심 판결이 상고인에게 유리하게 선고되었다면, 상고인이 주장하지 않은 유리한 직권조사사항을 근거로 원심을 파기하는 것은 상고의 이익 원칙에 반할 수 있다.

3. 처분권주의와의 관계

- 청구의 당부와 직접 관련된 본안의 사실관계는 직권조사의 대상이 될 수 없다. 소멸시효의 완성이나 채무의 변제와 같은 항변 사항은 당사자가 상고이유로 주장하지 않는 한 대법원이 직권으로 판단할 수 없다.

V. 사안의 적용

1. 丙의 상고이유와 직권조사사항의 관계

- 사안에서 丙은 이유불비 및 이유모순을 상고이유로 들었으나, 대법원이 인지한 소송대리권의 흠결 및 전속관할 위반은 소송요건 및 공익적 관할에 관한 사항이다. 이는 민사소송법상 직권조사사항에 해당하므로 丙의 상고이유 포함 여부와 관계없이 대법원이 심리할 수 있다.

2. 대법원의 판단 가능성

- 대법원은 상고이유서에 기재되지 않은 사항이라 하더라도 소송대리권 흠결 여부를 조사하여야 한다. 만약 대리권이 없거나 전속관할을 위반한 사실이 기록상 확인된다면, 丙이 주장한 이유불비에 대한 판단에 앞서 원심판결을 직권으로 파기하고 사건을 환송하거나 이송하여야 한다.

Ⅴ. 결론

- 상고심은 법률심으로서 상고이유에 구속되는 것이 원칙이나, 소송요건이나 전속관할 위반 등과 같은 직권조사사항에 대해서는 그 한계를 준수하는 범위 내에서 상고이유에 포함되지 않았더라도 직권으로 심리·판단할 수 있다. 이는 사법 정의의 실현과 적법절차의 원칙을 수호하기 위한 법원의 책무이기 때문이다. 따라서 대법원은 丙의 사례에서 발견된 절차적 흠결을 직권으로 조사하여 판결에 반영할 수 있다.

《【문제15.3】

<사례>

甲은 乙을 상대로 소유권이전등기청구소송을 제기하여 항소심에서 승소하였다. 피고 乙은 이에 불복하여 2024. 4. 1. 상고장을 제출하였고, 대법원은 2024. 4. 15. 乙에게 상고기록접수통지서를 송달하였다. 乙은 상고이유서를 작성하던 중 지병으로 입원하게 되어, 통지서를 받은 날로부터 21일째 되는 날 예야 상고이유서를 우체국에 접수하였다.

한편, 乙이 제출한 상고이유서에는 원심판결이 법령의 해석을 그르쳐 대법원 판례와 상반되는 판단을 하였다는 내용이 포함되어 있었다. 대법원은 이 사건이 상고심절차에 관한 특별법 제4조에서 정한 심리불속행 사유에 해당하는지 여부를 검토하고 있다.

또한, 별개의 소송에서 丙은 丁을 상대로 손해배상을 청구하였으나 항소심에서 기각되었다. 丙은 상고심에서 항소심이 판단하지 않은 새로운 사실관계인 丁의 추가적인 불법행위를 주장하며 관련 증거를 대법원에 제출하였다. 대법원은 丙이 제출한 새로운 증거를 기초로 항소심 판결을 뒤집을 수 있는지 확인 중이다.

(물음1) 乙이 상고기록접수통지를 받은 날로부터 20일의 기간을 도과하여 상고이유서를 제출한 경우, 대법원이 민사소송법 제429조에 따라 취해야 할 조치와 만약 乙이 제출한 상고이유서에 직권조사사항에 해당하는 내용이 포함되어 있다면 재판 결과가 달라질 수 있는지 논하시오.》

<문제15.3의 물음1> 상고이유서 제출기한 도과에 따른 대법원의 조치와 직권조사사항 포함 시 재판 결과의 변화

I. 문제의 제기

- 사안에서 乙은 상고기록접수통지를 받은 후 법정기간인 20일을 경과하여 상고이유서를 제출하였고, 그 상고이유서에는 직권조사사항에 해당할 수 있는 내용도 포함되어 있는 상황이다. 쟁점으로 <상고이유서 제출기간을 도과한 경우 대법원이 민사소송법 제429조에 따라 어떠한 조치를 하여야 하는지>와 <상고이유서에 직권조사사항이 포함된 경우 그에 따라 재판 결과가 달라질 수 있는지>를 검토할 필요가 있다. 이하에서는 상고이유서 제출기간 도과의 효과와 직권조사사항이 있는 경우의 심리 및 재판 가능성을 논한다.

II. 상고이유서 제출기한 도과와 대법원의 조치

1. 상고이유서 제출기간의 성격

- 민사소송법 제427조는 상고인이 상고기록접수통지를 받은 날부터 20일 이내에 상고이유서를 제출하여야 한다고 규정하고 있다. 이 기간은 불변기간은 아니나, 소송절차의 신속을 기하기 위한 법정기간으로서 그 준수 여부는 엄격하게 판단된다.

2. 기한 도과 시의 원칙적 조치(상고기각판결)

(1) 민사소송법 제429조의 규정

- 상고인이 제427조의 기간 내에 상고이유서를 제출하지 아니한 때에는 상고법원은 변론 없이 판결로 상고를 기각하여야 한다. 이는 상고이유의 부존재를 법률상 추정하여 신속하게 절차를 종결하기 위함이다.

(2) 예외적 수리 가능성

- 대법원 판례에 의하면, 상고이유서 제출기한을 단 하루라도 도과한 경우에는 원칙적으로 기각 대상이다. 다만, 제출기한 내에 상고이유를 기재하지 않은 상고장을 제출하였더라도 대법원이 상고기각판결을 내리기 전까지 상고이유서를 제출하였다면 이를 참작해야 한다는 견해가 있으나, 현행법상 20일의 기한은 강행적 의미를 갖는다.

III. 직권조사사항이 포함된 경우의 재판 결과 변화

1. 민사소송법 제429조 단서의 취지

- 민사소송법 제429조 단서는 상고장에 상고이유가 적혀 있는 때 또는 직권으로 조사하여야 할 사유가 있는 때에는 기한 도과를 이유로 상고를 기각할 수 없다고 규정하고 있다. 이는 절차적 태만보다 실체법적 혹은 절차법적 중대 하자를 우선시하겠다는 입법적 결단이다.

2. 직권조사사항의 범위와 효력

(1) 범위

- 직권조사사항이란 소송요건의 존부, 전속관할 위반, 소송대리권의 흠결, 재판권의 부존재 등 법원이 당사자의 주장 여부와 관계없이 스스로 조사하여 판단해야 할 사항을 의미한다.

(2) 효력

- 乙이 제출한 상고이유서가 비록 20일의 기간을 도과하여 제출되었다 하더라도, 그 내용 중에 위와 같은 직권조사사항에 해당하는 중대한 하자가 포함되어 있다면 대법원은 제429조 본문에 따른 상고기각판결을 할 수 없다. 이 경우 대법원은 기한 도과 사실을 묵인하고 본안심리에 들어가 직권조사사항에 대한 판단을 내려야 한다.

IV. 사안의 적용

1. 乙의 상고이유서 제출과 기한 도과

- 乙은 2024. 4. 15. 통지를 받았으므로 그로부터 20일이 되는 날은 2024. 5. 5.이다. 乙이 21일째 되는 날에 우체국에 접수하였다면 이는 명백한 기한 도과에 해당한다. 지병으로 인한 입원은 특별한 사정이 없는 한 민사소송법상 추완 사유나 기한 연장 사유로 인정되기 어렵다. 따라서 원칙적으로 대법원은 무변론 상고기각판결을 내려야 한다.

2. 직권조사사항 포함 시의 결과

- 그러나 乙이 늦게 제출한 상고이유서에 단순한 법리 오해나 사실인정의 오류를 넘어, 소송요건 흠결과 같은 직권조사사항이 포함되어 있다면 상황은 반전된다. 민사소송법 제429조 단서에 의해 대법원은 기한 도과를 이유로 상고를 기각할 수 없으며, 해당 직권조사사항을 심리하여 원심판결의 적법성을 판단해야 한다.

3. 상반된 판단(제4조 사유)과의 구별

- 乙이 주장한 대법원 판례와 상반되는 판단은 상고심절차 특별법상의 심리불속행 제외 사유일 뿐, 그 자체로 민사소송법 제429조 단서의 직권조사사항은 아니다. 따라서 乙이 제출한 내용이 단순한 판례 위반 주장이라면 기각을 면할 수 없으나, 별도의 소송요건 흠결 등이 포함되어 있다면 재판 결과는 기각에서 본안심리(파기 혹은 기각)로 달라지게 된다.

V. 결론

- 乙이 상고이유서 제출기한을 도과한 경우 대법원은 원칙적으로 민사소송법 제429조 본문에 따라 변론 없이 판결로 상고를 기각하여야 한다. 그러나 乙이 제출한 상고이유서에 소송대리권 흠결이나 전속관할 위반 등 직권조사사항이 포함되어 있다면, 대법원은 기한 도과를 이유로 상고를 기각할 수 없으며 해당 사유를 심리하여 판결해야 하므로 재판 결과는 달라진다.

《【문제15.3】

<사례>

甲은 乙을 상대로 소유권이전등기청구소송을 제기하여 항소심에서 승소하였다. 피고 乙은 이에 불복하여 2024. 4. 1. 상고장을 제출하였고, 대법원은 2024. 4. 15. 乙에게 상고기록접수통지서를 송달하였다. 乙은 상고이유서를 작성하던 중 지병으로 입원하게 되어, 통지서를 받은 날로부터 21일째 되는 날 예야 상고이유서를 우체국에 접수하였다.

한편, 乙이 제출한 상고이유서에는 원심판결이 법령의 해석을 그르쳐 대법원 판례와 상반되는 판단을 하였다는 내용이 포함되어 있었다. 대법원은 이 사건이 상고심절차에 관한 특례법 제4조에서 정한 심리불속행 사유에 해당하는지 여부를 검토하고 있다.

또한, 별개의 소송에서 丙은 丁을 상대로 손해배상을 청구하였으나 항소심에서 기각되었다. 丙은 상고심에서 항소심이 판단하지 않은 새로운 사실관계인 丁의 추가적인 불법행위를 주장하며 관련 증거를 대법원에 제출하였다. 대법원은 丙이 제출한 새로운 증거를 기초로 항소심 판결을 뒤집을 수 있는지 확인 중이다.

(물음2) 상고심절차에 관한 특례법상 심리불속행 제도의 취지와 적용 범위를 설명하고, 丙의 사례와 같이 상고심에서 새로운 사실이나 증거를 제출하는 것이 법률심의 원칙상 허용되는지 여부를 판례의 태도에 근거하여 기술하시오.》

<문제15.3의 물음2> 심리불속행 제도의 취지 및 범위와 상고심에서 새로운 사실 및 증거 제출의 허용 여부

I. 문제의 제기

- 사안에서 대법원은 상고이유가 심리불속행 대상에 해당하는지를 검토하고 있으며, 별개의 사례에서는 상고심에서 새로운 사실과 증거를 제출하여 원심판결을 다투려는 상황이다. 쟁점으로 <상고심절차에 관한 특례법상 심리불속행 제도의 취지와 적용 범위 및 상고심에서 새로운 사실이나 증거를 제출하는 것이 법률심의 원칙상 허용되는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 심리불속행 제도의 취지와 적용 범위 및 상고심에서 새로운 사실과 증거 제출의 허용 여부를 기술한다.

II. 심리불속행 제도의 취지와 적용 범위

1. 제도의 취지

- 심리불속행 제도란 상고이유에 관한 주장이 법률령 위반 등 특례법이 정한 특정한 사유를 포함하지 않는 경우, 더 이상의 본안 심리를 거치지 않고 판결로 상고를 기각하는 제도이다. 이는 대법원에 사건이 과도하게 집중되는 것을 방지하여 사법 자원을 효율적으로 배분하고, 중대한 법령 해석의 통일이 필요한 사건에 집중함으로써 최고법원으로서의 기능을 정상화하는 데 그 목적이 있다.

2. 적용 범위

(1) 대상 사건

- 심리불속행 제도는 민사사건, 가사사건, 행정사건의 상고심 절차에 적용된다. 다만, 형사사건에는 적용되지 않으며, 민사사건 중에서도 재심사건이나 전원합의체에서 다루어야 할 판례 변경의 필요성이 있는 사건 등은 제외될 수 있다.

(2) 심리불속행 사유(특례법 제4조)

- 대법원은 상고이유에 관한 주장이 다음 각 호의 사유를 포함하지 아니한다고 인정하면 더 나아가 심리를 하지 아니한다. ① 원심판결이 헌법에 위반되거나 헌법을 부당하게 해석한 경우, ② 원심판결이 법령의 해석을 그르쳐 대법원 판례와 상반되는 판단을 한 경우, ③ 대법원 판례가 없거나 이를 변경할 필요가 있는 경우, ④ 그 밖에 중대한 법령 위반이 있는 경우 등이다.

III. 상고심에서 새로운 사실 및 증거 제출의 허용 여부

1. 법률심 및 사후심의 원칙

- 상고심은 원심판결 시까지 제출된 자료를 기초로 원심판결의 법률적 정당성을 판단하는 사후심이다. 따라서 사실심의 변론종결 전까지 주장하고 입증하지 아니한 새로운 사실을 상고심에서 주장하거나 증거를 제출하는 것은 원칙적으로 허용되지 않는다.

2. 판례의 태도

(1) 새로운 사실과 증거의 배척

- 판례는 상고심은 법률심이므로 새로운 증거조사를 할 수 없고, 상고심에서 비로소 주장하는 새로운 사실이나 제출하는 새로운 증거는 원심판결의 당부를 판단하는 자료로 삼을 수 없다는 입장을 일관되게 유지하고 있다.

(2) 예외적 허용 사항

- 다만, 소송요건에 관한 사항이나 전속관할, 소송대리권 등 법원이 직권으로 조사하여야 할 사항에 대해서는 상고심에서도 새로운 자료를 제출할 수 있으며, 법원은 이를 참작하여 판단할 수 있다. 그러나 본안에 관한 실체적 사실관계에 대해서는 엄격히 금지된다.

IV. 사안의 적용

1. 乙의 사례와 심리불속행

- 乙은 상고이유서에 원심판결이 대법원 판례와 상반되는 판단을 하였다고 명시하였다. 이는 상고심절차 특례법 제4조 제1항 제2호에 해당하는 사유로, 만약 대법원이 심리 결과 실제로 판례 위반의 소지가 있다고 판단한다면 심리불속행 기각을 할 수 없고 본안 심리를 속행하여야 한다.

2. 丙의 사례와 새로운 증거 제출

- 丙은 항소심에서 판단하지 않은 새로운 사실관계인 丁의 추가적인 불법행위와 관련 증거를 대법원에 제출하였다. 이는 전형적인 새로운 실체적 사실의 주장 및 증거 제출에 해당한다. 상고심은 법률심이자 사후심으로서 원심 변론종결 시를 기준으로 판결의 당부를 가려야 하므로, 대법원은 丙이 제출한 새로운 증거를 기초로 항소심 판결을 뒤집을 수 없다. 丙의 주장은 원심 판결에 대한 적법한 상고이유가 될 수 없으며 대법원은 이를 심리 자료로 삼아서는 안 된다.

V. 결론

- 심리불속행 제도는 대법원의 기능 효율화를 위해 중대한 법령 위반이 없는 상고를 조기에 종결시키는 제도이며, 특례법 제4조의 사유가 없는 경우에 적용된다. 또한 상고심은 법률심이자 사후심이므로 丙이 제출한 새로운 사실관계와 증거는 원심판결의 당부를 판단하는 근거가 될 수 없다. 따라서 대법

원은 丙의 새로운 증거를 배척하고 원심판결 당시의 자료만을 토대로 법률적 판단을 내려야 한다.

《【문제15.4】

<사례>

甲은 乙을 상대로 대여금 청구소송을 제기하여 제1심에서는 승소하였으나, 항소심에서는 乙의 소멸시효 항변이 받아들여져 패소하였다. 甲은 이에 불복하여 상고하였고, 대법원은 심리 결과 항소심이 소멸시효 중단에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있다고 판단하였다. 이에 대법원은 항소심 판결을 파기하고 사건을 다시 심리하도록 하기 위해 원심법원인 고등법원으로 환송하는 판결을 선고하였다.

파기환송 판결을 받은 환송 후 원심법원은 재판을 다시 진행하게 되었다. 그런데 환송 후 원심법원의 재판부는 대법원이 파기 사유로 삼았던 법적 판단이 최근의 다른 유사 사건에 대한 대법원 전원합의체 판결의 취지와 배치된다고 생각하여, 대법원의 기속력에 반하여 기존 항소심 판결과 동일한 취지로 甲의 청구를 기각하는 판결을 내리고자 한다.

한편, 별개의 사건에서 丙은 丁을 상대로 소유권이전등기청구소송을 제기하여 항소심에서 승소하였다. 丁이 상고하였으나 대법원은 상고이유가 없다고 판단하여 상고기각 판결을 선고하였다. 그 후 丙은 상고심 재판 과정에서 대법원이 중요한 증거를 판단에서 누락하였다는 대법원에 다시 한번 판단을 구해달라고 요청하고 있다.

(물음1) 대법원이 원심판결을 파기하고 사건을 환송한 경우, 환송을 받은 법원이 대법원의 파기이유가 된 사실상 및 법률상 판단에 기속되는지 여부(기속력)와 그 범위에 대하여 설명하고, 만약 환송 후 새로운 증거가 제출되어 사실관계가 변동된 경우에도 여전히 대법원의 판단에 구속되는지 논하시오.》

<문제15.4의 물음1> 파기환송 판결의 기속력 및 범위와 사실관계 변동 시 기속력의 한계

I. 문제의 제기

- 사안에서 대법원이 항소심판결을 파기환송한 후 환송법원이 대법원의 법리판단과 달리 재판하러 하고, 환송 후에는 새로운 증거 제출로 사실관계의 변동 가능성도 있는 상황이다. 쟁점으로 <파기환송판결의 기속력이 환송법원의 사실상 및 법률상 판단에 어떠한 범위까지 미치는지>와 <환송 후 새로운 증거 제출 등으로 사실관계가 변동된 경우에도 대법원의 판단에 계속 기속되는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 파기환송판결의 기속력과 그 범위 및 사실관계 변동이 있는 경우의 기속력의 효력을 논한다.

II. 파기환송 판결의 기속력과 범위

1. 기속력의 의미

- 민사소송법 제436조 제2항은 상고법원이 파기의 이유로 삼은 사실상 및 법률상의 판단은 하급심을 기속한다고 규정하고 있다. 이는 재판의 확정력을 보장하고 소송경제 및 심급제도의 목적을 달성하기 위한 법적 강제력이다. 환송받은 법원은 대법원이 파기 사유로 명시한 판단과 상반되는 결론을 내릴 수 없다.

2. 기속력의 범위

(1) 주관적 범위

- 기속력은 사건을 환송받은 원심법원뿐만 아니라, 그 사건이 다시 상고되었을 때의 재상고심 법원에도 미친다. 따라서 동일한 사건에 대하여 대법원은 스스로 내린 이전의 파기 이유와 다른 판단을 할 수 없는 것이 원칙이다.

(2) 객관적 범위

- 판결의 기속력은 파기의 이유가 된 판단에만 미친다. 즉, 상고심에서 판단의 기초가 된 사실상 판단과 법률상 판단 모두에 미친다. 다만, 대법원이 판단하지 않은 사항이나 방론(Obiter Dictum)에 해당하는 부분에 대해서는 기속력이 발생하지 않는다.

III. 기속력의 한계와 사실관계 변동 시의 처리

1. 기속력의 한계 사유

(1) 새로운 사실의 주장과 증거의 제출

- 환송 후 원심법원의 심리 과정에서 새로운 사실이 주장되거나 새로운 증거가 제출되어 대법원 판결의 기초가 되었던 사실관계에 변동이 생긴 경우에는 대법원의 판단은 더 이상 기속력을 가지지 않는다. 이는 기속력이 동일한 사실관계를 전제로 하기 때문이다.

(2) 법령의 변경 및 판례의 변경

- 환송 후 법률이 개정되거나 대법원 전원합의체 판결에 의하여 환송 판결의 기초가 된 법리가 변경된 경우에도 기속력은 상실된다. 하급심 법원은 변경된 법령이나 판례에 따라 재판할 의무가 있기 때문이다.

2. 판례의 태도

- 판례는 상고법원이 파기 이유로 삼은 판단은 환송받은 법원을 기속하지만, 환송 후의 심리과정에서 새로운 증거가 제출되어 기속력의 판단 기초가 된 사실관계에 변동이 생긴 때에는 그 기속력이 미치지 않는다고 판시하고 있다. 즉, 환송 후 법원이 대법원이 전제한 사실과 다른 사실을 확정하는 것은 기속력 위반이 아니다.

IV. 사안의 적용

1. 법리 판단에 대한 기속력 준수 여부

- 사안에서 환송 후 원심법원은 대법원의 법적 판단이 최근의 다른 전원합의체 판결과 배치된다고 생각하여 기존 항소심과 동일한 취지로 판결하고자 한다. 그러나 당해 사건에 대하여 대법원이 내린 구체적인 파기환송 판결의 기속력은 하급심을 엄격히 구속한다. 만약 해당 법리가 실제로 변경되었다 하더라도, 그것이 당해 사건의 파기환송 판결 이후에 확립된 전원합의체 판결이 아니라면 환송 후 법원은 대법원의 판단을 따라야 한다. 임의로 기속력에 반하는 판결을 하는 것은 심급질서 위반이다.

2. 사실관계 변동 시의 기속력 배제

- 만약 환송 후의 재판 과정에서 甲이나 乙이 새로운 증거를 제출하여 소멸시효 중단과 관련된 사실관계 자체가 대법원이 판단했을 때와 달라졌다면 이야기는 달라진다. 사실관계의 변동은 기속력의 전제를 무너뜨리므로, 환송 후 법원은 변동된 사실을 기초로 독자적인 판단을 내릴 수 있다. 이 경우 대법원의 판단에 구속되지 않고 제반 사정을 고려하여 다시 판결할 수 있다.

V. 결론

- 대법원의 파기환송 판결은 환송 후 원심법원을 사실상·법률상으로 기속하므로 법원은 이에 따라 재판해야 함이 원칙이다. 그러나 환송 후 새로운 증거의 제출 등으로 인해 대법원 판결의 기초가 되었던 사실관계가 변동된 경우에는 기속력이 미치지 않는다. 따라서 사안의 환송 후 원심법원은 단순히 법리에 대한 견해 차이만으로는 대법원의 판단을 거부할 수 없으나, 새로운 증거에 의해 사실관계가 달라졌음이 확인된다면 대법원의 판단에 구속되지 않고 새로운 판결을 할 수 있다.

《【문제15.4】

<사례>

甲은 乙을 상대로 대여금 청구소송을 제기하여 제1심에서는 승소하였으나, 항소심에서는 乙의 소멸시효 항변이 받아들여져 패소하였다. 甲은 이에 불복하여 상고하였고, 대법원은 심리 결과 항소심이 소멸시효 중단에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있다고 판단하였다. 이에 대법원은 항소심 판결을 파기하고 사건을 다시 심리하도록 하기 위해 원심법원인 고등법원으로 환송하는 판결을 선고하였다.

파기환송 판결을 받은 환송 후 원심법원은 재판을 다시 진행하게 되었다. 그런데 환송 후 원심법원의 재판부는 대법원이 파기 사유로 삼았던 법적 판단이 최근의 다른 유사 사건에 대한 대법원 전원합의체 판결의 취지와 배치된다고 생각하여, 대법원의 기속력에 반하여 기존 항소심 판결과 동일한 취지로 甲의 청구를 기각하는 판결을 내리고자 한다.

한편, 별개의 사건에서 丙은 丁을 상대로 소유권이전등기청구소송을 제기하여 항소심에서 승소하였다. 丁이 상고하였으나 대법원은 상고이유가 없다고 판단하여 상고기각 판결을 선고하였다. 그 후 丙은 상고심 재판 과정에서 대법원이 중요한 증거를 판단에서 누락하였다는 대법원에 다시 한번 판단을 구해달라고 요청하고 있다.

(물음2) 대법원이 원심판결을 파기할 때 반드시 사건을 환송해야 하는지, 아니면 직접 중국판결을 내릴 수 있는 파기자판의 요건은 무엇인지 기술하시오. 또한 丙의 사례와 같이 상고기각 판결이 확정된 후 대법원 판결의 당부(當否)를 일반적인 상소 절차로 다시 다룰 수 있는지 여부를 설명하시오.》

<문제15.4의 물음2> 파기자판의 요건 및 상고기각 판결 확정 후의 불복 방법

I. 문제의 제기

- 사안에서 대법원은 항소심판결을 파기하여 환송하였고, 별개의 사례에서는 상고기각 판결이 확정된 후 그 판단의 당부를 다시 다투려는 상황이다. 쟁점으로 <대법원이 원심판결을 파기한 경우 반드시 환송하여야 하는지> 또는 <직접 중국판결을 하는 파기자판이 가능한 요건과 상고기각 판결이 확정된 후 그 당부를 일반적인 상소절차로 다시 다룰 수 있는지>를 검토할 필요가 있다. 이하에서는 파기자판의 요건과 상고기각 판결에 대한 일반 상소의 허용 여부를 설명한다.

II. 파기자판의 의의 및 요건

1. 파기자판의 의의

- 파기자판이란 상고법원이 원심판결을 파기한 경우, 사건을 하급심으로 돌려보내지 않고 스스로 사건의 실체에 대하여 중국판결을 내리는 것을 말한다. 이는 민사소송법 제437조에 규정되어 있으며, 상고법원의 법률심적 성격에 대한 예외에 해당한다.

2. 파기자판의 요건

(1) 확정된 사실에 대한 법령적용의 오류

- 확정된 사실에 대하여 법령을 적용함이 부적당하다는 이유로 판결을 파기하는 경우로서, 사건이 심리 부족 등의 사유 없이 충분히 성숙하여 상고법원이 직접 판결하기에 충분한 상태여야 한다.

(2) 사건이 재판하기에 충분히 성숙한 경우

- 원심이 확정된 사실만으로도 즉시 판결을 내릴 수 있을 정도로 소송자료가 갖추어져 있어야 한다. 만약 추가적인 증거조사나 사실확정이 필요하다면 재판할 수 없고 환송해야 한다.

(3) 소송경제 및 재판의 신속

- 사건을 환송하는 것이 불필요한 절차의 반복을 초래하거나, 재판의 신속을 기하기 위해 상고법원이 직접 결론을 내리는 것이 합리적이라고 판단되는 경우이다.

III. 확정된 상고심 판결에 대한 불복 방법

1. 일반적인 상소 절차의 불가능

(1) 심급의 종료

- 상고심 판결은 선고와 동시에 확정된다. 확정된 판결에 대해서는 더 이상 항소나 상고와 같은 통상의 상소 절차를 통해 당부(當否)를 다룰 수 없다. 이는 재판의 확정력(기판력) 때문이다.

(2) 상고기각 판결의 효과

- 대법원이 상고기각 판결을 내리면 원심판결이 확정된다. 丙이 주장하는 증거 누락 등의 사유는 상고심 절차 내에서의 오류를 주장하는 것이나, 이미 판결이 선고되어 확정된 이상 일반적인 방법으로는 구제받을 수 없다.

2. 재심 절차를 통한 불복

(1) 재심의 의의

- 확정된 중국판결에 중대한 흠이 있는 경우, 예외적으로 그 판결의 부당함을 다투어 취소를 구하고 다시 심판을 청구하는 비상구제방법이다.

(2) 재심사유 [민사소송법 제451조]

- 재판에 영향을 미칠 중요한 사항에 관하여 판단을 누락한 경우(제1항 제9호) 등 법이 정한 엄격한 재심사유가 있어야 한다. 丙이 주장하는 중요한 증거의 판단 누락은 재심사유에 해당할 여지가 있으나, 이는 상고심 판결 자체가 아닌 원심판결의 흠을 다투는 것이라면 상고심 판결에 대한 재심이 아닌 원심판결에 대한 재심 청구의 형식을 취해야 할 경우도 있다.

IV. 사안의 적용

1. 파기자판 가능성 판단

- 대법원이 소멸시효 중단에 관한 법리 오해를 이유로 판결을 파기할 때, 만약 원심이 확정된 사실관계만으로도 시효 중단 여부를 법률적으로 명백히 확정할 수 있다면 대법원은 사건을 환송하지 않고 직접 재판하여 甲의 승소 판결을 내릴 수 있다. 그러나 사실관계에 대한 추가 확인이 필요하다면 반드시 환송해야 한다.

2. 丙의 구제 방법

- 丙은 이미 상고기각 판결이 확정되었으므로 다시 한번 판단해달라는 일반적인 요청(상고 등)으로는 구제받을 수 없다. 오직 민사소송법 제451조에
서 정한 재심사유를 갖추어 재심의 소를 제기함으로써만 확정 판결의 효력을 다룰 수 있다. 丙이 주장하는 증거 누락이 재심사유인 판단누락에 해당한다
면 재심 절차를 통해 다시 재판받을 가능성이 열려 있다.

V. 결론

- 상고법원은 법리 오해 등으로 파기할 때 사실관계가 확정되어 자판하기에 충분하면 파기자판을 할 수 있으나, 그렇지 않으면 환송함이 원칙이다. 확
정된 상고심 판결에 대해서는 통상의 상소로 다룰 수 없으며, 丙은 재심사유가 존재함을 입증하여 재심 절차를 통해서만 불복할 수 있다.

《【문제16.2】

<사례>

甲은 乙을 상대로 소유권이전등기청구소송을 제기하였으나, 제1심 법원은 소장이 접수된 후 인지가 첩부되지 않았음을 이유로 재판장이 보정명령을 내렸음에도 甲이 응하지 않자 소장각하명령을 내렸다. 이에 불복하고자 하는 甲은 소장각하명령 정본을 송달받은 날로부터 1주일 이내에 항고장을 작성하여 항고법원이 아닌 원심법원에 제출하였다.

그런데 甲이 제출한 항고장에는 항고이유가 기재되어 있지 않았으며, 별도의 항고이유서도 기재 기한 내에 제출되지 않았다. 원심법원의 재판장은 항고장에 항고이유가 없음을 발견하였으나, 이를 즉시 각하하지 않고 사건 기록을 항고법원으로 보냈다. 항고법원은 기록을 송부받은 후 甲에게 항고이유를 소명할 것을 요구하는 심리 절차를 진행하고자 한다.

한편, 丙은 丁과의 소송비용액확정 절차에서 법원이 내린 결정에 불복하여 즉시항고를 제기하였다. 丙은 즉시항고장에 항고이유를 적지 않았으나, 항고장을 제출한 날로부터 10일 이내에 구체적인 항고이유를 담은 항고이유서를 원심법원에 제출하였다. 丁은 丙이 항소와 달리 항고이유서를 법정 기한 내에 제출하지 않았으므로 해당 항고가 부적법하다고 주장하고 있다.

(물음1) 甲이 항고장을 항고법원이 아닌 원심법원에 제출한 것이 적법한 절차인지 검토하고, 항고장에 항고이유가 기재되지 않았음에도 원심재판장이 보정명령이나 각하명령을 내리지 않은 경우 항고법원이 취해야 할 심리 방식과 조치에 대하여 논하시오.》

<문제16.2의 물음1> 소장각하명령에 대한 항고절차 및 항고법원의 조치

I. 문제의 제기

- 사안에서 甲은 소장각하명령에 대한 항고장을 원심법원에 제출하였으나 항고이유를 기재하지 않았고, 원심재판장은 별도의 조치 없이 사건기록을 항고법원으로 송부한 상황이다. 쟁점으로 <항고장을 원심법원에 제출한 절차의 적법 여부와 항고장에 항고이유가 기재되지 않았음에도 원심재판장이 보정명령이나 각하명령을 하지 않은 경우 항고법원이 어떠한 심리 방식과 조치를 취하여야 하는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 항고장의 제출 방식의 적법 여부와 항고법원의 심리 방식 및 조치를 논한다.

II. 항고장의 제출 법원 및 적법성 검토

1. 원칙적인 제출 법원

- 민사소송법 제443조에 의해 준용되는 제396조 등에 따르면, 항고는 항고장을 원심법원에 제출함으로써 한다. 이는 상소의 일종인 항소나 상고가 원심법원에 제출되어야 하는 것과 궤를 같이한다.

2. 사안의 경우

- 甲은 소장각하명령에 불복하여 항고장을 작성한 후, 항고법원이 아닌 명령을 내린 원심법원에 제출하였다. 이는 법령이 정한 적법한 절차에 따른 것이므로 제출 법원의 관점에서 甲의 항고는 적법하다.

III. 항고이유 기재 여부에 따른 법원의 조치

1. 항고이유 부기 의무의 성격

(1) 일반항고와 즉시항고의 구별

- 민사소송법상 일반적인 항고의 경우 항고장에 항고이유를 반드시 기재해야 하는 것은 아니며, 항고이유서를 제출하지 않았다고 하여 항고가 바로 부적법해지는 것은 아니다. 그러나 즉시항고의 경우 신속한 결정을 위해 항고이유를 적도록 권장된다.

(2) 소장각하명령에 대한 즉시항고

- 소장각하명령에 대한 불복은 즉시항고(제254조 제4항)에 해당한다. 다만, 항소와 달리 항고 절차에서는 항고이유서를 기간 내에 제출하지 않았다고 하여 항고를 각하한다는 명시적인 규정이 없으므로, 이유 기재가 없다는 사실만으로 곧바로 각하할 수는 없다.

2. 원심재판장의 조치

(1) 항고장 심사권

- 원심재판장은 항고장이 접수되면 형식적 요건을 심사한다. 항고기간의 도과나 인지의 미첩부 등 명백한 부적법 사유가 있다면 보정을 명하거나 각하해야 한다.

(2) 이유 미기재 시의 대응

- 항고이유가 기재되지 않은 것은 항고장의 필수적 기재사항 위반이 아니므로, 원심재판장이 이를 이유로 보정명령을 내리거나 각하할 수는 없다. 따라서 원심재판장이 사건 기록을 항고법원으로 보낸 조치는 적절하다.

3. 항고법원의 조치

(1) 심리 방식

- 항고법원은 기록을 송부받은 후 항고이유가 기재되어 있지 않다면, 항고인에게 항고의 구체적인 이유를 밝히도록 독려하거나 서면 제출을 명하는 심리 절차를 진행해야 한다.

(2) 항고이유의 소명 및 판단

- 항고인이 끝내 이유를 밝히지 않거나 제출된 이유가 이유 없다고 판단되면 항고기각 결정을 내린다. 반대로 원심의 소장각하명령이 부당하다는 점(예 : 이미 인지를 첩부했음에도 착오로 명령이 내려진 경우 등)이 밝혀지면 원심명령을 취소한다.

IV. 사안의 적용

1. 항고장 제출의 적법성

- 甲이 원심법원에 항고장을 제출한 것은 민사소송법 제443조 및 제396조의 취지에 부합하는 적법한 절차이다.

2. 법원의 후속 조치

- 원심재판장이 항고이유 미기재를 이유로 각하하지 않고 기록을 송부한 것은 타당하다. 항고법원은 甲에게 항고이유를 소명할 기회를 부여해야 하며, 甲이 소장각하명령의 원인이 된 인지 미첩부 사유를 해소했거나 명령의 부당함을 소명한다면 항고법원은 원심명령을 취소하고 사건을 다시 진행하도록 해야 한다.

V. 결론

- 甲의 항고장 제출은 적법한 법원에 이루어졌다. 항고이유의 기재는 항소와 달리 강제되는 요건이 아니므로, 항고법원은 즉시 각하할 것이 아니라 심리 절차를 통해 항고인에게 이유 소명 기회를 부여한 후 항고의 당부를 판단해야 한다.

《【문제16.2】

<사례>

甲은 乙을 상대로 소유권이전등기청구소송을 제기하였으나, 제1심 법원은 소장이 접수된 후 인지가 첩부되지 않았음을 이유로 재판장이 보정명령을 내렸음에도 甲이 응하지 않자 소장각하명령을 내렸다. 이에 불복하고자 하는 甲은 소장각하명령 정본을 송달받은 날로부터 1주일 이내에 항고장을 작성하여 항고법원이 아닌 원심법원에 제출하였다.

그런데 甲이 제출한 항고장에는 항고이유가 기재되어 있지 않았으며, 별도의 항고이유서도 기재 기한 내에 제출되지 않았다. 원심법원의 재판장은 항고장에 항고이유가 없음을 발견하였으나, 이를 즉시 각하하지 않고 사건 기록을 항고법원으로 보냈다. 항고법원은 기록을 송부받은 후 甲에게 항고이유를 소명할 것을 요구하는 심리 절차를 진행하고자 한다.

한편, 丙은 丁과의 소송비용액확정 절차에서 법원이 내린 결정에 불복하여 즉시항고를 제기하였다. 丙은 즉시항고장에 항고이유를 적지 않았으나, 항고장을 제출한 날로부터 10일 이내에 구체적인 항고이유를 담은 항고이유서를 원심법원에 제출하였다. 丁은 丙이 항소와 달리 항고이유서를 법정 기한 내에 제출하지 않았으므로 해당 항고가 부적법하다고 주장하고 있다.

(물음2) 즉시항고를 제기한 丙의 사례와 관련하여, 민사소송법 제445조에 규정된 항고이유서 제출 기한의 성질과 이를 준수하지 못했을 때의 효과를 항소이유서 제출 절차와 비교하여 설명하고, 丁의 주장대로 항고이유서 미제출을 이유로 곧바로 항고각하 결정을 내릴 수 있는지 여부를 기술하시오.》

<문제16.2의 물음2> 즉시항고의 항고이유서 제출 기한의 성질과 효과 및 각하 가능성

I. 문제의 제기

- 사안에서 丙은 소송비용액확정 결정에 대하여 즉시항고를 제기하면서 항고장에는 항고이유를 기재하지 않았으나 항고장을 제출한 후 10일 이내에 항고이유서를 제출하였고, 丁은 이를 이유로 항고가 부적법하다고 주장하는 상황이다. 쟁점으로 <민사소송법 제445조상 항고이유서 제출기한의 성질과 그 기한을 준수하지 못한 경우의 효과를 항소이유서 제출 절차와 비교하여 항고이유서 미제출만을 이유로 곧바로 항고각하를 할 수 있는지>를 검토할 필요가 있다. 이하에서는 항고이유서 제출기한의 법적 성질과 미제출 시의 효과 및 항고각하 가능 여부를 기술한다.

II. 즉시항고와 항고이유서 제출

1. 즉시항고이유서 제출 기한 [민사소송법 제445조]

- 민사소송법 제445조는 즉시항고를 제기할 때 항고장에 이유를 적지 아니한 때에는 항고장을 제출한 날부터 10일 이내에 항고이유서를 제출하여야 한다고 규정하고 있다. 이는 2002년 민사소송법 개정 당시 즉시항고 절차의 신속성을 도모하기 위해 신설된 규정이다.

2. 제출 기한의 성질

(1) 훈시적 규정 여부

- 항고이유서 제출 기한인 10일이 불변기간인지, 아니면 단순한 훈시규정인지가 문제 된다. 판례와 통설은 이 기한을 준수하지 않았다고 하여 곧바로 항고를 각하할 수 있는 강제적인 집행력을 가진 기간으로 보지 않는다.

(2) 항소절차와의 비교

- 항소의 경우, 항소장에 이유를 적지 않았더라도 항소기록송부 통지를 받은 날로부터 20일이라는 엄격한 항소이유서 제출 기한이 있고, 이를 어길 시 항소각하 판결을 하도록 규정되어 있다.(제427조, 제429조) 그러나 항고 절차에는 이와 유사한 각하 규정이 존재하지 않는다.

III. 항고이유서 미제출 시의 효과

1. 법적 근거의 부재

- 민사소송법은 항소나 상고의 경우 이유서 미제출 시의 각하 규정을 명시하고 있으나, 항고 절차에서는 제445조를 위반하여 10일 이내에 이유서를 제출하지 않은 경우에 대한 제재 규정을 두고 있지 않다. 따라서 조문의 문언상 기한 도과만으로 항고가 부적법해진다고 단정하기 어렵다.

2. 법원의 심리 의무

- 항고법원은 항고이유서가 기한 내에 제출되지 않았더라도, 항고장에 기재된 내용이나 기록에 나타난 자료를 바탕으로 원심재판의 당부를 심사하여야 한다. 만약 항고이유가 전혀 나타나지 않는다면 보정을 명하거나 심리 절차를 통해 이유를 소명할 기회를 주어야 한다.

IV. 사안의 적용

1. 丙의 항고이유서 제출의 효력

- 사안에서 丙은 즉시항고장을 제출한 날로부터 10일 이내에 항고이유서를 제출하였다. 이는 민사소송법 제445조에서 정한 기간을 준수한 것이며, 설령 이 기간을 도과하여 제출하였다 하더라도 앞서 살펴본 바와 같이 항고 자체가 부적법해지는 것은 아니다.

2. 丁의 주장에 대한 판단

- 丁은 항소이유서 제출 절차를 유추 적용하여 丙의 항고가 부적법하다고 주장한다. 그러나 항고 절차는 항소 절차와 달리 이유서 미제출에 따른 각하 규정이 없으며, 제445조의 기한은 절차의 신속을 위한 권고적 성격이 강하다. 따라서 丙이 이유서를 기한 내에 제출했는지 여부와 상관없이, 이유서가 제출된 이상 법원은 그 내용을 심리해야 하므로 丁의 주장은 타당하지 않다.

V. 결론

- 즉시항고에서 항고이유서 제출 기한(10일)은 항소이유서와 달리 그 미준수 시 각하를 강제하는 효력이 없다. 따라서 丙의 항고는 적법하며, 법원은 丁의 주장대로 항고이유서 제출 시점을 이유로 항고를 각하할 수 없다. 법원은 丙이 제출한 항고이유서를 바탕으로 소송비용액확정 결정의 정당성을 실질적으로 심리하여야 한다.

《【문제17.2】

<사례>

甲은 乙을 상대로 소유권이전등기청구소송을 제기하여 승소 판결을 받았고, 이 판결은 2023. 5. 1. 확정되었다. 그런데 2024. 6. 1. 乙은 위 소송의 핵심 증거였던 매매계약서가 甲에 의해 위조되었다는 사실을 증명하는 형사판결이 확정되었음을 알게 되었다. 이에 乙은 2024. 6. 15. 민사소송법 제451조 제1항 제6호를 재심사유로 하여 재심의 소를 제기하였다.

乙은 재심청구취지에 확정판결을 취소하고, 원고 甲의 청구를 기각한다는 내용을 담았으며, 재심사유로 증거서류의 위조뿐만 아니라 판결에 영향을 미칠 중요한 사항에 관하여 판단을 누락하였다는 점(동조 제1항 제9호)도 함께 주장하였다.

한편, 丙은 丁을 상대로 한 소송에서 패소 판결을 받고 재심을 제기하였으나, 재심법원은 심리 결과 재심사유가 인정되지 않는다는 이유로 재심기각 판결을 선고하였다. 丙은 이 재심기각 판결에 대해서도 다시 재심사유가 존재한다고 재심판결에 대한 재심을 제기하고자 한다.

(물음1) 재심의 소송물을 재심사유(본안전 소송물)와 재심대상판결의 당부(본안 소송물)로 구분하는 견해에 근거하여, 乙이 주장하는 두 가지 재심사유가 하나의 재심의 소에서 어떠한 관계를 갖는지 기술하고, 재심법원이 재심사유가 존재한다고 판단할 경우 본안 심리에 들어가는 절차적 구조에 대하여 설명하시오.》

<문제17.2의 물음1> 재심의 소송물 이론에 따른 재심사유의 관계 및 본안 심리 절차의 구조

I. 문제의 제기

- 사안에서 乙은 확정판결에 대하여 증거서류의 위조와 판단누락을 함께 재심사유로 주장하여 하나의 재심의 소를 제기한 상황이다. 쟁점으로 <재심의 소송물을 재심사유와 재심대상판결의 당부로 구분하는 견해에 비추어 두 재심사유의 관계와 재심법원이 재심사유의 존재를 인정한 후 본안 심리로 나아가는 절차적 구조>를 검토할 필요가 있다. 이하에서는 재심사유의 관계와 재심법원의 본안 심리 절차를 설명한다.

II. 재심의 소송물과 재심사유의 관계

1. 재심의 소송물 이론

(1) 재심사유(본안전 소송물)

- 재심의 소는 먼저 재심대상판결에 민사소송법 제451조 제1항 각 호에서 정한 재심사유가 존재하는지 여부를 심사한다. 이를 본안전 소송물이라 하며, 재심사유의 존부는 본안 심리를 개시하기 위한 요건이 된다.

(2) 재심대상판결의 당부(본안 소송물)

- 재심사유가 인정되면 법원은 원래의 소송 상태로 돌아가 청구의 당부를 다시 심판한다. 이를 본안 소송물이라 하며, 이는 재심대상판결이 되었던 원래 소송의 소송물과 동일하다.

2. 복수의 재심사유 사이의 관계

(1) 병합의 형태

- 하나의 재심의 소에서 여러 개의 재심사유를 주장하는 경우, 이는 소송법상 단순병합의 관계로 본다. 재심법원은 원고가 내세운 여러 사유 중 어느 하나라도 인정되면 재심개시결정을 하거나 본안 심리에 들어갈 수 있다.

(2) 심리의 범위

- 법원은 청구된 재심사유 전부에 대하여 심리할 의무가 있으나, 그중 하나의 사유만 정당하다고 인정되면 나머지 사유에 대하여 별도로 판단하지 않고도 본안 심리로 나아갈 수 있다. 다만, 재심 청구를 기각할 경우에는 주장된 모든 재심사유가 부정됨을 명시하여야 한다.

III. 재심 절차의 구조

1. 재심의 3단계 구조

(1) 제1단계 : 재심의 제소요건 심사

- 재심의 소가 적법한지(당사자 적격, 제척기간 준수 등)를 심사한다. 요건을 갖추지 못한 경우 소각하 판결을 내린다.

(2) 제2단계 : 재심사유의 유무 심사(재심소송절차)

- 주장된 재심사유가 실제로 존재하는지 심리한다. 재심사유가 없으면 재심청구기각 판결을 선고하며, 사안의 丙과 같이 이 판결에 대해서도 다시 재심을 제기할 수 있다.

(3) 제3단계 : 본안사건의 심리(본안소송절차)

- 재심사유가 존재한다고 판단되면, 취소되는 재심대상판결에 의하여 종료되었던 원래의 소송절차를 부활시켜 사건의 본안을 다시 심판한다.

2. 본안 심리로의 이행 방식

(1) 중간판결 또는 재심개시결정

- 현행법상 법원은 재심사유가 인정되는 경우 별도의 중간판결을 거치지 않고 바로 본안 심리를 병행하여 진행한 후 하나의 종국판결로 선고하는 것이 일반적이다. 다만, 재심사유 유무에 관한 판단을 명확히 하기 위해 중간판결 형식을 취할 수도 있다.

(2) 판결의 통합성

- 본안 심리 결과 재심대상판결이 부당하다고 판단되면 이를 취소하고 새로운 판결을 선고한다. 만약 재심사유는 인정되나 본안 심리 결과 재심대상 판결의 결론이 정당하다면 재심청구기각 판결을 내리게 된다.

IV. 사안의 적용

1. 乙이 주장하는 재심사유의 관계

- 乙은 제6호와 제9호의 사유를 함께 주장하고 있으므로 이는 단순병합된 상태이다. 법원은 형사판결 확정으로 증명된 제6호(증거 위조) 사유만으로도 충분히 재심사유의 존재를 인정할 수 있으며, 이 경우 제9호 사유에 대한 판단을 생략하더라도 재심개시에는 지장이 없다.

2. 본안 심리 절차의 구조

- 재심법원은 乙의 소가 제척기간(재심사유를 안 날로부터 30일) 내에 제기되어 적법함을 확인한 후, 증거 위조라는 재심사유를 확정한다. 이후 법원은 소유권이전등기청구라는 원래의 본안 소송물로 돌아가, 위조된 매매계약서를 배제한 상태에서 甲의 청구가 정당한지 다시 심리하여야 한다. 乙이 청

구취지에 담은 원고 甲의 청구 기각 여부는 이 본안 심리 단계에서 최종 결정된다.

V. 결론

- 재심의 소송물 이론에 의할 때 乙의 두 재심사유는 단순병합 관계에 있으며, 법원은 그중 하나라도 인정되면 본안 심리를 개시한다. 절차적으로는 재심사유 존부 심사 후 본안 심리로 이행하며, 최종적으로 재심대상판결의 취소 여부와 원래 청구의 당부를 하나의 종국판결로 확정하게 된다.

《【문제17.2】

<사례>

甲은 乙을 상대로 소유권이전등기청구소송을 제기하여 승소 판결을 받았고, 이 판결은 2023. 5. 1. 확정되었다. 그런데 2024. 6. 1. 乙은 위 소송의 핵심 증거였던 매매계약서가 甲에 의해 위조되었다는 사실을 증명하는 형사판결이 확정되었음을 알게 되었다. 이에 乙은 2024. 6. 15. 민사소송법 제451조 제1항 제6호를 재심사유로 하여 재심의 소를 제기하였다.

乙은 재심청구취지에 확정판결을 취소하고, 원고 甲의 청구를 기각한다는 내용을 담았으며, 재심사유로 증거서류의 위조뿐만 아니라 판결에 영향을 미칠 중요한 사항에 관하여 판단을 누락하였다는 점(동조 제1항 제9호)도 함께 주장하였다.

한편, 丙은 丁을 상대로 한 소송에서 패소 판결을 받고 재심을 제기하였으나, 재심법원은 심리 결과 재심사유가 인정되지 않는다는 이유로 재심기각 판결을 선고하였다. 丙은 이 재심기각 판결에 대해서도 다시 재심사유가 존재한다며 재심판결에 대한 재심을 제기하고자 한다.

(물음2) 재심의 소는 재심사유를 안 날로부터 30일 이내에 제기하여야 하는바, 乙이 주장하는 증거서류의 위조와 판단누락 각각에 대한 재심제기 기간의 기산점이 동일한지 여부를 판단하시오. 또한 丙의 사례와 같이 재심기각 판결에 대하여 다시 재심을 제기하는 경우의 소송물 확정 문제를 재심의 소송물 이론과 관련하여 논하시오.》

<문제17.2의 물음2> 재심제기기간의 기산점 판단 및 재심판결에 대한 재심의 소송물 확정 문제

I. 문제의 제기

- 사안에서 乙은 증거서류의 위조와 판단누락을 재심사유로 주장하여 재심의 소를 제기하고, 丙은 재심기각 판결에 대하여 다시 재심을 제기하려는 상황이다. 쟁점으로 <증거서류의 위조와 판단누락에 관한 재심제기기간의 기산점이 동일한지>와 <재심기각 판결에 대한 재심이 허용되는 경우 소송물을 어떻게 확정할 것인지>를 재심의 소송물 이론과 관련하여 검토할 필요가 있다. 이하에서는 재심사유별 재심제기기간의 기산점과 재심기각 판결에 대한 재심의 소송물 확정 문제를 논한다.

II. 재심제기기간의 기산점

1. 재심제기기간의 원칙

- 민사소송법 제456조 제1항에 의하면 재심의 소는 당사자가 판결이 확정된 후 재심의 사유를 안 날로부터 30일 이내에 제기하여야 한다. 이때 안 날이란 단순히 재심사유에 해당하는 사실을 안 것만으로는 부족하고, 그것이 법률상 재심사유에 해당한다는 것까지 구체적으로 안 날을 의미한다.

2. 각 사유별 기산점의 개별적 판단

(1) 제451조 제1항 제6호(증거 위조)

- 증거가 되는 서류의 위조를 이유로 재심을 제기하는 경우에는 동조 제2항에 따라 유죄의 판결이 확정된 때 또는 증거부족 외의 이유로 유죄의 확정 판결을 얻을 수 없는 때에 한하여 재심을 제기할 수 있다. 따라서 이 사유의 기산점은 유죄판결이 확정되었다는 사실을 안 날이 된다. 乙의 경우 2024. 6. 1.에 형사판결 확정 사실을 알았으므로 이때가 기산점이 된다.

(2) 제451조 제1항 제9호(판단 누락)

- 판단 누락은 판결문 자체에 나타나는 하자이다. 판례에 의하면 판단 누락과 같이 판결문 자체에 의하여 재심사유의 존부를 알 수 있는 경우에는 특별한 사정이 없는 한 판결 정본이 송달된 날에 그 사유를 알았다고 보아야 한다. 乙의 경우 원판결 확정일인 2023. 5. 1. 이전에 이미 판결 정본을 송달받았을 것이므로, 제9호 사유의 기산점은 제6호 사유의 기산점보다 훨씬 앞서게 된다.

III. 재심판결에 대한 재심과 소송물

1. 재심의 소송물 이론

- 재심의 소송물은 재심대상판결의 당부(본안 소송물)와 재심사유의 유무(본안전 소송물)로 구성된다. 재심법원은 먼저 재심사유의 존부를 심사하고, 사유가 인정될 때에만 본안 심리로 나아가는 단계적 구조를 취한다.

2. 재심기각판결에 대한 재심의 소송물 확정

(1) 재심기각판결의 성격

- 재심사유가 인정되지 않아 내려진 재심기각판결도 하나의 확정된 종국판결이므로, 이 판결 자체에 재심사유가 있다면 다시 재심을 제기할 수 있다.

(2) 소송물의 범위

- 재심기각판결에 대한 재심에서 본안전 소송물은 재심기각판결 자체에 존재하는 재심사유이다. 만약 이 재심의 소에서 사유가 인정되어 재심기각 판결이 취소된다면, 절차는 다시 전 단계의 재심절차로 복귀하게 된다. 즉, 丙이 제기하는 재심의 소송물은 재심기각판결이 정당한가의 여부이며, 이는 원칙적으로 원판결(丁과의 소송)의 당부와는 직접적인 관련이 없는 독립된 소송물로 취급된다.

IV. 사안의 적용

1. 乙의 재심제기기간 준수 여부

(1) 제6호 사유에 대한 판단

- 乙은 2024. 6. 1. 형사판결 확정 사실을 알았고, 그로부터 14일 뒤인 2024. 6. 15. 재심을 제기하였으므로 30일의 불변기간을 준수하였다.

(2) 제9호 사유에 대한 판단

- 제9호(판단 누락) 사유는 판결 송달 시에 알았다고 보아야 하므로, 2024. 6. 15. 시점에서는 이미 30일의 체척기간이 도과했을 가능성이 매우 높다. 따라서 乙이 주장하는 두 사유의 기산점은 동일하지 않으며, 제9호 사유는 기간 도과로 인해 부적법 각하될 가능성이 크다.

2. 丙의 재심 소송물 확정

- 丙이 제기하는 재심판결에 대한 재심의 소송물은 丁과의 원소송에 관한 것이 아니라, 재심기각판결 자체의 하자 여부이다. 재심법원은 재심기각판결 심리 과정에서 판사가 뇌물을 받았거나(제1호) 판단을 누락하는 등(제9호) 그 판결 자체에 결함이 있는지를 심리하게 된다.

V. 결론

- 乙이 주장하는 두 사유의 기산점은 동일하지 않다. 제6호 사유는 형사판결 확정 사실을 안 날부터 기산되나, 제9호 사유는 판결 송달 시부터 기산되므로 乙의 제9호 주장은 기간 도과로 부적법하다. 또한 丙의 사례에서 재심판결에 대한 재심의 소송물은 원판결의 당부가 아닌 재심판결 자체의 재심사유 유무 및 당부로 한정된다.

《【문제17.3】

<사례>

甲은 乙을 상대로 대여금 청구소송을 제기하여 제1심에서 승소하였다. 乙은 이에 불복하여 항소하였으나 항소심에서도 패소하였고, 상고를 제기하였으나 대법원에서 상고기각 판결이 선고되어 2023. 8. 1. 판결이 최종 확정되었다. 이후 2024. 9. 1. 乙은 항소심 당시 자신의 소송대리인이었던 A가 상대방 甲과 공모하여 乙에게 불리한 진술을 하는 등 대리권의 흠결이 있었음을 알게 되었다.

乙은 2024. 9. 20. 항소심 판결에 대하여 재심의 소를 제기하고자 한다. 그런데 확인 결과 乙은 항소심 재판 과정에서 이미 A의 대리권 행사에 문제가 있음을 인지하고 항소이유서 등에 이를 언급하며 다툰 사실이 있었다. 또한 乙은 항소심 판결뿐만 아니라 대법원의 상고기각 판결에 대해서도 재심사유가 존재한다며 동시에 재심을 제기하려 한다.

한편, 丙은 丁을 상대로 한 소송에서 화해권고결정을 받아 확정되었으나, 이후 그 결정의 기초가 된 증거가 위조되었음을 발견하였다. 丙은 일반적인 판결에 대한 재심 절차에 따라 화해권고결정에 대한 재심의 소를 제기할 수 있는지 여부를 고민하고 있다.

(물음1) 乙이 주장하는 재심사유인 대리권의 흠결이 민사소송법 제451조 제1항 단서의 보충성 원칙에 위배되는지 여부를 乙이 항소심에서 이를 주장하였던 사정과 관련하여 논하고, 항소심 판결과 상고기각 판결이 모두 존재하는 경우 재심 대상의 확정(재심의 소의 대상)에 관한 원칙을 설명하시오.》

<문제17.3의 물음1> 재심사유의 보충성 원칙 위배 여부 및 재심대상의 확정 원칙

I. 문제의 제기

- 사안에서 乙은 항소심에서 이미 소송대리인의 대리권 흠결을 주장하였음에도 이를 재심사유로 항소심 판결에 대한 재심을 제기하고, 상고기각 판결에 대해서도 함께 재심을 구하려는 상황이다. 쟁점으로 <대리권의 흠결이 민사소송법 제451조 제1항 단서의 보충성 원칙에 위배되는지>와 <항소심 판결 및 상고기각 판결이 모두 존재하는 경우 재심의 소의 대상을 어느 판결로 확정할 것인지>를 검토할 필요가 있다. 이하에서는 재심사유의 보충성 원칙 위반 여부와 재심의 소의 대상이 되는 판결을 설명한다.

II. 재심사유의 보충성 원칙

1. 보충성 원칙의 의의

- 재심의 소는 상소에 의하여 구제받을 수 없었던 경우에 한하여 허용되는 최후의 수단이다. 따라서 민사소송법 제451조 제1항 단서에 의하여 당사자가 상소에 의하여 재심사유를 주장하였거나, 상소 제기 당시에 그 사유를 알고 있었음에도 불구하고 이를 주장하지 않은 경우에는 재심의 소를 제기할 수 없다.

2. 대리권 흠결과 보충성 원칙

(1) 원칙적 적용

- 재심사유 중 법정대리권·소송대리권의 흠결은 제451조 제1항 제3호에 해당한다. 만약 당사자가 판결 확정 전의 소송절차에서 대리권의 흠결을 알고 있었고 이를 충분히 주장할 수 있었음에도 불구하고 주장하지 않았다면, 판결 확정 후 이를 이유로 재심을 제기하는 것은 보충성 원칙에 반하여 허용되지 않는다.

(2) 사안의 특수성

- 사안에서 乙은 항소심 재판 과정에서 이미 A의 대리권 행사에 문제가 있음을 인지하였고, 항소이유서 등을 통해 이를 언급하며 다툰 사실이 있다. 이는 당사자가 상소 절차에서 해당 사유를 이미 주장한 경우에 해당하므로, 법문의 취지상 동일한 사유를 내세워 다시 재심을 제기하는 것은 보충성 원칙에 위배될 소지가 크다.

III. 재심대상의 확정(재심의 소의 대상)

1. 기본 원칙

- 재심은 원칙적으로 확정된 종국판결을 대상으로 한다. 그러나 하나의 사건에 대하여 제1심, 항소심, 상고심 판결이 순차적으로 내려져 모두 확정된 경우, 어느 판결을 재심대상으로 삼을 것이냐가 문제된다.

2. 심급에 따른 대상 확정

(1) 항소심 판결과 상고심 판결의 관계

- 본안에 대하여 항소심 판결이 있고 이에 대한 상고가 기각되어 상고심 판결이 확정된 경우, 재심의 대상은 원칙적으로 본안판결인 항소심 판결이 된다. 상고심의 상고기각 판결은 하급심 판결의 당부를 심사하여 이를 유지하는 것이므로, 실질적인 판단의 기초가 된 항소심 판결에 재심사유가 있다면 항소심 판결을 대상으로 재심을 제기해야 한다.

(2) 상고심 판결 자체가 대상이 되는 경우

- 만약 재심사유가 항소심 판결에는 없고 오직 상고심의 소송절차나 상고심 판결 자체에만 존재하는 경우(예 : 상고심에서의 판단누락 등)에는 예외적으로 상고심 판결을 대상으로 재심을 제기할 수 있다.

(3) 흡수설과 독립설의 태도

- 판례는 원칙적으로 하급심 판결이 상급심 판결에 의하여 확정된 경우, 하급심 판결에 재심사유가 있다면 하급심 판결을 대상으로 재심을 제기해야 한다는 입장이다. 다만, 상고심에서 본안판결을 한 경우(상고기각이 아닌 파기자판 등)에는 상고심 판결이 대상이 된다. 사안과 같이 상고기각 판결로 항소심 판결이 확정된 경우에는 항소심 판결이 재심의 대상이 되는 것이 원칙이다.

IV. 사안의 적용

1. 보충성 원칙 위배 여부

- 사안의 乙은 항소심 과정에서 소송대리인 A의 대리권 흠결 문제를 인지하였고 이를 항소이유서에서 주장하며 다투었다. 이는 민사소송법 제451조 제1항 단서의 상소에 의하여 그 사유를 주장한 때에 해당한다. 재심은 상소로 구제받지 못한 경우에 한하여 보충적으로 허용되는 것이므로, 이미 항소심에서 심리되었거나 주장되었던 사유를 다시 재심사유로 삼는 것은 보충성 원칙에 위배되어 부적법하다.

2. 재심대상의 확정

- 乙은 항소심 판결과 상고기각 판결에 대하여 동시에 재심을 제기하려 한다. 대리권의 흠결이라는 사유가 항소심 변론 과정에서의 행위에 기인한 것이라면, 재심의 대상은 실질적인 심리가 이루어진 항소심 판결이 되어야 한다. 상고심 판결은 법률심으로서 항소심 판결을 확정시킨 것에 불과하므로, 항소심 절차상의 하자를 이유로 상고심 판결에 대해 재심을 제기하는 것은 원칙적으로 허용되지 않는다. 따라서 乙은 항소심 판결을 대상으로 재심을 제기하여야 하며, 상고기각 판결에 대한 재심은 특별한 사유(상고심 자체의 하자)가 없는 한 대상적격이 인정되기 어렵다.

V. 결론

- 사안의 乙이 주장하는 대리권 흠결 사유는 이미 항소심에서 주장된 바 있으므로 보충성 원칙에 위배되어 재심사유로 삼을 수 없다. 또한 재심대상 확정에 있어서는 실질적 판단의 기초가 된 항소심 판결이 대상이 되어야 하며, 상고기각 판결은 원칙적으로 재심의 대상이 될 수 없다.

《【문제17.3】

<사례>

甲은 乙을 상대로 대여금 청구소송을 제기하여 제1심에서 승소하였다. 乙은 이에 불복하여 항소하였으나 항소심에서도 패소하였고, 상고를 제기하였으나 대법원에서 상고기각 판결이 선고되어 2023. 8. 1. 판결이 최종 확정되었다. 이후 2024. 9. 1. 乙은 항소심 당시 자신의 소송대리인이었던 A가 상대방 甲과 공모하여 乙에게 불리한 진술을 하는 등 대리권의 흠결이 있었음을 알게 되었다.

乙은 2024. 9. 20. 항소심 판결에 대하여 재심의 소를 제기하고자 한다. 그런데 확인 결과 乙은 항소심 재판 과정에서 이미 A의 대리권 행사에 문제가 있음을 인지하고 항소이유서 등에 이를 언급하며 다툼 사실이 있었다. 또한 乙은 항소심 판결뿐만 아니라 대법원의 상고기각 판결에 대해서도 재심사유가 존재한다고 동시에 재심을 제기하려 한다.

한편, 丙은 丁을 상대로 한 소송에서 화해권고결정을 받아 확정되었으나, 이후 그 결정의 기초가 된 증거가 위조되었음을 발견하였다. 丙은 일반적인 판결에 대한 재심 절차에 따라 화해권고결정에 대한 재심의 소를 제기할 수 있는지 여부를 고민하고 있다.

(물음2) 재심제기기간의 준수 여부와 관련하여, 乙이 재심사유를 안 날로부터 30일 이내에 소를 제기하였으나 판결 확정 후 1년이 경과한 경우 재심의 적법성을 판단하시오. 또한 丙의 사례와 같이 화해권고결정이나 확정된 지급명령 등 판결이 아닌 준재심 대상에 대하여 재심의 소를 제기할 수 있는지 그 요건과 절차를 기술하시오.》

<문제17.3의 물음2> 재심제기기간의 적법성 판단 및 준재심의 요건과 절차

I. 문제의 제기

- 사안에서 乙은 재심사유를 안 날부터 30일 이내이지만 판결 확정 후 1년이 지난 시점에 재심의 소를 제기하려 하고, 丙은 화해권고결정 등 준재심 대상에 대하여 불복을 구하려는 상황이다. 쟁점으로 <재심제기기간의 준수 여부와 재심사유를 안 날부터의 기간 및 판결 확정 후 제척기간의 관계, 그리고 화해권고결정이나 확정된 지급명령 등에 대한 준재심의 허용 요건과 절차>를 검토할 필요가 있다. 이하에서는 재심제기기간의 적법 여부와 준재심의 요건 및 절차를 기술한다.

II. 재심제기기간의 준수 여부

1. 재심제기기간의 이중적 제한

(1) 주관적 제척기간

- 당사자가 판결이 확정된 후 재심의 사유를 안 날로부터 30일 이내에 제기하여야 한다.(민사소송법 제456조 제1항) 이는 당사자의 인지 시점을 기준으로 하는 주관적 기간이다.

(2) 객관적 제척기간

- 판결이 확정된 날로부터 5년을 경과한 때에는 재심의 소를 제기하지 못한다.(동법 제456조 제3항) 이는 판결 확정이라는 객관적 사실을 기준으로 하는 기간이다.

2. 대리권 흠결에 대한 특칙

(1) 기간 제한의 배제

- 민사소송법 제456조 제4항에 의하면, 제451조 제1항 제3호(대리권의 흠결)를 사유로 하는 재심의 소에는 위 30일 및 5년의 기간 제한 규정을 적용하지 아니한다. 이는 대리권의 흠결이 소송의 근본적인 절차적 정의를 침해하는 중대한 하자로 보기 때문이다.

(2) 사안의 판단

- 乙이 주장하는 재심사유는 소송대리인 A의 대리권 흠결(제451조 제1항 제3호)에 해당한다. 따라서 乙은 판결 확정 후 1년이 경과하였더라도 기간의 제한 없이 재심을 제기할 수 있다. 설령 乙이 재심사유를 안 날로부터 30일이 경과했더라도 대리권 흠결의 경우에는 기간 제한이 적용되지 않으므로 소 제기는 적법하다.

III. 준재심의 요건과 절차

1. 준재심의 의의

- 준재심이란 확정판결은 아니지만 판결과 동일한 효력을 가지는 조서(화해조서, 인낙조서)나 결정(화해권고결정, 확정된 지급명령 등)에 재심사유가 있는 경우, 재심 절차에 준하여 취소나 변경을 구하는 절차를 말한다.(민사소송법 제461조)

2. 준재심의 요건

(1) 대상적격

- 화해권고결정, 확정된 지급명령, 화해조서, 조정조서 등과 같이 확정판결과 동일한 효력을 가지는 것이어야 한다. 사안의 丙이 받은 화해권고결정은 이의신청 없이 확정된 경우 확정판결과 동일한 효력을 가지므로 준재심의 대상이 된다.

(2) 재심사유의 존재

- 민사소송법 제451조 제1항 각 호에서 규정하는 재심사유가 존재해야 한다. 丙의 사례에서 결정의 기초가 된 증거가 위조된 경우(제451조 제1항 제6호)는 전형적인 재심사유에 해당한다.

3. 준재심의 절차

(1) 관할 및 방식

- 준재심의 소는 해당 조서나 결정이 성립한 법원의 관할에 속한다. 소송 절차는 일반적인 재심의 소의 규정을 준용하며, 소장 형식으로 제출하여야 한다.

(2) 불복 기간

- 일반 재심과 마찬가지로 사유를 안 날로부터 30일, 확정된 날로부터 5년 이내에 제기하여야 한다. 단, 대리권 흠결을 사유로 하는 경우에는 기간 제한이 없다.

IV. 사안의 적용

1. 乙의 재심제기 적법성

- 乙은 2023. 8. 1. 판결이 확정된 후 1년이 지난 시점인 2024. 9. 20.에 소를 제기하였다. 일반적인 재심사유라면 안 날로부터 30일은 준수했으나 확정 후 기간에 대한 검토가 필요할 수 있으나, 乙의 사유는 대리권 흠결이다. 민사소송법 제456조 제4항에 따라 대리권 흠결에 의한 재심은 제기기간의 제한을 받지 않으므로, 乙의 재심의 소 제기는 기간 측면에서 적법하다.

2. 丙의 준재심 제기 가능성

- 丙은 화해권고결정에 대해 재심의 소를 제기할 수 있는지 고민하고 있다. 화해권고결정은 확정판결과 동일한 효력을 가지므로 민사소송법 제461조에 따른 준재심의 대상이 된다. 丙은 증거위조라는 재심사유를 발견하였으므로, 해당 사유를 안 날로부터 30일 이내에 화해권고결정을 내린 법원에 준재심의 소를 제기함으로써 구제받을 수 있다.

V. 결론

- 乙의 재심의 소는 대리권 흠결을 사유로 하므로 기간 제한의 적용을 받지 않아 적법하다. 丙은 화해권고결정에 대하여 민사소송법 제461조의 준재심 절차에 따라 증거위조를 사유로 한 불복이 가능하며, 이는 일반 재심의 규정과 절차를 준용하여 처리된다.

《【문제17.3-3】 제3자 재심청구에 대해 설명하시오. (25점)》

<문제17.3-3> 제3자 재심청구의 의의 및 제도적 취지, 적법요건, 제소기간, 절차 및 결과 처리

I. 제3자 재심청구의 의의 및 제도적 취지

1. 제3자 재심청구의 의의

- 제3자 재심청구란 확정된 취소판결로 인해 권리 또는 이익을 침해받은 제3자가 자신에게 책임 없는 사유로 소송에 참가하지 못해 판결에 영향을 미칠 공방방법을 제출하지 못한 때, 확정판결에 대해 재심을 청구하여 구제받는 제도이다.(행정소송법 제31조 제1항)

2. 제3자 재심청구의 제도적 취지

- 취소판결은 제3자에게도 효력이 미치므로(동법 제29조 제1항), 소송에 참여하지 못한 제3자가 불측의 피해를 볼 수 있다. 이에 제3자에게 최종적인 불복 기회를 제공하여 법적 안정성과 구체적 정의를 조화시키고자 한다.

II. 재심청구의 적법 요건

1. 주관적 요건 (재심청구인적격)

(1) 권리 또는 이익의 침해 받은 제3자일 것

- 재심을 청구하려면 확정판결로 권리나 법률상 이익을 침해받은 제3자여야 하며, 단순한 사실상·경제상 이해관계인은 제외된다. 판결의 대세효뿐 아니라 기속력에 따른 후속 처분으로 침해받는 자도 포함되나, 행정청은 이에 해당하지 않는다.

(2) 소송절차에 참가하지 못한 데 책임이 없을 것

- 제3자에게 책임 없는 사유로 소송절차에 참가하지 못하였어야 한다. 소송 계속 사실을 알지 못했거나, 알았더라도 참가가 불가능했던 객관적 사정이 인정되어야 하며, 고의나 중과실로 참가를 해태한 경우에는 적격이 부정된다.

2. 객관적 요건 (대상 및 재심사유와 제소기간)

(1) 대상적격 및 판결의 영향

- 재심청구의 대상은 처분등을 취소하는 확정된 중국판결이다. 또한 제3자가 소송에 참가하여 판결의 결과에 영향을 미칠 만한 공격 또는 방어방법을 제출하지 못하였음이 인정되어야 한다.

(2) 제3자 재심청구의 기간

- 판결이 확정되었음을 안 날부터 30일 이내, 판결이 확정된 날부터 1년 이내에 제기하여야 한다.(행정소송법 제31조 제2항) 이는 불변기간이므로 기간 도과 시 부적법 각하된다.

III. 재심청구의 절차 및 심리 결과의 처리

1. 소송 절차

(1) 전속관할과 소의 제기

- 재심청구는 원판결을 내린 법원의 전속관할에 속하며, 서면으로 신청하여야 한다. 청구서에는 당사자, 대리인, 대상 판결, 청구 취지 및 재심 사유를 명시하여 제출하여야 한다.

(2) 집행정지의 병합 신청

- 재심의 소 제기만으로는 판결의 집행을 정지되지 않으므로, 권리구제의 실효성을 확보하기 위해 필요한 경우 원판결의 효력이나 집행을 정지해 달라는 집행정지 신청을 병합하여 제기할 수 있다.

2. 법원의 심리 결과 처리

(1) 청구가 부적법한 경우 (재심각하)

- 소송요건을 결여하였거나 제소기간을 경과하여 부적법한 제3자 재심청구에 대해서는 법원이 본안 심리를 하지 않고 각하결정 또는 각하판결을 내린다.

(2) 본안 심리 결과에 따른 처리 (재심기각 및 청구인용)

① 재심기각의 판단

- 재심청구가 적법하나 심리 결과 제3자의 주장이 이유 없거나 기존 판결의 결과를 바꿀 영향이 없다면 기각 판결을 내린다.

② 재심인용의 판단

- 제3자의 공방방법이 타당하여 기존 판결을 유지할 수 없다고 인정되면 기존 판결을 취소·변경하고 새로운 판단을 내린다.

IV. 결론

- 제3자 재심청구는 행정소송의 대세효와 국민의 재판청구권 보장을 조화롭게 실현하는 소송법상 구제 수단이다. 비록 법적 안정성 수호를 위해 적법요건과 불변기간을 엄격히 규정하고 있으나, 절차적 흠결로 침해당한 국민의 구체적 권리 구제를 실질적으로 보장하는 최종적인 법적 안전망으로 기능한다.

《【문제17.4】

<사례>

甲은 乙을 상대로 소유권이전등기청구소송을 제기하여 승소 판결을 받았고, 이 판결은 확정되었다. 이후 乙은 판결의 기초가 된 서류가 위조되었음을 이유로 재심의 소를 제기하였다. 재심법원은 심리 결과 乙이 주장하는 재심사유가 인정된다고 판단하여 본안 심리에 착수하였다.

본안 심리 과정에서 乙은 전소(원래의 소송)에서 주장하지 않았던 새로운 방어방법으로 취득시효 완성을 주장하였다. 이에 대해 甲은 재심절차는 확정된 판결의 부당함을 시정하는 비상구제수단이므로 전소의 변론종결 전까지 제출했어야 할 공격방어방법을 새로이 제출하는 것은 허용되지 않는다고 맞서고 있다.

한편, 丙은 丁을 상대로 한 판결이 확정된 후 재심을 제기하여 재심대상판결을 취소하고 원고 丁의 청구를 기각한다는 내용의 재심판결을 받아냈다. 그런데 재심판결이 확정되기 전, 丁은 재심대상판결(전소 판결)에 기하여 이미 丙의 재산을 강제집행하여 대금을 회수해 간 상태였다. 丙은 재심판결을 근거로 丁에게 기집행된 대금의 반환을 구하고자 한다.

(물음1) 재심법원이 재심사유가 있다고 인정하여 본안 심리를 진행할 때, 당사자가 전소의 변론종결 전의 사유를 새로운 공격방어방법으로 제출할 수 있는지 여부를 재심절차의 성격(소송의 부활)과 관련하여 논하고, 재심법원의 심판 범위가 재심사유로 주장된 범위에 한정되는지 여부를 기술하시오.》

<문제17.4의 물음1> 재심절차의 본안심리에서 새로운 공격방어방법 제출 가능성 및 심판 범위

I. 문제의 제기

- 사안에서 乙은 재심사유가 인정되어 본안 심리가 진행되는 재심절차에서 전소의 변론종결 전에 존재하였으나 주장하지 않았던 취득시효 완성을 새로운 방어방법으로 제출한 상황이다. 쟁점으로 <재심절차의 소송부활적 성격에 비추어 전소의 변론종결 전 사유를 새로운 공격방어방법으로 제출할 수 있는지>와 <재심법원의 심판 범위가 재심사유로 주장된 범위에 한정되는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 재심절차에서 새로운 공격방어방법의 제출 가능 여부와 재심법원의 심판 범위를 기술한다.

II. 재심절차의 본안심리와 공격방어방법의 제출

1. 재심절차의 이단계 구조

- 재심절차는 재심청구가 적법하고 재심사유가 존재하는지를 심사하는 재심소송절차(준비절차)와, 재심사유가 인정될 경우 사건의 본안을 다시 심판하는 본안심판절차로 나뉜다. 법원이 재심사유가 있다고 인정하여 본안 심리에 착수하면, 전소의 판결은 효력을 잃고 사건은 판결 전의 상태로 돌아가게 된다.

2. 소송의 부활과 새로운 공격방어방법

(1) 소송의 부활(Litigatio Reviviscit)의 원칙

- 재심사유가 인정되어 본안 심리에 들어가면 종전의 소송절차가 다시 부활한다. 이 단계에서 재심법원은 전소의 상급심으로서가 아니라, 재심대상 판결을 한 법원의 지위에서 사건을 다시 심리한다.

(2) 새로운 공격방어방법의 제출 가능성

- 재심본안절차는 종전 소송절차의 연장이므로, 당사자는 전소의 변론종결 전의 사유는 물론 변론종결 후에 발생한 사유도 새로운 공격방어방법으로 제출할 수 있다. 이는 재심절차가 단순히 재심사유의 존부만을 다루는 것이 아니라, 사건의 적절한 해결을 목적으로 하는 본안 재판이기 때문이다.

(3) 학설 및 판례의 태도

- 통설과 판례는 재심사유가 인정되어 본안 심리를 하는 경우, 당사자는 전소에서 제출하지 않았던 새로운 공격방어방법을 자유롭게 제출할 수 있다고 본다. 다만, 재심절차가 상고심인 경우에는 상고심의 특성상 새로운 사실이나 증거를 제출할 수 없다는 제약이 따를 뿐이다.

III. 재심법원의 심판 범위

1. 불이익변경금지의 원칙 준용

- 재심절차에서도 불이익변경금지의 원칙이 적용된다. 즉, 재심법원은 재심원고가 신청한 불복의 범위 내에서만 재심대상판결을 취소하거나 변경할 수 있다.

2. 재심사유와 본안 심리의 관계

(1) 심판 범위의 한정 여부

- 재심법원이 본안을 심리할 때, 그 심판의 범위가 당사자가 주장한 재심사유와 관련된 부분에만 한정되는지가 문제된다. 법리는 재심사유의 존부 판단은 본안 심리에 들어가기 위한 전제조건일 뿐이며, 일단 본안 심리에 들어간 이상 재심사유와 무관한 본안의 모든 쟁점이 심판 대상이 된다고 본다.

(2) 변론주의의 적용

- 재심본안심리에서도 일반 소송절차와 마찬가지로 변론주의가 적용되므로, 당사자가 주장하지 않은 사실을 법원이 임의로 심판할 수는 없으나, 당사자가 적법하게 제출한 공격방어방법이라면 재심사유와 관련이 없더라도 법원은 이를 심리하여 판결의 기초로 삼아야 한다.

IV. 사안의 적용

1. 乙의 새로운 방어방법 제출에 대한 판단

- 사안에서 乙은 재심본안심리 과정에서 취득시효 완성이라는 새로운 방어방법을 제출하였다. 재심사유(서류 위조)가 인정되어 본안 심리가 개시되었다면, 소송은 부활하여 종전 절차의 연장선상에 있게 된다. 따라서 乙은 전소에서 주장하지 않았던 사유라 할지라도 본안의 승패를 가를 수 있는 방어방법을 새로이 제출할 수 있다. 甲의 주장은 재심절차의 소송 부활적 성격을 오해한 것으로 타당하지 않다.

2. 재심법원의 심판 범위 적용

- 재심법원은 乙이 주장한 재심사유인 서류 위조 여부에 대해서만 심리하는 것이 아니라, 乙이 새로 제출한 취득시효 완성 여부에 대해서도 심리해야 한다. 본안 심리에 착수한 이상 법원의 심판 범위는 재심사유로 주장된 범위에 한정되지 않으며, 부활한 소송 전체에 대해 다시 심리하여 결론을 내려야 하기 때문이다.

V. 결론

- 재심사유가 인정되어 본안 심리에 착수한 경우 소송은 부활하므로, 당사자인 乙은 전소의 변론종결 전의 사유인 취득시효 완성을 새로운 방어방법으로 제출할 수 있다. 또한 재심법원의 심판 범위는 당사자가 주장한 재심사유의 범위에 국한되지 않고 본안 전체에 미치므로, 법원은 乙의 새로운 주장을 심리하여 판결에 반영하여야 한다.

《【문제17.4】

<사례>

甲은 乙을 상대로 소유권이전등기청구소송을 제기하여 승소 판결을 받았고, 이 판결은 확정되었다. 이후 乙은 판결의 기초가 된 서류가 위조되었음을 이유로 재심의 소를 제기하였다. 재심법원은 심리 결과 乙이 주장하는 재심사유가 인정된다고 판단하여 본안 심리에 착수하였다.

본안 심리 과정에서 乙은 전소(원래의 소송)에서 주장하지 않았던 새로운 방어방법으로 취득시효 완성을 주장하였다. 이에 대해 甲은 재심절차는 확정된 판결의 부당함을 시정하는 비상구제수단이므로 전소의 변론종결 전까지 제출했어야 할 공격방어방법을 새로이 제출하는 것은 허용되지 않는다고 맞서고 있다.

한편, 丙은 丁을 상대로 한 판결이 확정된 후 재심을 제기하여 재심대상판결을 취소하고 원고 丁의 청구를 기각한다는 내용의 재심판결을 받아냈다. 그런데 재심판결이 확정되기 전, 丁은 재심대상판결(전소 판결)에 기하여 이미 丙의 재산을 강제집행하여 대금을 회수해 간 상태였다. 丙은 재심판결을 근거로 丁에게 기집행된 대금의 반환을 구하고자 한다.

(물음2) 재심판결에 의해 재심대상판결이 취소된 경우, 이미 취소된 판결에 기하여 집행된 결과에 대하여 丙이 재심절차 내에서 직접 원상회복을 청구할 수 있는 방법(민사소송법 제461조)과 그 요건에 대하여 설명하시오.》

<문제17.4의 물음2> 재심대상판결의 취소에 따른 강제집행 결과의 원상회복청구 방법 및 요건

I. 문제의 제기

- 사안에서 丙은 재심판결로 재심대상판결이 취소된 후 그 취소된 판결에 기하여 이미 이루어진 강제집행으로 회수된 대금의 반환을 재심절차에서 구하고자 하는 상황이다. 쟁점으로 <재심판결에 의해 재심대상판결이 취소된 경우 민사소송법 제461조에 따라 재심절차 내에서 직접 원상회복을 청구할 수 있는지와 그 요건>을 검토할 필요가 있다. 이하에서는 재심절차에서의 원상회복청구의 방법과 그 요건을 설명한다.

II. 원상회복신청의 의의 및 성격

1. 제도의 의의

- 민사소송법 제461조에 의하면, 재심대상판결이 취소되는 경우 피고(재심원고)는 그 판결에 기하여 이미 집행된 부분에 대하여 원상회복과 집행으로 인한 손해배상을 재심절차 내에서 함께 청구할 수 있다. 이는 승소한 피고의 보호와 소송경제의 도모를 목적으로 한다.

2. 법적 성격

(1) 병합소송의 성격

- 원상회복신청은 재심의 소에 병합하여 제기하는 소송의 성격을 갖는다. 즉, 재심사유의 존부를 다투는 절차와는 별개로, 재심대상판결이 취소될 것을 조건으로 하는 조건부 병합소송이다.

(2) 반소와의 구별

- 이 신청은 형식상 반소와 유사하지만, 법률에 의해 특별히 허용된 독립된 신청이다. 따라서 반소의 일반적 요건(상호 관련성 등)을 갖출 필요는 없으며, 제461조가 정한 요건만 충족하면 족하다.

III. 원상회복신청의 요건

1. 주관적 요건

(1) 신청권자

- 재심의 소를 제기한 당사자(재심원고)만이 신청할 수 있다. 사안의 丙이 이에 해당한다.

(2) 상대방

- 재심대상판결에 기하여 강제집행을 실시하여 이익을 얻은 자(재심피고)를 상대로 해야 한다. 사안의 丁이 이에 해당한다.

2. 객관적 요건

(1) 재심대상판결의 존재와 집행을 완료

- 확정된 재심대상판결이 존재해야 하며, 그 판결에 기하여 이미 강제집행이 행하여졌거나 채무자가 판결의 강제를 면하기 위해 임의로 이행(임의변제)을 완료한 상태여야 한다.

(2) 재심대상판결의 취소 가능성

- 원상회복신청은 재심대상판결이 취소되고 본안 청구가 기각될 것을 전제로 하므로, 재심사유가 인정되지 않아 재심청구가 기각될 경우에는 원상회복신청 역시 판단될 수 없다.

3. 절차적 요건

(1) 신청의 시기

- 재심의 소가 제기되어 심리가 진행 중인 동안에만 신청이 가능하다. 즉, 재심의 변론종결 전까지 신청해야 한다.

(2) 신청의 방식

- 소의 제기예 준하는 방식이 필요하다. 서면으로 신청하는 것이 원칙이며, 인지대 등 소정의 비용을 납부해야 한다.

IV. 원상회복의 범위와 심리

1. 회복의 범위

(1) 원상회복

- 강제집행으로 인하여 인도한 물건이나 지급한 금전의 반환을 청구할 수 있다. 금전의 경우 집행 시부터 반환 시까지의 법정이자도 포함된다.

(2) 손해배상

- 집행 자체로 인하여 발생한 부수적인 손해에 대해서도 배상을 청구할 수 있다. 다만, 이는 집행행위와 인과관계가 있는 손해에 한정된다.

2. 법원의 심리 및 판결

- 법원은 먼저 재심사유를 심리하여 재심대상판결을 취소하는 경우에 한하여 원상회복신청을 심리한다. 만약 재심사유가 인정되어 판결을 취소하고 청구를 기각한다면, 동시에 원상회복을 명하는 판결을 선고한다. 이때 원상회복판결에는 가집행 선고를 붙일 수 있다.

V. 사안의 적용

1. 丙의 구제방법(민사소송법 제461조의 활용)

- 사안에서 丙은 이미 재심을 제기하여 재심대상판결을 취소하고 丁의 청구를 기각한다는 재심판결을 받아낸 상태이다. 다만, 재심판결이 확정되기 전이므로 丙은 해당 재심절차의 변론종결 전까지 민사소송법 제461조에 따른 원상회복신청을 병합하여 제기했어야 한다. 만약 이미 변론이 종결되어 재심판결이 선고된 상황이라면 별도의 부당이득반환청구소송을 제기해야 할 것이나, 재심절차가 계속 중이라면 직접 신청이 가능하다.

2. 요건 구비 여부 판단

- 丙은 재심원고로서 집행채권자인 丁을 상대로 신청할 수 있다. 丁이 재심대상판결에 기하여 丙의 재산을 강제집행하여 대금을 회수한 사실이 명백하므로, 집행 완료라는 객관적 요건도 충족한다. 재심법원이 이미 丁의 청구를 기각하는 판단을 내렸으므로, 원상회복의 근거인 판결의 취소 조건도 달성되었다.

VI. 결론

- 丙은 민사소송법 제461조에 의거하여 재심의 소가 계속 중인 법원에 원상회복신청을 함으로써, 별도의 소송 없이 丁에게 기집행된 대금 및 이에 대한 이자의 반환을 청구할 수 있다. 이는 재심대상판결의 취소를 당연한 전제로 하며, 丙은 이를 통해 강제집행 전의 상태로 재산을 회복할 수 있는 효율적인 구제를 받게 된다.

《【문제17.5】

<사례>

甲은 乙을 상대로 대여금 청구소송을 제기하였고, 법원은 소송 계속 중 양 당사자의 합의를 이끌어내기 위해 화해권고결정을 내렸다. 甲과 乙 모두 결정서를 송달받은 날로부터 2주 이내에 이의를 신청하지 않아 위 결정은 확정판결과 동일한 효력을 가지게 되었다. 그런데 3개월 뒤 乙은 위 화해권고결정의 기초가 된 갑 제출의 영수증이 위조된 것임을 알게 되었다.

한편, 丙은 丁을 상대로 물품대금 지급을 구하는 지급명령을 신청하였고, 丁이 이의를 제기하지 않아 지급명령이 확정되었다. 그러나 이후 丁은 丙이 지급명령 신청 당시 丁의 주소를 허위로 기재하여 송달받지 못하게 함으로써 방어할 기회를 박탈당했다는 사실을 깨달았다. 丁은 이미 확정된 지급명령의 효력을 제거하고자 한다.

또한, 소송법상 조정이 성립하여 조정조서가 작성된 경우에도 당사자 일방이 조정 성립 과정에 중대한 절차적 하자가 있음을 이유로 그 효력을 다투려 하고 있다. 이들은 모두 일반적인 재심의 소가 아닌 준재심의 방법으로 구제받을 수 있는지 의문이다.

(물음1) 확정된 화해권고결정에 대하여 乙이 취할 수 있는 불복 방법인 준재심의 소의 요건을 민사소송법 제461조와 관련하여 기술하고, 재심의 소에 관한 규정이 준재심 절차에 어느 정도까지 준용되는지 그 범위에 대하여 설명하시오.》

<문제17.5의 물음1> 확정된 화해권고결정에 대한 준재심의 소의 요건과 재심 규정의 준용 범위

I. 문제의 제기

- 사안에서 甲과 乙은 이의 없이 확정되어 확정판결과 동일한 효력이 발생한 화해권고결정의 기초가 된 영수증이 위조된 사실을 뒤늦게 알게 되어 그 효력을 다투려는 상황이다. 쟁점으로 <확정된 화해권고결정에 대하여 민사소송법 제461조에 따른 준재심의 소가 허용되는 요건과 재심의 소에 관한 규정이 준재심 절차에 어느 범위까지 준용되는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 확정된 화해권고결정에 대한 준재심의 소의 요건과 재심 규정의 준용 범위를 설명한다.

II. 준재심의 소의 의의 및 대상

1. 제도의 의의

- 준재심이란 확정판결이 아님에도 불구하고 그와 동일한 효력을 가지는 조서(재판상 화해, 조정조서 등)나 결정 등에 재심사유에 해당하는 하자가 있는 경우, 그 효력을 배제하기 위해 제기하는 비상구제수단이다.

2. 대상(민사소송법 제461조)

(1) 제461조 본문

- 조서가 확정판결과 동일한 효력을 가지는 경우로서 재판상 화해조서, 청구의 포기·인낙조서가 대표적이다.

(2) 제461조 단서

- 확정판결과 동일한 효력을 가지는 결정이나 명령이 이에 해당한다. 사안의 화해권고결정은 민사소송법 제231조에 의해 확정판결과 동일한 효력을 가지므로 준재심의 대상이 된다.

III. 준재심의 소의 요건

1. 주관적 요건

(1) 당사자 적격

- 준재심 대상인 결정이나 조서의 당사자 또는 그 승계인이 신청할 수 있다. 사안에서는 화해권고결정의 당사자인 乙이 원고가 된다.

(2) 상대방

- 해당 절차의 상대방 당사자(사안의 甲)를 피고로 하여 제기해야 한다.

2. 객관적 요건

(1) 준재심 사유의 존재

- 민사소송법 제451조 제1항 각 호에서 정한 재심사유가 존재해야 한다. 사안의 경우 증거가 된 문서가 위조된 것은 제451조 제1항 제6호의 사유에 해당한다. 다만, 문서 위조를 이유로 할 때는 원칙적으로 처벌받을 확정판결이 있어야 하나, 사안처럼 증거 흠결로 확정판결을 얻을 수 없는 때에는 제452조에 의해 위조 사실을 증명하여 제기할 수 있다.

(2) 대상의 확정

- 화해권고결정의 경우 이의신청 기간이 경과하여 확정판결과 동일한 효력을 갖춘 상태여야 한다.

3. 절차적 요건

(1) 제소기간

- 재심과 마찬가지로 준재심 사유를 안 날로부터 30일 이내, 결정이 확정된 날로부터 5년 이내에 제기해야 한다. 乙은 위조 사실을 안 날로부터 30일 이내에 소를 제기해야 한다.

(2) 관할법원

- 해당 결정이나 조서가 성립한 법원의 전속관할에 속한다.

IV. 재심 규정의 준용 범위

1. 준용의 원칙

- 민사소송법 제461조는 제451조 내지 제460조의 규정을 준용한다고 명시하고 있다. 따라서 재심의 절차, 재심사유, 기간, 심리 방식 등은 준재심 절차에 원칙적으로 그대로 적용된다.

2. 준용의 구체적 내용

(1) 재심사유의 준용

- 제451조 제1항 각 호의 사유가 그대로 준재심 사유가 된다. 따라서 조서의 내용 자체가 허위이거나 절차상 중대한 하자가 있는 경우 등이 포함된다.

(2) 재심제기기간의 준용

- 제456조의 기간 규정이 적용된다. 불변기간인 30일의 제척기간과 5년의 장기 제척기간이 적용되나, 상소의 효력이 있는 하자가 있는 경우 등 특정 사유에 대해서는 5년의 제한이 적용되지 않는다.

(3) 심리 및 재판 절차의 준용

- 재심의 소제기 방식, 재심개시절차와 본안심리의 2단계 구성, 판결의 형식 등이 준용된다.

3. 준용의 한계

- 준재심은 판결이 아닌 조서나 결정을 대상으로 하므로, 판결의 속성을 전제로 하는 규정은 성질상 준용되지 않거나 변형되어 적용된다. 예를 들어, 재심대상판결이 취소되면 전소송이 부활하여 다시 심리하지만, 화해조서에 대한 준재심이 인용되어 조서가 취소되면 화해 성립 전의 소송상태로 복귀하게 된다.

V. 사안의 적용

1. 乙의 구제수단

- 乙은 민사소송법 제461조에 따라 준재심의 소를 제기할 수 있다. 화해권고결정은 확정판결과 동일한 효력을 가지며, 乙이 주장하는 영수증 위조는 제451조 제1항 제6호의 재심사유에 해당하기 때문이다.

2. 절차적 준수사항

- 乙은 영수증이 위조되었다는 사실을 안 날로부터 30일 이내에 화해권고결정을 내린 법원에 준재심의 소를 제기해야 한다. 재심 규정이 준용되므로, 乙은 위조 사실을 증명하는 자료를 첨부하여 소를 제기해야 하며 법원은 1단계로 준재심 사유 유무를 심사한 후 본안을 심리하게 된다.

VI. 결론

- 확정된 화해권고결정의 효력을 다투기 위해 乙은 준재심의 소를 제기해야 한다. 이는 민사소송법 제461조에 근거하며, 재심에 관한 제반 규정(사유, 기간, 심리절차 등)이 원칙적으로 준용된다. 다만, 준재심 인용 시에는 판결의 취소와 달리 당해 사건이 화해권고결정 전의 소송계속 상태로 복귀한다는 점에서 실무적 차이가 존재한다.

《【문제17.5】

<사례>

甲은 乙을 상대로 대여금 청구소송을 제기하였고, 법원은 소송 계속 중 양 당사자의 합의를 이끌어내기 위해 화해권고결정을 내렸다. 甲과 乙 모두 결정서를 송달받은 날로부터 2주 이내에 이의를 신청하지 않아 위 결정은 확정판결과 동일한 효력을 가지게 되었다. 그런데 3개월 뒤 乙은 위 화해권고결정의 기초가 된 갑 제출의 영수증이 위조된 것임을 알게 되었다.

한편, 丙은 丁을 상대로 물품대금 지급을 구하는 지급명령을 신청하였고, 丁이 이의를 제기하지 않아 지급명령이 확정되었다. 그러나 이후 丁은 丙이 지급명령 신청 당시 丁의 주소를 허위로 기재하여 송달받지 못하게 함으로써 방어할 기회를 박탈당했다는 사실을 깨달았다. 丁은 이미 확정된 지급명령의 효력을 제거하고자 한다.

또한, 소송법상 조정이 성립하여 조정조서가 작성된 경우에도 당사자 일방이 조정 성립 과정에 중대한 절차적 하자가 있음을 이유로 그 효력을 다투려 하고 있다. 이들은 모두 일반적인 재심의 소가 아닌 준재심의 방법으로 구제받을 수 있는지 의문이다.

(물음2) 丙이 丁을 상대로 얻은 확정된 지급명령에 대하여 丁이 준재심을 제기할 수 있는지 여부를 판례의 태도에 근거하여 판단하고, 조정조서나 재판상 화해와 같이 판결이 아닌 처분권주의가 적용되는 조서에 대한 준재심 사유의 특수성을 재심사유와 비교하여 논하시오.》

<문제17.5의 물음2> 확정된 지급명령에 대한 준재심 제기 가능성 및 조서의 특수성에 따른 준재심 사유

I. 문제의 제기

- 사안에서 丁은 확정된 지급명령이 허위 주소 기재로 인해 송달받지 못한 상태에서 확정되었음을 이유로 그 효력을 다투고자 하고, 조정조서 등에 대해서도 준재심으로 다룰 수 있는지가 문제되는 상황이다. 쟁점으로 <확정된 지급명령에 대한 준재심의 허용 여부와 판결이 아닌 조정조서·재판상 화해 등에 대한 준재심 사유의 특수성을 재심사유와 비교>하여 검토할 필요가 있다. 이하에서는 지급명령에 대한 준재심의 허용 여부와 조정조서 등에 대한 준재심 사유의 특수성을 논한다.

1. 지급명령의 효력 및 구제수단

(1) 지급명령의 효력

- 민사소송법 제474조에 따라 확정된 지급명령은 확정판결과 같은 효력을 가진다. 다만 판결과 달리 기판력이 인정되는지에 대해서는 견해의 대립이 있으나, 민사집행법 제58조 제3항은 확정된 지급명령에 대한 청구이의의 소에서 기판력의 시간적 한계에 따른 제한을 두지 않고 있다.

(2) 구제방법의 분화

- 확정된 지급명령의 효력을 배제하기 위한 방법으로는 청구이의의 소(민사집행법 제58조)가 일반적이다. 사안처럼 송달의 하자가 있는 경우에는 준재심의 소를 제기할 수 있는지에 대한 판례의 검토가 요구된다.

2. 판례의 태도

(1) 준재심 부정설

- 판례는 확정된 지급명령에 대하여 민사소송법 제461조가 정한 준재심의 소를 제기할 수 없다는 입장이다. 지급명령은 기판력이 없으므로 그 효력을 다투기 위해서는 청구이의의 소를 제기하거나, 송달 자체가 부적법하여 확정되지 않았음을 주장하며 이의신청 및 추완이의를 하는 방식으로 해결해야 한다고 본다.

(2) 사안의 경우

- 사안에서 丁은 丙이 주소를 허위 기재하여 송달을 가로챘음을 주장하고 있다. 판례에 따르면 이 경우 지급명령은 적법하게 송달된 것으로 볼 수 없어 확정되지 않았으므로, 丁은 준재심을 제기할 것이 아니라 지급명령에 대한 이의신청을 하거나 청구이의의 소를 통해 다투어야 한다.

II. 조서에 대한 준재심 사유의 특수성

1. 재판상 화해 및 조정조서의 성질

(1) 이원적 성격

- 재판상 화해나 조정조서는 소송법상 판결과 동일한 효력을 가지는 소송행위인 동시에, 당사자 간의 합의라는 사법상 계약의 성격을 병유한다.

(2) 처분권주의의 발현

- 판결이 법원의 판단에 의한 것인 반면, 조서는 당사자의 의사 합치에 기초한다. 따라서 그 효력을 다투는 사유 역시 판결에 대한 재심사유와는 차이가 발생할 수밖에 없다.

2. 준재심 사유의 확장 여부(사법상 하자)

(1) 원칙(재심사유 한정)

- 민사소송법 제461조는 제451조의 재심사유를 준용한다고 규정하므로, 원칙적으로 법문에 열거된 재심사유가 있어야만 준재심이 가능하다.

(2) 특수성(실체법상 하자)

- 재판상 화해나 조정은 사법상 합의를 기초로 하므로, 합의 자체에 민법상 무효나 취소 사유(의사표시의 착오, 사기, 강박 등)가 있는 경우 이를 준재심 사유로 인정할 것인가가 핵심이다. 판례는 화해조서 등의 내용이 실체법상 계약의 원인 무효 사유가 있더라도 그것이 민사소송법이 정한 재심사유에 해당하지 않는 한 준재심의 소를 제기할 수 없다는 태도를 견지해 왔다.

3. 재심사유와 비교한 특수성

(1) 절차적 하자의 중시

- 조서의 경우 당사자의 대리권 흠결(제451조 제1항 제3호) 등 절차적 공정성을 해치는 사유가 준재심에서 핵심적으로 다루어진다.

(2) 사법상 하자의 포섭 노력

- 비록 판례는 엄격히 재심사유에 한정하나, 해석상 제451조 제1항 제9호(판결의 기초가 된 재판의 변경) 등을 원용하여 실체법상 하자를 간접적으로 수용하려는 학설적 시도가 존재한다. 그러나 현행 실무상 판결에 대한 재심보다 의사의 합치라는 성립 요건의 하자가 더 중요하게 다루어진다는 점이 조서 준재심의 특수성이다.

III. 사안의 적용

1. 지급명령에 대한 丁의 불복

- 丁이 제기하려는 준재심은 판례의 태도에 비추어 볼 때 부적법하다. 丁은 주소 허위 기재 및 송달 불능을 근거로 지급명령 이의신청(또는 추완이의)을 하거나, 집행력을 배제하기 위한 청구이의의 소를 제기하는 것이 타당한 구제수단이다.

2. 조정조서에 대한 불복

- 조정 성립 과정에 중대한 절차적 하자가 있다는 주장은 민사소송법 제461조 및 제451조 제1항 소정의 사유(예 : 대리권의 흠결 등)에 해당할 경우 준재심의 소를 통해 다룰 수 있다. 다만 단순히 조정 내용이 불공정하다거나 사법상 착오가 있었다는 사유만으로는 판례상 준재심 청구가 기각될 가능성이 높다.

V. 결론

- 확정된 지급명령은 기판력이 없고 별도의 불복 방법이 존재하므로 준재심의 대상이 되지 않는다는 것이 확립된 판례이다. 또한 재판상 화해나 조정조서에 대한 준재심은 판결과 달리 사법상 계약의 성질을 가지나, 우리 법제는 법적 안정성을 위해 민사소송법상 열거된 재심사유가 있는 경우에 한하여 준재심을 허용하므로 청구인은 이를 엄격히 증명하여야 한다.